
Las decisiones fundamentales del constituyente

PID_00258346

Clara Marsan Raventós
Marcel Mateu Vilaseca

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 11 horas





Clara Marsan Raventós

Profesora de derecho constitucional de la UOC.



Marcel Mateu Vilaseca

Profesor de derecho constitucional en la UOC.

Índice

Introducción.....	5
Objetivos.....	7
1. Las opciones básicas de una constitución.....	9
1.1. La forma de estado	9
1.1.1. Las alternativas al Estado de derecho, democrático y social	9
1.1.2. El Estado de derecho	13
1.1.3. El estado democrático	20
1.1.4. El Estado social	39
1.2. La forma de gobierno	46
1.3. La forma de organización territorial	51
1.4. El modelo de justicia constitucional	57
2. Las opciones básicas de la Constitución española.....	61
2.1. La forma de Estado: el Estado social y democrático de derecho	62
2.1.1. Tres calificativos para un concepto unitario	62
2.1.2. El Estado de derecho en la Constitución española	64
2.1.3. El Estado democrático en la Constitución española	74
2.1.4. El Estado social en la Constitución española	95
2.2. La forma de Gobierno: la monarquía parlamentaria	103
2.3. La forma de organización territorial: el Estado de las autonomías	110
2.4. El modelo de justicia constitucional: un sistema jurisdiccional y concentrado en manos del Tribunal Constitucional	121
Resumen.....	129
Actividades.....	135
Ejercicios de autoevaluación.....	135
Solucionario.....	137
Glosario.....	138
Bibliografía.....	139

Introducción

Al principio de estos materiales, avanzábamos que estos módulos quieren ser una herramienta útil para cualquiera que desee ejercer de «ciudadano responsable», que necesariamente tiene que conocer, aunque sea mínimamente, la estructura y el funcionamiento de su estado, porque si es un estado democrático cada ciudadano es, ni más ni menos, que cosoberano, junto con el resto de la ciudadanía. Con lo que se ha explicado en los módulos anteriores, ahora estamos en condiciones de construir un esbozo de lo que son los fundamentos del Estado constitucional de nuestro tiempo, que ya hemos visto que es diferente en cada país, pero que se basa en dos ideas clave del constitucionalismo: la limitación del poder y el respeto a los derechos humanos; y a partir de aquí, cada uno de los estados que sigue estos postulados es fruto de una serie de decisiones fundamentales que se han tenido que tomar entre un abanico limitado de opciones. Y en este panorama complejo, aún debemos tener presente que, junto a estos estados constitucionales, hoy día hay otros que, a pesar de que puedan tener formalmente un texto que denominen constitución, en realidad no son estados de derecho (con división de poderes, con sujeción de todos los poderes al derecho y con garantía de los derechos fundamentales) y, por lo tanto, tampoco pueden ser considerados estados democráticos. Debemos ser muy conscientes de que, como mínimo en derecho, el nombre no hace la cosa. También hay que dejar constancia de que, más allá de las distintas formas estatales, que son las que analizaremos en este último módulo, también hay otras alternativas no estatales, como por ejemplo la anarquía, que propone la supresión del sistema político estatal (el Estado no existiría porque desaparecería la coerción política, lo cual permitiría que todas las funciones reguladoras del sistema político fueran llevadas a cabo por otros subsistemas sociales).

Enlazando con algunos conceptos que hemos explicado sobre todo en el módulo 1 (elementos constitutivos del Estado, principio de división del poder como instrumento para la garantía de los derechos, carácter supremo de la constitución, justicia constitucional, etc.), ahora seguiremos con otros conceptos también básicos y comunes del derecho constitucional. En la primera parte de este tercer módulo, estudiaremos las cuatro grandes decisiones que tiene que tomar cualquier constituyente: sobre la forma de Estado, la forma de Gobierno, la forma de organización territorial y el modelo de justicia constitucional y, en la segunda parte de este último módulo, veremos cuáles han sido las opciones elegidas por el constituyente español de 1978: el Estado social y democrático de derecho, el sistema parlamentario en su variante monárquica, el Estado autonómico y un tipo de justicia constitucional jurisdiccional y concentrada que tiene al Tribunal Constitucional como garantía de la supremacía normativa de la Constitución. Daremos solo una visión básica y general de estas cuatro cuestiones, porque en la asignatura de *Derecho constitucional* se dedica todo un módulo a profundizar en el sistema autonómico, otro a los

derechos fundamentales (que son la base de la forma de Estado social y democrático de derecho) y un tercero a explicar los órganos constitucionales, en el que se analizarán con detalle, entre otros, el Gobierno del Estado, las Cortes y las relaciones entre ellos, y también el TC como órgano y los principales procedimientos en los cuales tiene competencia.

Objetivos

En los materiales didácticos de este módulo encontraréis los contenidos y las herramientas procedimentales para lograr los objetivos siguientes:

- 1.** Conocer cuáles son las grandes decisiones que tiene que tomar cualquier constituyente y las opciones que tiene respecto a cada una.
- 2.** Comprender los conceptos de forma de Estado, forma de Gobierno y forma de organización territorial, y profundizar en el concepto de justicia constitucional (que ya se ha explicado en el módulo 1).
- 3.** Saber las opciones elegidas por el constituyente español de 1978 y sus principales características respecto a la forma de Estado (el Estado social y democrático de derecho), la forma de Gobierno (el sistema parlamentario en su variante monárquica), la forma de organización territorial (el Estado autonómico) y sobre la justicia constitucional (una variante del modelo jurisdiccional concentrado que tiene al Tribunal Constitucional como garantía de la supremacía normativa de la Constitución).

1. Las opciones básicas de una constitución

En la primera parte de este tercer módulo, estudiaremos las cuatro grandes decisiones que debe tomar cualquier constituyente: sobre la forma de Estado, la forma de Gobierno, la forma de organización territorial y el modelo de justicia constitucional. Son las opciones básicas porque son el fundamento de cualquier sistema constitucional, el *núcleo esencial* que define un régimen constitucional. Y estudiaremos también las principales opciones que hay a la hora de tomar estas decisiones fundamentales.

1.1. La forma de estado

La forma de Estado es un concepto teórico que hace referencia a los denominados **elementos constitutivos del estado** (ordenamiento jurídico, poder soberano, pueblo y territorio) y **que se construye a partir de dos de estos cuatro elementos: el poder** (el aparato de Gobierno) **y el pueblo** (la comunidad política). **Las diferentes formas de Estado dependen del tipo de relaciones que mantienen el aparato de Gobierno** (los poderes públicos, especialmente los órganos superiores o también llamados órganos constitucionales del Estado) **con los ciudadanos**. Siguiendo el análisis de Carles Viver, **estas relaciones dependen fundamentalmente de tres variables:**

- la sumisión o no de los poderes del Estado al derecho;
- la participación, o no, de los ciudadanos en el ejercicio del poder público estatal, y
- la intervención o no del Estado en la vida socioeconómica.

Lectura recomendada

C. Viver Pi-Sunyer (1992). *Ordenament constitucional. Constitució* (págs. 31-89). Barcelona: Vicens Vives.

1.1.1. Las alternativas al Estado de derecho, democrático y social

1) La sumisión o no de los poderes del Estado al derecho

La forma de Estado depende en primer lugar de si hay una limitación del poder del Estado ejercida por el derecho, y de si este derecho le impone la obligación de respetar un conjunto de derechos y libertades fundamentales. Si el poder del Estado está limitado por el derecho (y por un derecho con este contenido), estaremos ante un Estado de derecho; si no hay esta limitación jurídica, el Estado será totalitario o autoritario.

- **El Estado de derecho** es el tipo de Estado en el cual el aparato de Gobierno estatal se organiza y sobre todo actúa sometido al derecho, partiendo del principio de división del poder, como mecanismos para asegurar que el aparato estatal respetará una esfera de derechos y libertades. Estos derechos proclamados y garantizados inicialmente solo eran unos derechos individuales (en el Estado liberal de derecho del siglo XIX), pero se fueron ampliando en aquellos estados que aceptaron los principios democráticos (hacia finales del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX) y posteriormente implantaron el Estado social (a partir de la segunda mitad del siglo XX).

Por lo tanto, a pesar de esta evolución, la técnica y el objetivo del Estado de derecho continúan siendo los mismos: la división del poder estatal (para que los poderes u órganos se controlen mutuamente) y la sumisión de todos los poderes del Estado al derecho, como técnicas o instrumentos para conseguir la finalidad de preservar un conjunto de derechos que, como hemos apuntado, han ido evolucionando a partir de ampliar los tipos de derechos y libertades proclamados y garantizados.

- **El Estado totalitario** es aquel en el que el estado somete a su regulación la totalidad de la vida de los individuos de la sociedad y el sistema político absorbe todos los otros subsistemas (que hemos explicado al principio del módulo 1). El Estado totalitario impone una ideología, una cultura, un arte, y quiere encuadrar a los ciudadanos en todas sus actividades privadas y sociales (trabajo, ocio, etc.). Por lo tanto, un Estado es totalitario si, **además de no aceptar limitaciones a su poder, invade todos los ámbitos de la vida personal y social, y le impone sus directrices, actuando con violencia contra los ciudadanos que se oponen a estas directrices**. Esta forma de Estado se podría definir más sintéticamente con la frase que el dictador italiano Benito Mussolini aplicó al Estado fascista: «Nada fuera del Estado. Nada contra el Estado. Todo dentro del Estado».
- **El Estado autoritario** es aquel en el que el aparato de Gobierno tampoco está sometido a unos límites jurídicos que impidan su injerencia en la vida privada y social de los ciudadanos pero, en cambio, a diferencia del Estado totalitario, esta intromisión se produce de manera negativa: el Estado no impone sus directrices (ideológicas, religiosas, artísticas, etc.), pero **prohíbe todas las manifestaciones de la vida privada y social que representen, según su parecer, un peligro o incluso una sencilla crítica de la organización estatal existente**.

2) La participación, o no, de los ciudadanos en el ejercicio del poder público estatal

Lecturas recomendadas

H. Arendt (2006). *Los orígenes del totalitarismo*. Madrid: Alianza.

V. Klemperer (2001). *LTI: La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo*. Barcelona: Minúscula.

G. Orwell (2003). *1984*. Barcelona: Edicions 62.

La segunda de las variables que permiten clasificar las diferentes formas de Estado hace referencia a si los ciudadanos pueden participar libremente en el ejercicio y el control del poder público estatal. Desde esta perspectiva, podemos distinguir entre estados autocráticos y estados democráticos.

- **Hay muchos tipos de estados autocráticos** que no aceptan esta participación de los ciudadanos, **como las dictaduras, que rechazan las elecciones como manera de acceder al poder estatal y las sustituyen por otros procedimientos, como por ejemplo la conquista violenta, la herencia o la cooptación** (sistema de designación en el que quien ejerce un cargo elige a su sucesor). En las dictaduras, los gobernantes no solo no surgen de la elección popular por medio de elecciones libres, plurales y periódicas basadas en el sufragio universal, sino que tampoco están sujetos al derecho ni limitados por los derechos humanos. **En otros casos**, como podía ser el Estado liberal del siglo XIX y lamentablemente todavía en algunos países en el siglo XXI, **se aceptan las elecciones, pero solo se otorga el derecho a voto a una parte muy reducida de la población; e incluso en otros estados se aceptan las elecciones y el sufragio universal, pero se rechaza el pluralismo**, de modo que el elector solo tiene la opción de votar la única lista que se puede presentar a los comicios, votar en blanco o hacer un voto nulo. En todos estos casos, la voluntad del Estado no se forma mediante la participación de los ciudadanos expresada en el marco del pluralismo político, que es el que caracteriza al Estado democrático.
- **El Estado democrático** es el tipo de Estado en el cual los ciudadanos participan (o como mínimo pueden participar) en condiciones de igualdad y en un contexto de pluralismo político en la gestión y el control de los poderes públicos, porque la soberanía corresponde a todos los ciudadanos, y el pueblo (los integrantes de la comunidad política) es la única fuente legítima del poder político. Al contrario de lo que sucede en una dictadura, en una democracia **los gobernantes surgen de la elección popular mediante elecciones libres y periódicas por sufragio popular y son limitados por la existencia del derecho y los derechos fundamentales**. En un Estado democrático, las decisiones estatales tienen que ser resultado de la libre concurrencia de las diferentes alternativas políticas surgidas de los varios sectores e intereses sociales, que son articuladas y expresadas fundamentalmente, pero no de manera exclusiva, por los partidos políticos. **Dentro de este contexto de libertad y pluralidad de opciones, se tiene que producir la participación ciudadana.**

3) La intervención o no del Estado en la vida socioeconómica

Este es el tercer factor del que depende la forma de Estado (la manera de relacionarse el aparato estatal con la sociedad).

Partiendo de este criterio, podemos diferenciar los modelos de Estado abstencionista propios del siglo XIX y los estados intervencionistas, que en la actualidad son casi todos, aunque no en el mismo grado o intensidad ni tampoco con los mismos objetivos. Si en su intervención en el sistema económico, el Estado quiere garantizar unas condiciones de vida suficientes para todos los ciudadanos, o una mayor igualdad entre ellos, estaremos ante un Estado social.

En cambio, no podremos calificarlo así si la intervención del Estado tiene por objeto el desarrollo y la consolidación de unas determinadas clases o sectores socioeconómicos dominantes o el establecimiento de una economía de guerra, como sucedió, por ejemplo, con el tipo de intervencionismo promovido por el Estado nacionalsocialista de Alemania en el periodo nazi. Así, en la primera mitad del siglo XX aparecieron varios regímenes comunistas, corporativistas o fascistas, de vocación totalitaria, que se definieron como socialistas (Unión Soviética) o como sociales (además de la Alemania nazi, la Italia fascista, el corporativismo de Portugal o la dictadura de Franco en el Estado español) y aunque sus objetivos eran diferentes, coincidían en el hecho de que el Estado tenía que controlar la sociedad y la economía. Por lo tanto, **el intervencionismo social del Estado no ha sido privativo de los sistemas democráticos, pero como señala Molas, después de 1945, en la Europa occidental, el intervencionismo estatal en materias económicas y sociales se ha convertido en una realidad derivada directamente del principio democrático.** Así, el Estado intervencionista surgido en Europa después de la II Guerra Mundial es conocido en Gran Bretaña como *Welfare State*, y en Francia como *État Providence*, como expresiones básicamente descriptivas de la tarea asistencial del Estado, pero es en Alemania donde el término Estado social adoptó un contenido jurídico, que contribuyó decisivamente a caracterizar este tipo de Estado como un Estado habilitado para regular la vida económica, dotado de una economía pública y organizador de los derechos sociales (que pueden ser constitucionales o legales) como derechos de prestación. Por lo tanto, el Estado social no es cualquier tipo de Estado que interviene en el orden económico, sino solo aquel en el que se reconocen unos derechos socioeconómicos y el derecho obliga al aparato de Gobierno estatal a intervenir en el sistema económico con el fin de garantizar una igualdad de oportunidades y unas mínimas condiciones de vida a todos los ciudadanos, que conviertan en reales y efectivos sus derechos personales y públicos. Sin embargo, el grado de intensidad de este carácter social no solo varía mucho de un Estado a otro, sino que en un mismo marco constitucional, las diferentes mayorías políticas que logra el Gobierno en cada momento tienen mucho margen para llevar a cabo unas u otras políticas sociales.

Una vez apuntadas las principales formas de Estado alternativas al Estado de derecho, democrático y social, profundizaremos algo más en las bases de cada una de estas formas de Estado, subrayando lo que ya se ha avanzado: no son formas incompatibles, sino plenamente complementarias.

Cuando se dan las tres calificaciones en una misma forma de Estado, como por ejemplo en el art. 1.1 de la Constitución española, la fórmula resultante no constituye solo una simple agregación o yuxtaposición de los tres elementos, sino que origina una nueva forma de Estado en la que estos tres componentes (social, democrático, de derecho) están vinculados entre ellos por relaciones directas e indirectas que necesariamente obligan a reinterpretar sus principios y presupuestos por los de los otros, de modo que el conjunto de la fórmula tiene un alcance normativo distinto de la simple suma de sus elementos integrantes.

1.1.2. El Estado de derecho

Hemos partido de la noción de Estado de derecho como **el tipo de Estado en el que el aparato de Gobierno estatal se organiza y sobre todo actúa sometido al derecho, basándose en el principio de división del poder, como mecanismos para asegurar que el aparato estatal respetará una esfera de derechos.**

La primera concreción histórica del estado de derecho corresponde al Estado liberal del siglo XIX, que garantiza solo unos derechos individuales que tendían a proteger únicamente algunos aspectos de la vida privada de los ciudadanos: además del derecho a la vida, la libertad personal (no ser detenido ni encarcelado arbitrariamente), la propiedad, la libertad ideológica (la llamada libertad de conciencia) o la libertad religiosa. **A finales del siglo XIX (y ya más claramente a principios del XX), en algunos países se consiguió que el derecho al que se sometía el Estado fuera un derecho elaborado con la participación de todos los ciudadanos** y, por lo tanto, se irá generando un ordenamiento jurídico que, además de unos derechos individuales o de autonomía personal, sumaba otros que fomentaban la actuación colectiva de los ciudadanos: los derechos de reunión y manifestación, de asociación y sindicación, de expresión y de información, y evidentemente el derecho de sufragio, que primero fue para todos los hombres y, posteriormente, verdaderamente universal (para hombres y mujeres). **Finalmente, en algunos países la evolución continuó y, a partir de la Primera Guerra Mundial, al Estado democrático de derecho no solo se agregaron una serie de derechos socioeconómicos, sino que la implantación del Estado social también representó una matización o reinterpretación de alguno de los derechos reconocidos por el primer liberalismo** (como, por ejemplo, el derecho de propiedad –limitado por la utilidad pública o el interés social– o el derecho de información, que puede requerir en algunos casos la creación de medios de comunicación públi-

cos que garanticen el pluralismo, asegurando el acceso de los diferentes grupos sociales y políticos). En la mayoría de los países, esta evolución no se produjo «espontáneamente», sino que hay que tener presente que en cada una de las etapas los cambios se lograron con la reivindicación, el esfuerzo y la lucha de unos grupos o clases sociales frente a unas minorías que tenían el poder y que se resistieron a los cambios, a menudo con violencia.

Así pues, el número y el tipo de derechos se han ido ampliando, pero el **objetivo del Estado de derecho** continúa inmutable: **la garantía de un conjunto de derechos** que, en algunos casos, requerirá solo la no injerencia del Estado y, en otros, sobre todo cuando estemos en presencia de un Estado social y democrático de derecho, una acción de garantía o, incluso, de fomento o prestación. Y también continúan siendo básicamente los mismos **los instrumentos para conseguir el objetivo: la división del poder estatal** (para que los poderes u órganos se controlen mutuamente) y **la sumisión de todos los poderes del Estado al derecho**.

El Estado de derecho **tiene su origen en el liberalismo de finales del siglo XVIII y comienzo del XIX**. Las primeras formulaciones teóricas sobre el Estado de derecho se tienen que situar en el primer liberalismo alemán del siglo XVIII, que tiene las raíces en pensadores como Kant, Fichte o Von Humboldt. La expresión concreta «Estado de derecho» (en alemán, *Rechtsstaat*) se atribuye a Robert von Mohl en una obra de 1832. En aquel contexto, **el Estado de derecho era un concepto político de lucha contra el Estado absoluto** (en el que el rey no estaba sometido a las leyes, sino que era *legibus solutus*: no sujeto a las leyes). Como hemos visto en el módulo 1, el poder del monarca en el Estado absoluto podía estar limitado de hecho por el poder de otros estamentos sociales, por la falta de recursos o por ciertos principios religiosos o morales, pero jurídicamente era ilimitado. El rey, y por lo tanto el poder estatal, estaba por encima del derecho, podía actuar sin someterse a ningún procedimiento ni ninguna norma superior que limitase su voluntad; el Estado podía injerirse en cualquier ámbito de la vida personal y social, e imponer cualquier tipo de obligación. Tal y como señala Viver, por un lado, según la utopía liberal la prosperidad y el bienestar individual se consiguen cuando se deja al hombre totalmente libre, independiente para que busque él mismo la prosperidad y felicidad; pero, por otro lado, **a la burguesía liberal le hacía falta romper las trabas económicas y sociales que aún había en el Antiguo Régimen y que ahogaban la expansión del capitalismo** (límites a la libertad de circulación de mercancías y personas, límites a la libertad de contratación, subsistencia de gremios y corporaciones, mantenimiento de los privilegios económicos y sociales concedidos por nacimiento a determinados estamentos sociales, etc.). Es decir, a la burguesía le hacía falta proclamar la igualdad jurídica de todos los ciudadanos (y suprimir los privilegios otorgados a la nobleza) y consagrar una serie de libertades individuales (sobre todo económicas) que limitaran el poder estatal y potenciasen la expansión de la economía capitalista. Sin embargo, **para conseguir esta expansión económica y consolidar su bienestar, esta burguesía liberal tenía bastante con las libertades individuales y era**



El alemán Robert von Mohl (1799-1875), autor de *Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates*, fue un jurista y profesor de ciencias políticas en Tübingen y Heidelberg; sus actividades políticas también lo llevaron a ser diputado, ministro y embajador. Su obra es muy extensa y especialmente importante en la teoría general del Estado, el derecho constitucional comparado y la historia del pensamiento político.

consciente de que los derechos políticos podrían fortalecer la posición de las clases populares, y esto significaría un peligro para su posición privilegiada. En buena parte por esto, **el Estado prácticamente se tenía que limitar a mantener el orden público**: solo tenía que hacer de policía (el Estado-gendarme) y no intervenir en otros asuntos de la vida política, económica y social. Y este Estado tenía que ser gobernado no por un hombre solo (el rey), ni por la nobleza, sino por los más ricos, los que según su parecer, eran los más capacitados para hacerlo. Por lo tanto, por un lado, **la burguesía necesita el Estado, porque es quien tiene que mantener el orden público, pero**, por otro lado, **le tiene miedo porque con su fuerza puede invadir la esfera privada de los individuos; la solución es un Estado mínimo, dedicado fundamentalmente a mantener el orden social y limitado por unos derechos que se proclaman como derechos naturales**, propios de la naturaleza humana y que se consagran en solemnes declaraciones de derechos. Precisamente porque la burguesía liberal teme al Estado, quiere limitarlo y la novedad es que quiere hacerlo sometiéndolo al derecho y, en especial, a la constitución, que acabará incorporando una relación de derechos y libertades de los ciudadanos.

Por lo tanto, desde sus inicios, **el Estado de derecho** era un concepto que propugnaba la sujeción del poder público al Derecho y una organización estatal basada en la razón que garantizase la libertad y la dignidad del hombre. Precisamente porque se trata de una concepción arraigada en principios y creencias liberales, **tiene una dimensión valorativa o material: no todo Estado con derecho es un Estado de derecho**; no toda subordinación del Estado al derecho transforma una organización en un Estado de derecho; **solo merece este nombre el Estado que responde a tres presupuestos**:

- **la proclamación y la garantía de unos derechos y libertades que pertenecen a todas las personas por igual;**
- **la división de los poderes como principio de organización del Estado** (la división del ejercicio de los poderes del Estado entre diferentes instituciones o órganos);
- **la sujeción de la actuación de los diferentes órganos del Estado al derecho** (a la ley y a la constitución).

Así pues, **el Estado de derecho no es cualquier limitación del Estado por el derecho, sino la sujeción a un derecho que tiene un determinado contenido**, porque responde a ciertas convicciones, valores y principios políticos (inicialmente, los del liberalismo político). Por eso, como hemos visto en el módulo 1, la idea se desarrolla en el contexto de las revoluciones liberales de Estados Unidos (1776) y de Francia (1789), y antes en Inglaterra (fruto de una lenta transformación a lo largo del siglo XVII, con un hito importante con la llamada «Gloriosa Revolución» de 1688). Frente al absolutismo, en el que solo algunos hombres podían disfrutar de «privilegios» otorgados por el soberano, o de situaciones de simple «tolerancia», **el liberalismo defiende que los**

hombres disfrutaran de unos derechos que se imponen a los poderes públicos (como la propiedad, la libertad personal, la libertad ideológica o religiosa). Aún más, según la filosofía jusnaturalista, **son unos derechos naturales, innatos, anteriores al Estado**.

Tal y como explica Isidre Molas (*Derecho constitucional*. Madrid: Tecnos, pág. 328), el derecho a la propiedad privada fue un factor inicial determinante del constitucionalismo moderno; la lucha por la limitación del poder provino en gran medida del propósito de evitar la rapiña de los poderosos sobre los bienes y propiedades de los súbditos. Así se impuso el criterio de que solo era legítima la obligación de pagar impuestos cuando así lo habían decidido quienes habían de pagarlos. Y de hecho, los primeros estados constitucionales se basaron en la defensa de la propiedad privada, hasta el punto de que se convirtió en el eje del nuevo sistema político, que se organizó como una «democracia de los propietarios» mediante la instauración del sufragio censatario. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789 llegó a declarar el derecho a la propiedad «sagrado e inviolable» (art. 17).

El Estado de derecho, en sus inicios, se fundamenta en una concepción de la vida política según la cual **se entendía que era posible limitar racionalmente el poder estatal mediante el derecho**, con el fin de respetar la dignidad, la libertad y la igualdad natural de todos los seres humanos, **por lo que había que equilibrar los poderes públicos**, eligiendo popularmente como mínimo uno, el parlamento (que hace la ley, que es superior a las decisiones de los otros poderes estatales, y en todo caso, solo subordinada a la constitución). **La idea del necesario equilibrio de los poderes fue formulada por primera vez por John Locke y desarrollada posteriormente por Montesquieu**.

En el siglo XVII, Locke, el padre del liberalismo británico, propugnaba la distinción entre un poder legislativo (hacer leyes y juzgar), un poder ejecutivo (ejecución de la ley apoyada por la fuerza) y un poder federativo (mantener relaciones exteriores). Locke no pensaba propiamente en una separación de poderes, sino en una intervención de los diferentes sectores sociales en el Gobierno partiendo del equilibrio, si bien con una cierta supremacía del parlamento. La idea de equilibrio fue recogida en Inglaterra en el siglo XVIII con la teoría de los *checks and balances*, es decir, los controles y equilibrios mutuos entre poderes que tienen como finalidad la libertad.

Montesquieu se inspiró en estas formulaciones y en la realidad constitucional de Inglaterra a la hora de concebir su teoría de la división de poderes, expuesta en la obra *Del espíritu de las leyes* (1748). Influido por la idea de equilibrio, Montesquieu parte de la necesidad de dividir el poder para garantizar la libertad. Por eso, distingue tres funciones del Estado: el poder legislativo (encargado de elaborar leyes), el poder ejecutivo (poder coactivo que asegura la paz interior) y el poder judicial (le corresponde castigar los delitos y resolver las diferencias entre particulares). Montesquieu hace corresponder cada poder a un sector social: el legislativo a la burguesía y la aristocracia (cámara baja y cámara alta), el ejecutivo al rey, y el judicial, que Montesquieu no consideraba propiamente un poder, a unos jueces elegidos anualmente por los ciudadanos. Estos tres poderes tenían que estar, según Montesquieu, separados, pero vinculados por un sistema de correctivos y vetos que darían lugar a una cierta independencia.

Pese a las críticas que en el siglo XVIII suscitaron estas teorías (teoría de la constitución equilibrada, de la constitución mixta o forma mixta de Gobierno), **las revoluciones liberales norteamericana y francesa proclamaron el principio de separación de poderes**, si bien las diferentes situaciones sociales y políticas de cada país hicieron que **su concreción fuera distinta: en el régimen presidencial, separación de poderes; en el régimen parlamentario, colaboración de poderes**.

Tal y como remarcan Fossas y Pérez Francesch, **la formulación originaria del principio de división de poderes se ha visto superada en muchos aspectos por las profundas transformaciones por las que ha pasado el Estado desde el siglo XVIII: la desaparición de grupos sociales con fuerza política (nobleza, aristocracia) y la radicación de la soberanía en el pueblo; el incremento de la complejidad del Estado en cuanto a sus órganos y funciones; la superposición del sistema de partidos, que diluye la separación desde el punto de vista de la dirección política; el cambio sustancial en cuanto al peso del poder judicial, y la aparición y consolidación de la justicia constitucional. Todos estos fenómenos han llevado a nuevas formulaciones del principio de división de poderes, que ya no se limita a la tripartición de órganos y funciones de Montesquieu, sino que actualmente se pone de manifiesto en una mayor pluralidad de divisiones del poder, porque, además de un legislador, un ejecutivo y un poder judicial, la mayoría de las constituciones crean otros órganos que incrementan la complejidad de la estructura de los poderes constituidos. Pero, además, algunos de estos órganos no tienen una única función, ni las que llevan a cabo son exclusivas de ellos y, por lo tanto, con frecuencia hace falta la participación de varios órganos en la realización de una función, lo que genera un complejo entramado de relaciones, controles y contrapesos. Además de todas estas consideraciones en relación con la *división horizontal* de los poderes, en la actualidad hay muchos estados que se han estructurado territorialmente como estados compuestos (de tipo federal, regional o autonómico) que, como veremos más adelante, incorporan también una *división vertical* de los poderes. Por lo tanto, hay que coincidir con Fossas y Pérez Francesch en el hecho de que a pesar de la superación de las formulaciones iniciales de Locke y Montesquieu, el postulado de la división de poderes constituye todavía hoy una premisa ineludible del Estado de derecho: solo cuando el poder del Estado está dividido y repartido entre varios detentores que se limitan y controlan recíprocamente, puede ser efectiva la sujeción de los poderes al derecho y la garantía de unos derechos y libertades.**

También hoy día continúa siendo un pilar básico del Estado de derecho la sujeción de la actuación de las diferentes instituciones y órganos del Estado a la ley y a la constitución. Actualmente, los mecanismos que quieren asegurar la subordinación del Estado al derecho pueden ser internos a la Administración (mediante, por ejemplo, el control jerárquico u organismos de control interno) o externos al aparato administrativo; y en este caso, pueden ser de tipo político (el control parlamentario), institucional (como, por ejemplo, los *ombudsmen*) o jurisdiccional (órganos judiciales y órganos de control de la constitucionalidad), que en nuestro sistema jurídico occidental son los principales para asegurar la sumisión de la Administración al derecho. Los mecanismos de control son numerosos y se complementan mutuamente, pero tienen en común el objetivo de hacer efectivos una serie de principios básicos, como el de constitucionalidad y legalidad, que tienen como consecuencia la jerarquía normativa, la prohibición de la arbitrariedad y la responsabilidad de los poderes públicos, y un objetivo final: la seguridad jurídica, que representa una certeza sobre la norma jurídica aplicable (predictibilidad de

Lectura recomendada

E. Fossas Espadaler; J. Ll. Pérez Francesch (1994). «La forma d'Estat (I): l'Estat de Dret». En: *Lliçons de dret constitucional* (1.ª ed., págs. 119-128). Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

la norma) y **una previsibilidad de la interpretación y aplicación del derecho por los poderes públicos, especialmente la Administración y los jueces**. Solo si hay seguridad jurídica, los ciudadanos pueden ejercer plenamente sus derechos y defenderlos adecuadamente. **Esta previsibilidad implica la publicidad de las normas** (es decir, la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer las normas jurídicas porque tienen que ser publicadas en los diarios o boletines oficiales). El derecho oculto o secreto es incompatible con el Estado de derecho. **La seguridad jurídica también supone, lógicamente, la prohibición de la retroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos**, sencillamente porque si no existían estas normas, no podían ser conocidas por los ciudadanos en el momento de actuar (es imposible adecuar una conducta a una norma que no se conoce porque todavía no existe o no se ha publicado). La seguridad jurídica es el concepto que resume todo aquello que se busca con el Estado de derecho: evitar la arbitrariedad y someter a responsabilidad las actuaciones contrarias al derecho.

De todo el conjunto de principios dirigidos a hacer efectiva la supremacía del derecho sobre los órganos estatales y a garantizar la seguridad jurídica, **los dos más importantes son el principio de legalidad y el de constitucionalidad**, que en algunos ordenamientos se considera que conforman el denominado principio de juridicidad.

- **El principio de legalidad implica la vinculación de los diferentes poderes del Estado a la ley**, entendida como norma general aprobada por el parlamento, que es el órgano que representa al pueblo; significa que **la Administración, en su actividad diaria, tiene que respetar lo que está establecido en las normas jurídicas** y especialmente en la ley, de modo que si un ciudadano considera que la Administración ha actuado al margen de la legalidad vigente, puede impugnar estos actos o normas reglamentarias ante los tribunales de justicia, que si consideran que la impugnación tiene fundamento, anularán o dejarán sin efecto la actuación administrativa. El principio de legalidad tiene dos versiones, dependiendo de cómo se entienda que la ley condiciona la actuación de los poderes públicos:
 - **la versión inicialmente francesa, que entiende la ley como el fundamento previo de cualquier actuación administrativa** y que implica una vinculación positiva de los poderes a la ley: **aquello que la ley no permite expresamente a los poderes públicos, les está prohibido**;
 - **la versión germánica, en la que la ley no es el fundamento sino tan solo un límite a la actividad de los poderes públicos** (solo los vincula negativamente): **les está permitido todo lo que la ley no prohíbe**.
- **El principio de constitucionalidad implica la sujeción de todos los poderes del Estado a la constitución**, en los ordenamientos que tienen la constitución como norma suprema (que como hemos visto en el módulo 1, son la gran mayoría actualmente). **Significa, en primer lugar, la vincu-**

lación del poder legislativo a la constitución, tanto desde el punto de vista formal (el legislador tiene que respetar las normas constitucionales que establecen el órgano y los procedimientos para la aprobación de las leyes) **como material** (el legislador no puede contradecir los contenidos constitucionales, porque esto representaría una modificación de la constitución y esto solo se puede hacer siguiendo los procedimientos previstos en la misma constitución). Tal y como hemos visto también en el módulo 1, la sujeción del legislador se garantiza mediante los procesos de inconstitucionalidad que se siguen en uno u otro órgano según el modelo de justicia constitucional que haya adoptado cada Estado. Sin embargo, el principio de constitucionalidad es más amplio que la constitucionalidad de las leyes, porque **el resto de los poderes del Estado también quedan vinculados a la Constitución** y, por eso, las normas inferiores a ley y los actos administrativos están sujetos a la constitución y pueden ser anulados cuando la contradigan. Y, especialmente, los jueces están sujetos a la constitución porque independientemente de que puedan inaplicar una ley o solo cuestionarla al órgano con potestad para anularla (según se trate de un sistema difuso o concentrado de justicia constitucional), **el principio de constitucionalidad obliga los jueces a interpretar todo el ordenamiento jurídico en conformidad con la constitución** (como también se ha explicado en el módulo 1).

Actualmente, pues, **el elemento clave del Estado de derecho es la eficacia real de sus postulados teóricos**. Así, a pesar de que un Estado pueda ser calificado en una constitución como Estado de derecho, lo realmente decisivo para que merezca este nombre es que en la práctica aquel Estado se comporte como tal, es decir, que en el día a día se apliquen los tres presupuestos del Estado de derecho: que haya una división de poderes (horizontal y vertical) que no sea solo teórica sino real, y que, por lo tanto, no haya ni una judicialización de la política (que los jueces abusen de su poder para entrar en temas que son propios de la dialéctica política) ni una politización de la justicia (que los gobernantes interfieran en las decisiones o en los nombramientos de los órganos de Gobierno de los jueces y los altos órganos jurisdiccionales eligiendo a personas no por sus méritos profesionales, sino por razones de afinidad política); que todo el mundo esté sometido al derecho y, por lo tanto, que nadie esté por encima de la ley, por muy importante que sea el cargo que ocupe o por potente que sea su posición económica, y que los jueces también estén sometidos a la ley y a la constitución y no retuerzan la ley para hacerle decir lo que no dice; y que se puedan ejercer con plenitud todos los derechos fundamentales (incluidos aquellos que más puedan incomodar o inquietar al poder) y que encuentren amparo efectivo cuando excepcionalmente pueda haber alguna vulneración de estos derechos. Por lo tanto, en un Estado de derecho puede haber algunos casos aislados en los que no se haya respetado alguno de estos presupuestos, pero debe haber una respuesta jurídica que repare el mal funcionamiento; **a la hora de calificar un estado como Estado de derecho, no basta con ver si su constitución así lo prevé, sino que hay que examinar la realidad cotidiana de aquella sociedad para ver si efectivamente se**

dan o no los tres requisitos básicos que caracterizan el Estado de derecho. Hay informes elaborados periódicamente por organismos no gubernamentales, tanto de ámbito estatal como supraestatal, que evalúan varios aspectos relacionados con el Estado de derecho, como por ejemplo las violaciones de los derechos humanos, la independencia judicial o la corrupción institucional, y que pueden ser un indicador del nivel de efectividad de la división de poderes, la sujeción de los poderes al Derecho y la garantía de los derechos y libertades fundamentales, es decir, del Estado de derecho.

1.1.3. El estado democrático

Hemos avanzado la noción de Estado democrático como **el tipo de Estado en el cual los ciudadanos participan** (o como mínimo pueden participar) **en condiciones de igualdad y en un contexto de pluralismo político en la gestión y el control de los poderes públicos, porque la soberanía corresponde a todos los ciudadanos, y el pueblo** (los integrantes de la comunidad política) **es la única fuente legítima del poder político.** Frente al lema del despotismo ilustrado de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», la **democracia significa gobierno del pueblo. Su objetivo es que el pueblo se gobierne a sí mismo.** Abraham Lincoln sintetizó esta idea de democracia en una expresión que ha hecho fortuna: *government of the people, by the people and for the people* (el gobierno del pueblo, *por* el pueblo y *para* el pueblo). El término *democracia* viene del griego, de las palabras *δημος* (*demos*), que quiere decir pueblo, y *κρατία*, de la raíz de *κρατω* (*krátos*), que se puede traducir como fuerza, dominio o poder. En un Estado democrático **todos los integrantes de la comunidad política pueden participar igualmente en la adopción de las decisiones que afectan a la comunidad.**



La frase *government of the people, by the people and for the people* forma parte del muy breve Discurso de Gettysburg, el más famoso de los discursos de Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos (1861–1865), pronunciado durante la inauguración del Cementerio Nacional de Soldados de Gettysburg, el 19 de noviembre de 1863, en plena Guerra Civil de Estados Unidos.

Tal y como sintetiza Isidre Molas, **si todos los ciudadanos pudiésemos deliberar conjuntamente y llegar a un mismo criterio y, por lo tanto, coincidir en la decisión que hay que tomar en cada asunto, la decisión podría basarse únicamente en la regla de la unanimidad;** sin embargo, muy pocas veces esto es posible. **Las dimensiones físicas** (territoriales y poblacionales) **de los estados contemporáneos y el pluralismo social y político inherente a las sociedades libres no permiten llegar a la unanimidad en la mayoría de los casos. Por lo tanto, para adoptar decisiones legítimas, hay que adoptar un criterio sustitutivo:** después de la correspondiente deliberación (debate), y en defecto de la unanimidad, la mayoría decide. **Es la regla de la mayoría. La democracia se basa, pues, en dos grandes reglas: la búsqueda del gobierno por consenso y, en defecto de este consenso, la organización del gobierno por mayoría.** Por lo tanto, **de las dos reglas se deduce que la deliberación previa, el debate, es imprescindible** (para conseguir un consenso más amplio o para intentar, si fuera posible, la decisión por unanimidad). Ahora bien, si la decisión unánime no se produce, **es preciso que las minorías resultantes acepten la legitimidad de la decisión de la mayoría. Por eso, hay que asegurar unos límites a la mayoría y unos derechos a la minoría; básicamente, el derecho de existir como minoría, es decir, no solo la garantía de no ser**

aniquilados (física o políticamente) sino **el derecho de opinar, de participar en condiciones de igualdad en el debate público y, por lo tanto, el derecho de poder convertirse en mayoría**, de la manera que se hace en democracia, **convenciendo**. Este es también un elemento clave en una democracia: la minoría debe tener garantizada su participación en la deliberación antes de la decisión, para tener posibilidades de convencer y pasar a ser mayoría.

Ahora bien, **para que las minorías acepten la legitimidad de la decisión de la mayoría, hace falta una condición previa**, que se podría considerar una obviedad si no fuera porque todavía en la actualidad, en muchos países no se tiene lo bastante en cuenta: antes de que la democracia estructurada se pueda ejercer es preciso que haya una conciencia generalizada de que **se forma parte de una misma comunidad y que se quiera** (igualmente, de manera generalizada) **la continuidad política de esta comunidad**. Aquí hay un elemento fundamental (porque afecta profundamente a la base misma de la democracia) que es anterior al hecho de que pueda ser válida la regla de la mayoría. La aplicación legítima de la regla de la mayoría requiere una sociedad que consiente (o no cuestiona) convivir en una unidad política (que internamente puede incluir varias etnias, razas, religiones, nacionalidades, etc.). Si en un Estado hay varias naciones (culturales o sociales, tal y como se han definido en el módulo 1) y una o más de una de estas naciones mayoritariamente no quieren continuar formando parte de aquel Estado, falla el presupuesto básico de la democracia, el respeto a la voluntad del pueblo. En estos estados **puede suceder que algunas minorías nunca acepten la decisión de la mayoría: porque no se consideran una minoría dentro de un pueblo, sino otro pueblo que está permanentemente en minoría dentro de un Estado** (una minoría tendencialmente permanente, en terminología de Pizzorusso). En un Estado que de hecho sea plurinacional, los intereses generales de alguna de estas naciones pueden ser no solo diferentes, sino contradictorios con los de la nación mayoritaria o los del Estado. Si la democracia se basa en el gobierno del pueblo, si hay más de uno, lo ideal sería el consentimiento previo de todos ellos para crear la comunidad política donde se aplicará la regla de la mayoría, pero, tanto si se dio o no este pacto en el momento fundacional, en cada momento de la historia hace falta que, como mínimo, ninguno de los pueblos mayoritariamente cuestione la existencia misma del Estado. Es contrario a la democracia obligar a un pueblo a vivir en una unidad política de la que mayoritariamente no quiere formar parte. Este es un elemento fundamental que permite analizar hasta qué punto una democracia es real o solo formal, y es uno de los retos importantes teniendo en cuenta que, hoy día, la mayoría de los estados son, de hecho, plurinacionales. Como veremos más adelante, el establecimiento de diferentes tipos de Estado compuesto (como el federal, el regional o el autonómico) puede ser una fórmula válida para la buena convivencia en algunos estados plurinacionales.

En un plan meramente jurídico, lo que podría garantizar la existencia y la acomodación de una nación minoritaria (especialmente cuando constituye una mayoría en su subunidad territorial) dentro de un Estado plurinacional es la combinación de tres factores:

Lectura complementaria

A. Pizzorusso (1993). *Minoranze e maggioranze*. Turín: Einaudi.

Lecturas complementarias

F. Requejo (1998). *Federalisme, per a què?* Valencia: Edicions 3 i 4.

W. Kymlicka (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.

- conseguir que el Estado se base en una política de reconocimiento de su plurinacionalidad, regulando los efectos en los ámbitos simbólico, lingüístico, representativo e institucional;
- conseguir que se articule un autogobierno nacional pleno (es decir, que las decisiones más importantes para aquella nación se tomen en las instituciones políticas autóctonas, con la excepción de las que hayan sido delegadas por estas últimas), y
- establecer unos mecanismos eficaces de participación en los órganos que fijan la voluntad general del Estado, que permitan compartir la dirección del mismo. Todo esto es teóricamente posible, si así lo aceptan honesta y lealmente todas las partes.

Una vez apuntada esta condición previa, y volviendo a la noción inicial de democracia, hay que remarcar que **el Estado democrático incorpora los presupuestos del Estado de derecho y añade tres elementos nuevos que lo definen:**

- **la soberanía popular** (que implica el sufragio universal);
- **el reconocimiento y la garantía del pluralismo** de la sociedad, y muy especialmente del pluralismo político, y
- **la participación política**, ejercida directamente mediante mecanismos como el referéndum o la iniciativa legislativa popular, o por medio de la elección libre y periódica de representantes.

Estos son los tres grandes pilares en los que se basa el Estado democrático, sus tres grandes elementos definidores. Sin embargo, antes de comentar cada una de estas ideas, hay que subrayar que no es posible un verdadero Estado democrático sin los presupuestos del Estado de derecho, y muy especialmente sin derechos, sin libertades personales: porque los derechos son indispensables para que todos los ciudadanos puedan participar en condiciones de igualdad, con su propio criterio, en la vida colectiva; por eso, la democracia implica la búsqueda de la igualdad en las condiciones de libertad (I. Molas).

1) La soberanía popular y el sufragio universal

Es el primero de los tres grandes pilares en los que se basa el Estado democrático. En el módulo 1, definimos la soberanía como el tipo de poder político que no está sometido a ningún otro poder y, por lo tanto, en su vertiente exterior es independiente de cualquier otro y, en la vertiente interior, es supremo. La soberanía no la tiene el monarca ni una aristocracia o una oligarquía, sino que el poder supremo de la comunidad corresponde a todos los ciudadanos. **En democracia, el poder emana y radica en el pueblo.** En este sentido, ya hemos destacado que en democracia **el pueblo es la única fuente legítima de poder político.** Y esto significa que los órganos estatales no son soberanos, sino que se tienen que limitar a ejercer las competencias que el pueblo soberano les atribuye por medio del ordenamiento jurídico y, en especial, de la constitución.

En los estados democráticos que han adoptado un concepto racional-normativo de constitución, en un primer momento la soberanía se concreta en la capacidad de ejercer el poder constituyente, es decir, el poder de hacer y aprobar una constitución, que es la que define unos poderes constituidos (parlamento, gobierno, poder judicial) que encuentran su referencia última en el pueblo. A partir de aquí, **la participación de los ciudadanos requiere el establecimiento de una serie de derechos entre los cuales destaca especialmente el derecho de sufragio universal, sin cuya existencia no se puede hablar propiamente de democracia.** En democracia, el derecho de sufragio activo (poder votar) y pasivo (poder ser votado, ser candidato) es un derecho de todos los ciudadanos, de los integrantes de la comunidad política. La soberanía popular implica que todos los individuos de aquel pueblo tienen una parte de la soberanía y todos tienen derecho (como soberanos que son) a participar en el gobierno de la comunidad.

Históricamente, no siempre ha sido así.

La democracia es un concepto que ha ido evolucionando. En la Grecia clásica o en los primeros años de la fundación de Estados Unidos, lo que llamaban democracia era compatible con la esclavitud de una parte de la población. Asimismo, hasta hace muy pocas décadas, los estados considerados democráticos se basaban en el sufragio universal masculino, que excluía a las mujeres del derecho de sufragio, como anteriormente se había excluido a la mayoría de la población masculina, estableciendo un sufragio restringido (a los hombres que tenían capacidad económica o un determinado nivel de instrucción). Hoy ya no se puede calificar de democrático un Estado en el que no esté reconocida la soberanía popular y, por consiguiente, el derecho de sufragio universal.

Al principio del liberalismo, para la mayoría de los autores, el sufragio universal no solo ponía en peligro la posición lograda por la burguesía, sino que minaba las bases de su sistema social y económico, y llevaba directamente a la revolución social. Consideraban el sufragio universal y el socialismo una misma cosa con nombres diferentes; veían el sufragio universal y la propiedad como antitéticos, porque creían que «el objetivo de los no propietarios es llegar a la propiedad» y que a los derechos personales y las libertades económicas no se tenían que añadir los derechos políticos (principalmente, el derecho de voto), porque «estos derechos en manos de la mayoría servirán infaliblemente para invadir la propiedad» (Benjamin Constant). La justificación liberal del rechazo al sufragio universal (y, por lo tanto, de la democracia y la soberanía popular) se argumentaba a partir de la teoría de la soberanía de la nación. No consideraban soberano (fuente y origen del poder) al pueblo (entendido como la suma de todos y cada uno de los individuos), sino la nación, entendida como un ente abstracto, con vida propia diferente de la de los individuos concretos que la formaban. Y para expresar la voluntad de la nación, no hacía falta en absoluto la participación de todos los ciudadanos, sino, al contrario, los únicos que estaban capacitados para hacerlo eran los propietarios (especialmente, los propietarios agrícolas con grandes extensiones de tierra que les daban rentas suficientes para vivir sin tener que trabajar), por la sencilla razón de que eran quienes podían estar más preparados, quienes tenían más «luces» (en expresión de la época), porque eran los únicos que disponían de tiempo para cultivar las cualidades necesarias para expresar la voluntad de la nación. En palabras de Constant:

«La propiedad es la única que proporciona el ocio indispensable para la adquisición de las luces y de la rectitud de juicio; por consiguiente, solo ella hace que los hombres sean capaces de ejercer los derechos políticos.» B. Constant (1820). *Curso de política constitucional* (pág. 173). Madrid: Imprenta de la Compañía, consultable en la Biblioteca Digital Jurídica de la Universidad de Sevilla.

Para el liberalismo de la primera época, el procedimiento más eficaz para apartar a las clases «no propietarias» de la gestión pública consiste en negar el derecho de sufragio universal y establecer en su lugar el sufragio

restringido o censitario, que se otorgaba solo a la minoría que figuraba en el censo de contribuyentes con una determinada suma de impuestos; una minoría que oscilaba, dependiendo de los países y de la época, entre un 3 % y un 5 % de la población, y en algunos casos no llegaba ni al 1 %. Este sufragio censitario de los mayores contribuyentes a veces se completaba con el sufragio de capacidades (de aquellos que tenían estudios superiores). Han tenido que pasar muchos años, y muchas luchas y reivindicaciones, desde el sufragio censitario o restringido (de finales del siglo XVIII y de todo el siglo XIX), pasando por el sufragio universal masculino, hasta llegar a principios del siglo XX (en algunos países avanzados) al sufragio verdaderamente universal (masculino y femenino).

El art. 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que:

- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
- Toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a acceder a las funciones públicas de su país.
- La voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad del Estado; esta voluntad tiene que expresarse mediante elecciones auténticas, que tendrán que hacerse periódicamente por sufragio universal, e igual y por voto secreto o por otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

En un sistema de gobierno democrático, **el sufragio, además de universal, tiene que ser:**

- **Personal:** debe expresar la voluntad del votante; no es posible la delegación.
- **Libre:** hay que garantizar que no haya coacciones en el momento de la emisión del voto, pero también que se den las máximas condiciones posibles de libertad de expresión y propaganda en la fase de formación de la voluntad del votante.
- **Igual:** cada ciudadano posee un solo voto que tiene idéntico valor; aun así, en algunos estados esto no significa que el voto de todos «pese» exactamente lo mismo, porque aunque hayan adoptado fórmulas proporcionales, en algunos sistemas electorales subsiste un reparto irregular de los escaños que hay que elegir entre las diferentes circunscripciones, que implica que algunas zonas estén sobrerrepresentadas y otras, infrarrepresentadas.
- **Directo:** la elección se tiene que hacer directamente sobre los candidatos que aspiran a realizar la función representativa.

Aun así, la elección presidencial de Estados Unidos, por ejemplo, es técnicamente por sufragio indirecto porque se elige a unos miembros del Colegio Electoral (538 electores, desde 1964), que son los que votarán al presidente y el vicepresidente, pero que en la práctica, mayoritariamente, tienen comprometido su voto por uno de los candidatos; en

las elecciones de 2016, el candidato Donald Trump fue elegido por una mayoría de 304 compromisarios de los Colegios Electorales, pero su principal adversaria (Hillary Clinton) obtuvo en el conjunto del país casi 3 millones más de votos de los ciudadanos.

- **Secreto:** es una garantía de la libertad de emisión del voto, que quiere evitar las presiones o las posibles represalias por el sentido del voto. Los medios más comunes para garantizar el secreto son la cabina electoral, las papeletas oficiales y uniformes, la existencia de sobres, las urnas selladas y la introducción de la papeleta en la urna por el propio elector o por un miembro de la mesa electoral. El voto electrónico también puede garantizar el secreto del voto.

2) El reconocimiento y la garantía de la expresión del pluralismo de la sociedad, y muy especialmente del pluralismo político

El segundo presupuesto de la democracia es el **pluralismo**, que es **producto de la libertad**, y por lo tanto ha aflorado siempre que ha habido libertad. **Por eso hay que entenderlo como un valor, como una riqueza**; en democracia, el reconocimiento y la expresión del pluralismo son un valor que no solo hay que proteger, sino fomentar. Las dictaduras lo tienen claro, y es a menudo lo primero que hacen: eliminar cualquier discrepancia, intentar eliminar o reducir la diversidad, suprimir el pluralismo o, como mínimo, la expresión del pluralismo.

Es **preciso no confundir la diferencia con la desigualdad**. La desigualdad no justificada es discriminación y es rechazable para un demócrata; la diferencia, en cambio, tiene que ser la base de la democracia (I. Molas). La misma regla de la mayoría implica la existencia de mayoría y minorías, de diversidad. El debate libre, la deliberación a partir de la expresión de todas las opiniones, y la decisión de la mayoría es la fórmula de la democracia. **La diversidad en la sociedad** no solo es un hecho real, sino un hecho positivo, porque es **manifestación de la libertad**. Si el **pluralismo** es el fundamento, la base, de la democracia, **debe tener medios garantizados para expresarse**. En cualquier sociedad, hay grupos con intereses diferentes y a veces contrapuestos. Y aquí es donde está **la gran dificultad de la vida en democracia: encontrar fórmulas para integrar estos intereses distintos o contrapuestos** (o contradictorios).

Por eso, en democracia son fundamentales la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de asociación. Sin libertad de expresión y de información no habría debate público, que hemos visto que es imprescindible para las dos reglas básicas de la democracia: tanto para la búsqueda del consenso como para el surgimiento de una decisión mayoritaria. Sin debate no habría opinión pública libremente formada, que es la base del sistema representativo. Otro de los elementos básicos del Estado democrático es el reconocimiento a los individuos del derecho a asociarse

libremente con otros que tengan intereses afines. Las asociaciones que crean son el medio principal para canalizar la representación de sus intereses ante la sociedad y ante el Estado.

Tal y como señala Isidre Molas, en Europa el reconocimiento del derecho fundamental de asociación fue más tardío que el de las libertades del ámbito privado y estuvo directamente conectado al avance de la idea democrática. La prohibición de los «cuerpos intermedios» entre el individuo y la nación que hizo la Revolución Francesa mediante la Ley Le Chapelier (1791) tendía tanto a la destrucción de la organización señorial como a la defensa del individualismo, y su ejemplo fue adoptado como guía por los primeros estados liberales. Las asociaciones quedaban sometidas a la ley y al Gobierno y, por lo tanto, a las restricciones que pudiera imponer la mayoría, y quedaban también supeditadas a un régimen de situaciones excepcionales que permitía al Estado no autorizarlas, suspenderlas o disolverlas y, con esto, hacer frente a los desafíos populares. La incorporación de los ciudadanos a la vida colectiva y la necesidad de su intervención política por medio de sujetos colectivos provocaron en una primera etapa el reconocimiento legal de los partidos y sindicatos y, posteriormente, la aparición del derecho de asociación como derecho fundamental indispensable en democracia (I. Molas, *Dret constitucional, op. cit.*, pág. 322).

En democracia, **el pluralismo político se expresa hoy principalmente por medio de los partidos políticos, que se han convertido en los verdaderos sujetos del proceso político porque llevan a cabo dos funciones importantes:** contribuyen a agregar las diferentes preferencias individuales en pocas alternativas generales contenidas en programas (**función agregativa**), y seleccionan a los equipos dirigentes que defenderán intereses, valores o creencias de los ciudadanos y orientarán la opinión pública (**función selectiva**). Sin embargo, a pesar del papel fundamental que desarrollan desde hace más de un siglo en el proceso político, **el reconocimiento constitucional de los partidos políticos es reciente.** Primero aparecieron de hecho, a finales del siglo XIX, y tardaron en ser reconocidos por el derecho. El primer liberalismo tenía una hostilidad abierta a los partidos (a los cuales denominaba *facciones*), porque rechazaba la idea de grupos interpuestos (cuerpos intermedios) entre el individuo y el Estado, aunque pronto los admitió como grupos parlamentarios; posteriormente, con la conquista democrática del derecho de asociación, se empezó a reconocer su existencia legalmente (en especial, en las leyes electorales), pero **la constitucionalización de los partidos políticos no llegó hasta después de la Segunda Guerra Mundial.** Así, a partir de 1945, las constituciones democráticas han ido **regulando** los partidos políticos, determinando **algunas de sus funciones** en el sistema político y, **al mismo tiempo, exigiéndoles determinadas características** (básicamente, una organización y un funcionamiento democráticos).

La Constitución italiana de 1947 (art. 49) fue la pionera en la constitucionalización de los partidos políticos, y después vinieron la Ley fundamental de Alemania de 1949 (art. 21), la Constitución de Francia de 1958 (art. 4), la griega de 1975 (art. 29), la portuguesa del 1976 (art. 47) o la española de 1978 (art. 6), entre muchas otras.

El pluralismo de una sociedad democrática no se manifiesta solo en el pluralismo político, canalizado básicamente por los partidos políticos, sino también en el reconocimiento del pluralismo social, que incluye siempre, como mínimo, diversidad ideológica, de género, asociativa, profesional, de clase o de orientación sexual, y a menudo también diversidad nacional, lingüística,

religiosa, etc. Estas últimas son formas de pluralismo social que en el pasado a menudo habían sido negadas e, incluso, perseguidas con la voluntad de erradicarlas para construir estados más homogéneos basados en una sola nación, religión o lengua. El Estado democrático necesita una sociedad democrática. Si la sociedad no lo es, difícilmente lo será su sistema político. Sin embargo, en la sociedad hay poderes que actúan con criterios e intereses privados que pueden resultar antagónicos con la democracia política y el interés general. **Un Estado democrático solo se puede asentar en una sociedad democrática, donde las personas y los grupos no se encuentren en situaciones de tal desigualdad que su libertad quede limitada o sea solo teórica;** un Estado democrático requiere ciudadanos que puedan participar en la vida colectiva en condiciones de igualdad. Y en este sentido, tanto el Estado como la sociedad pueden estar en un proceso de permanente democratización. Si entendemos la democracia como un ideal, el Estado democrático será siempre mejorable, siempre perfectible: porque siempre puede haber más y mejor expresión del pluralismo, no solo político, sino en todos los ámbitos de la sociedad, y más igualdad de oportunidades a la libertad y, como veremos a continuación, más participación y de más calidad, más transparencia en la actividad de los poderes públicos y más control y responsabilidad de estos poderes.

3) La participación política

Es el tercer gran pilar en el que se basa la democracia. En un Estado democrático, **los ciudadanos tienen que poder participar en la gestión y control de los poderes públicos en un contexto de libertad y pluralidad de opciones.** Ahora bien, esta participación, teóricamente, podría darse en un modelo de democracia directa o bien de democracia representativa.

Para diferenciar la democracia directa de la representativa, nos tenemos que fijar en dos aspectos del poder: la titularidad y el ejercicio. **En la democracia directa, hay identidad entre la titularidad y el ejercicio del poder:** la titularidad del poder corresponde a todos (pueblo) y el ejercicio del poder también correspondería a todos. **En cambio, en la democracia representativa no todos los titulares ejercen el poder:** la titularidad del poder corresponde a todos (pueblo), pero el ejercicio del poder solo se atribuye a unos pocos, a unos representantes, elegidos por el pueblo.

En el modelo de democracia directa, nunca hasta ahora efectuada en la práctica, la aspiración máxima sería que todos los ciudadanos tomaran constantemente todas y cada una de las decisiones que afectan a la comunidad ¹. **Sin embargo, en unos estados como los actuales, se hace muy difícil, si no imposible, aplicar radicalmente la democracia directa,** no solo por la extensión de la mayoría de los estados, sino por el número y la complejidad de los problemas que hay que resolver; además, este modelo no es un ideal

⁽¹⁾ Algunos autores hablan de la Grecia clásica como un sistema en el que se practicó la democracia directa, aunque fuera parcialmente, pero no se puede olvidar que la participación solo estaba al alcance de una minoría, los ciudadanos, y que las mujeres eran como eternas menores que, a diferencia de los extranjeros y los esclavos, nunca podían convertirse en ciudadanas.

compartido por todo el mundo, porque ejercer de ciudadano implicaría una dedicación de tiempo y de energía muy grande, que necesariamente se tendría que sacar de la vida privada de cada cual.

En el modelo de democracia representativa, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos se articula básicamente por medio de representantes elegidos de manera periódica en elecciones libres. Sin embargo, como complemento, en la mayoría de las constituciones democráticas se establecen una serie de mecanismos de participación directa o semidirecta de los ciudadanos en el ejercicio del poder público, como por ejemplo el referéndum, la iniciativa legislativa popular o el derecho de petición². Ahora bien, más allá del uso más o menos intensivo y profundizado de estos mecanismos, que varía mucho de un estado al otro, entre el modelo de democracia directa, en el que todo el mundo decide sobre todo, y la democracia representativa, en el que los ciudadanos se limitan a elegir periódicamente a unos representantes, hay toda una gradación en la cual **es posible avanzar mucho en la cantidad y la calidad de la participación** (democracia participativa), seguramente en un avance inacabable, como es propio de un ideal. Así, gracias a la tecnología, cada vez es más fácil el acceso de los ciudadanos a la información pública relevante y confiable, y por lo tanto la transparencia administrativa y la rendición de cuentas (*accountability*) por parte de la Administración, que son la base para la deliberación y, finalmente, decisión en las cuestiones que los ciudadanos consideren más importantes, tanto en una escala local como estatal³. Porque **la participación política no se ejerce solo votando periódicamente** en las elecciones o ejerciendo otros derechos políticos (como el derecho de expresión, reunión y manifestación, el de asociación, sindicación o el de huelga), **sino también teniendo acceso a la información de la actividad de los poderes públicos para poder revisarla, evaluarla y controlarla**, entre otras razones para poder actuar en consecuencia y denunciar judicialmente las posibles irregularidades (cuando se detecten), o bien volver a votar a los mismos representantes, cambiar de opción o crear la propia opción política. **El Estado democrático se caracteriza también por ser un sistema político en el que los ciudadanos controlan el Gobierno.**

⁽²⁾ Algunos autores diferencian entre los mecanismos de participación directa, en los que los ciudadanos toman la decisión final sin intervención de los representantes (referéndum), y los mecanismos de participación semidirecta, que permiten intervenir a los ciudadanos pero no configurar el contenido de la decisión final (iniciativa legislativa popular).

⁽³⁾ La tecnología facilita el acceso de los ciudadanos a la información pública relevante y confiable, pero también puede generar fenómenos como los de las *fake news*, que ponen de manifiesto cómo la tecnología puede colaborar a orientar el voto de los electores por medio de las «noticias» que circulan por las redes sociales. Un ejemplo de la interacción entre tecnología y elecciones lo encontramos en las presidenciales de los Estados Unidos del 2016 y con el caso Cambridge Analytica.

En un sistema representativo, **los representantes pueden estar condicionados por un mandato imperativo o tener un mandato representativo** (un mandato libre):

- **El mandato imperativo es propio del tiempo del sufragio censitario** (y antes con la representación estamental): era un mandato no general, sino concreto (con representantes que tenían un cuadernillo de indicaciones, de órdenes) y, por lo tanto, sometido a responsabilidad y a una posible revocación de la representación. Los electores dan instrucciones a sus representantes (delegados) y les indican el sentido del voto que tienen que emitir, y que no puede ser modificado sin consultarlos. Se trata de un sistema inspirado en el contrato de mandato, en el sentido del derecho civil, en el

que se dan instrucciones al representante. En el tiempo del sufragio censitario, eran pocos los electores y se conocían todos (electores y elegidos). Con la extensión del sufragio, este modelo se hace insostenible. Aparte de las dificultades prácticas en la época contemporánea, es un sistema en el cual no tiene sentido el debate (porque hay que seguir instrucciones), ni buscar aproximaciones o transacciones, porque los representantes tienen instrucciones precisas de las que no es posible apartarse. Con mandato imperativo, la deliberación sería inútil o inacabable (I. Molas).

- **Con el sistema de mandato libre o mandato representativo**, el cuerpo electoral otorga su confianza a quienes resultan elegidos, para que, en nombre del pueblo, actúen de acuerdo con su criterio personal; por eso, **hay que renovar periódicamente la confianza. Son representantes del interés general, no tienen que obedecer órdenes de nadie**. Ahora bien, hay dos concepciones contrapuestas que continúan presentes en la teoría democrática: cada representado lo es de todo el pueblo (no representan a sus votantes –dado que el sufragio es secreto, no sería posible identificarlos– ni a los electores de su distrito, sino al conjunto del pueblo); y, por el contrario, el representante lo es de su circunscripción y solo todos los representantes conjuntamente representan al pueblo. Según Molas, la primera concepción es la que ha tendido a imponerse, pero en algunos estados americanos, influidos por el primer pensamiento democrático, se utiliza el *recall* o revocación de los electos por los electores mediante referéndum, lo cual significa que el representante lo es de su distrito. En cualquier caso, en algunos países que sobre el papel han optado por el mandato representativo e, incluso, por la prohibición del mandato imperativo en sus textos constitucionales (como es el caso del art. 67.2 de la Constitución española), en la práctica los partidos dan órdenes *a sus* parlamentarios o regidores y hablan de deslealtad o de traición cuando se rompe la llamada disciplina de partido cuando, en cambio, jurídicamente, no están obligados a obedecer las órdenes de nadie, incluidas las de su partido político. En una democracia como la actual, una democracia de partidos, **la prohibición del mandato imperativo no ha perdido su funcionalidad, sino que la ha ampliado: no es solo garantía de libertad y permanencia en el cargo frente a los electores, sino principalmente frente al partido político y del grupo parlamentario**. En esta segunda vertiente, **la prohibición del mandato imperativo es una garantía de la libertad de conciencia del parlamentario y del derecho de mantenerse en el cargo a pesar de que abandone el partido o sea expulsado**. Ante la preeminencia de los partidos y la consiguiente disciplina de voto, que en la práctica relaciona a los parlamentarios con los partidos, la prohibición del mandato imperativo se ha convertido en una **garantía que trata de dar una cierta autonomía al parlamentario para poder defender sus ideas, y para poder interpretar el interés general libremente y no como le indica el partido**. La disciplina de voto que puedan asumir los parlamentarios solo es admisible en la medida en que voluntariamente sea aceptada por ellos. Los partidos políticos no pueden revocar el mandato de un parlamentario

porque, jurídicamente, la renuncia depende única y exclusivamente de la libre voluntad del parlamentario. **La representación** (el escaño en el caso de los parlamentarios) **no es de los partidos, sino de la persona elegida**. Los partidos no los pueden obligar a dimitir, aunque hayan abandonado el partido (quizá porque consideran que el partido los ha abandonado a ellos y el programa con el que se presentaron a las elecciones). A pesar de que puede haber casos de corrupción y de transfuguismo por razones espurias, **el sistema del mandato representativo se basa en la confianza en la persona elegida**, porque aunque no lo parezca (con según qué campañas electorales), desde un punto de vista jurídico, **votamos a personas, no a partidos**.

En las democracias actuales, los partidos políticos son instituciones que están entre la sociedad y el Estado como principales gestores de la representación. Los partidos políticos son asociaciones privadas, de carácter voluntario, pero que cumplen unas funciones públicas muy importantes. Son asociaciones de ciudadanos agrupados en el entorno de un programa (de una ideología más o menos definida), con una organización estable, que cumplen unas funciones públicas (básicamente en el proceso electoral), son el instrumento principal de la participación política y tienen como finalidad el ejercicio del poder (a diferencia de los *lobbys*, los grupos de presión, que «solo» quieren influir en el poder). **Expresan el pluralismo político y son canal de manifestación de la voluntad popular, pero al mismo tiempo también ayudan a formar esta voluntad popular** (son, o tendrían que ser, canales de relación de ida y vuelta). Hoy día, los partidos políticos no solo son importantes, sino imprescindibles para la democracia moderna, para establecer una relación estable entre el Estado y la sociedad; **pero no deberían ser los únicos que intervinieran en los asuntos públicos**.

El riesgo de la democracia representativa es que el ciudadano no actúe como tal, que se sitúe solo en la esfera privada y abandone la *res publica*. La «profesión» del ciudadano es informarse, pensar, discutir, deliberar y decidir. Si no actuamos como ciudadanos, sino solo como trabajadores, empresarios o consumidores, el peligro es que la democracia resulte cada vez más oligarquía. Si la democracia no se ejercita cada día, como la musculatura, pierde tono, y puede llegar un momento en que se atrofie.

En la mayoría de los estados democráticos actuales, las elecciones son el mecanismo principal de participación política, pero para que podamos hablar de democracia, hace falta que sean:

- una verdadera «elección», es decir, **una elección entre varias opciones o alternativas reales** y entre varios candidatos;
- **libres**: el voto tiene que ser una decisión personal; hay que garantizar que no haya coacciones en la emisión del voto, pero también que se den las condiciones de libertad de expresión y propaganda en la fase de formación de la voluntad de los ciudadanos;

- **periódicas:** la democracia es poder examinar a quienes nos han representado, y poder cambiarlos, si consideramos que no lo han hecho lo bastante bien o hay otros que pensamos que lo pueden hacer mejor.

Para intentar evitar cualquier discusión sobre la legitimidad del resultado de las elecciones, es muy importante dotarlas de un marco jurídico que garantice su corrección. Este conjunto de normas jurídicas es lo que se denomina **derecho electoral**, y no suele estar establecido con detalle en las constituciones (para poder tener más flexibilidad a la hora de modificarlo sin tener que recurrir a la reforma constitucional). Sin embargo, **el derecho electoral es solo uno de los elementos del sistema electoral, que podríamos definir como el conjunto de elementos normativos y sociopolíticos que configuran el proceso de designación de titulares de poder**, cuando este proceso se basa en preferencias expresadas por los ciudadanos de una determinada comunidad política. De esta definición, se deduce que para proceder a un análisis completo de cualquier sistema electoral hay que adoptar una doble perspectiva, jurídica y politológica.

Por un lado, hace falta una perspectiva jurídica, porque una parte de los elementos del sistema electoral están contenidos en normas jurídicas; normas constitucionales o legales, pero también administrativas o penales, que constituyen las «reglas de juego» que han experimentado una mayor formalización. Para algunos autores, los elementos del sistema electoral expresados en normas jurídicas es lo que podríamos denominar el derecho electoral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el contenido del derecho electoral varía a lo largo de los años y en los diferentes países; por ejemplo, hoy día en el Estado español se regulan con detalle las campañas electorales, la financiación de los gastos, la forma del voto, etc., aspectos que en otros tiempos y actualmente, en algunos otros lugares, se dejan en manos de los actores políticos como prácticas discrecionales. Sin embargo, esta formalización jurídica de algunos elementos del sistema electoral que constatabamos que se ha producido no agota por sí sola todo el contenido del sistema electoral. Otros elementos importantes del sistema nos pasarían desapercibidos si no adoptáramos también una perspectiva politológica. Son los elementos que resultan de la experiencia acumulada por los actores que operan en el escenario electoral: partidos, candidatos, los votantes mismos. Sus conductas siguen pautas relativamente estables, condicionadas por la acción de las normas electorales y por la influencia de otros factores, como por ejemplo el mapa y la estructura de los partidos, la cultura política dominante y sus subculturas, una determinada distribución de los recursos (financieros, mediáticos y organizativos) necesarios para intervenir en el proceso electoral.

Según remarcan los profesores Josep Maria Vallès y Agustí Bosch (*Sistemas electorales y gobierno representativo*. Barcelona: Ariel, 1997), esta doble cara del sistema electoral es lo que explica que normas legales prácticamente idénticas no cumplen las mismas funciones ni producen los mismos efectos cuando se combinan con realidades sociopolíticas diferentes. Así, por ejemplo, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, la India y Sri Lanka comparten unos componentes normativos del sistema electoral muy parecidos; pero, integrados con elementos sociopolíticos muy diferentes, acaban configurando procesos electorales muy poco comparables en aspectos fundamentales. Entre estos elementos sociopolíticos, habría que tener en cuenta el nivel cultural, de bienestar, la estructura social (estratificación social, clases sociales, etnias, religiones, grupos de presión, antagonismos sociales), el sistema parlamentario o presidencial, la forma de organización territorial en Estado unitario o compuesto, número y tamaño de los partidos, y distancia ideológica entre ellos, etc.

En estos materiales, nos centraremos básicamente en los elementos normativos y todavía solo en algunos de los más importantes. **Podríamos distinguir dos grupos entre los diferentes elementos normativos que integran un sistema electoral:**

- **los que más directamente se orientan a garantizar la expresión libre e igual del voto** (como la capacidad electoral activa y pasiva, la formación del censo, la naturaleza de la instancia que tutela el proceso electoral o la financiación de partidos), y
- **los elementos que de manera más directa están relacionados con la conversión de las preferencias de los electores en escaños:** definición y magnitud de las circunscripciones, la forma del voto, la barrera electoral y fórmula electoral.

Así, algunos de los elementos más importantes que tiene que regular el derecho electoral son:

a) La capacidad electoral activa y pasiva

En democracia, el derecho de sufragio activo tradicionalmente suele estar reservado a los ciudadanos, es decir, a quienes tienen la nacionalidad del Estado, pero en algunos países también se permite participar a los extranjeros después de un cierto periodo de residencia; asimismo, en algún tipo de elecciones, como por ejemplo las locales, no es infrecuente que se dé la posibilidad de voto a los extranjeros. **Además de la nacionalidad, los requisitos más habituales para ejercer el derecho de voto son una edad mínima** (que normalmente coincide con la mayoría de edad –la plena capacidad jurídica de la persona– y mayoritariamente se sitúa en los 18 años, a pesar de que en algunos países, como Argentina, Brasil o Ecuador es a los 16), **disfrutar de los derechos políticos** (no estar condenado judicialmente a pena privativa del derecho de sufragio o haber sido declarado incapacitado para el ejercicio de este derecho) y **estar inscrito en el censo electoral** (en algunos países la inscripción es automática, de oficio por la Administración electoral, y en otros, como por ejemplo EE. UU., es preciso que el ciudadano se registre como votante, en un entramado burocrático de una cierta complejidad en algunos estados, lo cual es una de las causas que hacen que la abstención en este país se haya mantenido de manera persistente en torno al 50 % en las últimas tres décadas).

En la mayoría de los países, el voto es un derecho pero no un deber. En cambio, **el voto es obligatorio en una veintena de países en el mundo** (como Australia, Bélgica o Luxemburgo), la mayoría de los cuales son latinoamericanos (como Argentina o Brasil), **a pesar de que en algunos de estos estados no se sanciona a las personas que no votan** (como, por ejemplo, México, Costa Rica o Grecia). Las sanciones previstas suelen ser multas económicas, pero también se prevén trabajos para la comunidad, supresión del derecho de sufragio o prohibición de ocupar un cargo público.

En cuanto a la capacidad electoral pasiva, hay que diferenciar las causas de inelegibilidad de las de incompatibilidad. La inelegibilidad es un impedimento jurídico para ser sujeto pasivo de la relación electoral, para ser elegido. Las causas de inelegibilidades son circunstancias que pueden evitarse libre

o voluntariamente antes del proceso electoral, y que impiden el ejercicio del sufragio pasivo –ser elegibles– a determinadas personas, normalmente por razón de la función pública que ejercen, salvo que, con carácter previo, renuncien al cargo declarado incompatible. Así, la razón de las causas de inelegibilidad radica en el deseo de evitar que algunos candidatos puedan utilizar en provecho propio (y con la consiguiente discriminación para los otros) el ascendente o la capacidad de influencia sobre el electorado que se deriva de la posesión de determinados cargos o situaciones. Impidiendo que determinadas personas puedan concurrir como sujeto pasivo a la relación electoral, se quiere evitar que por los cargos o posiciones que ocupan aparezcan en situaciones de ventaja en las campañas electorales o puedan constreñir a determinados grupos electorales.

En definitiva, con la mayoría de las regulaciones tradicionalmente establecidas, se busca un mínimo de igualdad formal entre los candidatos a la hora de las elecciones. Ahora bien, en la sociedad actual de principios del siglo XXI, este tipo de inelegibilidades centradas sobre todo en el sector público han perdido parte de su eficacia real, porque no recogen algunos cargos o situaciones de poder que en estos momentos permiten detentar posiciones realmente preeminentes desde las cuales más se puede menoscabar el sentido de la igualdad material. Así, por ejemplo, parece evidente que hoy día puede tener más ventaja electoral, ascendente o capacidad de influencia el propietario de un gran medio de comunicación que un militar profesional o un policía en activo. Por otro lado, en algunos países, para garantizar de manera más eficaz la libertad del elector e imposibilitar que ningún candidato disfrute de más ventajas que otro, han establecido la inelegibilidad para quienes ejercen los cargos correspondientes en un momento relativamente distante –por ejemplo, seis meses o un año– de la convocatoria electoral.

Por otro lado, las incompatibilidades de los parlamentarios son el conjunto de cargos o situaciones jurídicas que no pueden ostentar durante el ejercicio de su mandato. **Si las causas de inelegibilidad tienen su fundamento en la voluntad de crear igualdad jurídica entre los distintos candidatos, la incompatibilidad se basa en la necesidad de independizar al elegido de otros intereses y dotarlo de plena dedicación a la función de representación**, es decir, que la primera causa opera antes de la elección y, en cambio, la segunda opera durante todo el mandato del electo. Sin negar que alguna causa de inelegibilidad sea también de incompatibilidad, parece excesivo asimilar las dos situaciones.

b) La naturaleza de la instancia que tutela el proceso electoral

Para controlar la regularidad de todo el proceso electoral y garantizar el libre ejercicio del derecho de voto, hace falta **un organismo electoral**, que básicamente **puede ser de tres tipos** (a pesar de que hay muchas variaciones en el detalle): **el modelo independiente** (las elecciones son organizadas y administradas por un organismo que es institucionalmente independiente del Gobierno y que administra su propio presupuesto, a pesar de que puede estar sujeto a un proceso de rendición de cuentas ante el poder legislativo o el judicial); **el modelo gubernamental** (las elecciones son organizadas y administradas por el Gobierno por medio de un ministerio –como el del Interior– o por medio de autoridades locales, como por ejemplo en Suecia, Suiza, el Reino Unido o Estados Unidos) y **el modelo mixto** (con una estructura doble o mixta, que

encontramos en estados como Japón, Francia o muchas excolonias francesas). Cualquiera de estos modelos puede resultar eficaz si se injerta bien en la tradición jurídica y política de cada país, porque, de cualquier manera, el organismo electoral (que puede ser permanente o temporal, centralizado o descentralizado) tiene que estar regido por criterios de independencia, imparcialidad y transparencia. De la calidad de la administración electoral depende significativamente la credibilidad de los procesos electorales.

c) La financiación de los partidos

En la mayoría de los países, la financiación de los partidos o candidatos es mixta (pública y privada) y combinada (por gastos ordinarios y por gastos específicamente electorales), y tiene límites en algunos ingresos y gastos electorales. Sin embargo, también en este tema es muy grande la variedad de sistemas.

En EE. UU., uno de los países donde son más cuantiosas las donaciones privadas (sobre todo provenientes de personas jurídicas), la sentencia del Tribunal Supremo de 2010 (*Citizens United vs. Federal Election Commission*) cambió de manera importante el sistema de donaciones al entender que la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución prohíbe al Gobierno restringir los gastos para las comunicaciones electorales (incluidas las campañas de desprestigio de un candidato) para las corporaciones con ánimo de lucro o sin el mismo.

A favor de la financiación pública, se suele argumentar que evita clientelismos que obligan a futuros favores, y que aumenta y equilibra la competencia entre partidos políticos. A favor de la financiación privada de los partidos, se argumenta que los partidos no pueden ser tratados como poderes públicos ni sus dirigentes como funcionarios, ni la organización interna como una máquina administrativa-electoral, y que los partidos y candidatos son en el fondo quienes deciden las subvenciones y quienes las reciben.

Regulando la financiación política: se puede intentar prevenir abusos (tanto financieros como en el proceso electoral, y por eso a menudo se fijan límites a las contribuciones o se establece la prohibición de ciertas fuentes de financiación que quieren minimizar los riesgos de corrupción política o de la distorsión que el dinero pueden provocar en la política); **procurar una competencia política justa y equitativa** (por medio de financiación pública a los partidos políticos, la práctica de acciones encaminadas a promover la participación de grupos subrepresentados o la imposición de límites a los gastos de campaña); **dar más información a los electores** (la exigencia de revelar públicamente los ingresos y gastos de los partidos da a los electores la oportunidad de saber quién da apoyo a los partidos y candidatos, y así decidir qué fuentes de financiación consideran aceptables y, por lo tanto, emitir su voto de manera consecuente); **y fortalecer los partidos como actores democráticos efectivos** (mediante el otorgamiento de subvenciones públicas como reconocimiento de su colaboración en el funcionamiento del sistema político).

La financiación pública puede ser directa (se otorga a los partidos políticos o candidatos en forma de dinero, habitualmente por medio de transferencias bancarias) **o indirecta** (aportaciones en especie con valor monetario, como por ejemplo espacios gratuitos en medios de comunicación de propiedad pública o privada, préstamos sin intereses, impresión y distribución gratuitas de papeletas y propaganda electoral, uso gratuito o subsidiado de espacios para establecer las oficinas de los partidos, transporte público gratuito o subsidiado para candidatos, uso de edificios públicos para celebrar concentraciones políticas, régimen fiscal o impositivo especial para los partidos que los exima del pago de alguno o de todos los impuestos, donaciones libres de impuestos para incentivar las aportaciones privadas a los partidos o líneas telefónicas gratuitas o subvencionadas).

d) El número y la magnitud de las circunscripciones

Una circunscripción electoral es **la unidad tomada como base para asignar los escaños**.

Para ser más precisos, también se podría definir como el colectivo de electores (generalmente asentados en un territorio concreto) sobre los cuales se hace la operación de asignación de los escaños entre las diferentes candidaturas. También se suele denominar distrito electoral, especialmente cuando es una demarcación electoral que solo elige a un representante. No obstante, el hecho de que la circunscripción tenga habitualmente una base territorial no implica que siempre deba ser así. De hecho, hay circunscripciones que no están asentadas en ningún territorio concreto, como por ejemplo las circunscripciones étnicas en Nueva Zelanda, la circunscripción para emigrantes en Portugal, o las antiguas circunscripciones universitarias en Inglaterra. Sin embargo, la práctica dominante es la circunscripción como unidad territorial.

Lectura recomendada

A. Bosch (2004). *Guía del sistema electoral* (núm. 151). Bellaterra: UAB, Colección Materials.

La magnitud de la circunscripción es el número de escaños de los que dispone la circunscripción para asignarlos entre las diferentes candidaturas. Este es el elemento más importante (junto con la fórmula electoral) para determinar la proporcionalidad del sistema electoral.

e) La fórmula electoral

La fórmula electoral es **el procedimiento de cálculo utilizado para traducir los resultados electorales de cada circunscripción a una distribución de escaños parlamentarios entre las candidaturas concurrentes, es decir, el procedimiento para convertir los votos en escaños**.

Hay fundamentalmente dos familias de fórmulas electorales: las mayoritarias y las distributivas (a menudo llamadas proporcionales). Las fórmulas mayoritarias parten de la idea de que la candidatura que obtiene más votos en una circunscripción se queda con el escaño o los escaños que se disputan. El nombre de fórmulas mayoritarias proviene del hecho de que siempre es la mayoría la que se lleva todos los escaños de la circunscripción. Habitualmente, estas fórmulas se aplican a circunscripciones uninominales (eligen un solo escaño), pero también se pueden aplicar a las plurinominales. Una de sus principales ventajas es la claridad: quien gana, sale elegido; quien pierde, se va

a casa, de tal manera que solo las candidaturas ganadoras en alguna circunscripción están presentes en el parlamento. No hay escaños para los perdedores: para ser diputado no basta con obtener un cierto porcentaje de votos, sino que se tiene que haber obtenido el apoyo mayoritario de los votantes de la circunscripción. Por otro lado, las fórmulas distributivas parten de la idea de que los escaños de una circunscripción se tienen que distribuir entre las candidaturas concurrentes de acuerdo con los votos obtenidos por cada una. La pretensión principal de las fórmulas distributivas es que el resultado final de la distribución de escaños logre un alto grado de proporcionalidad (es decir, una gran aproximación entre el porcentaje de escaños de cada partido y su porcentaje de votos), por lo cual a menudo han sido llamadas (no muy correctamente) fórmulas proporcionales.

Tal y como remarca el profesor Agustí Bosch, esta denominación es equívoca porque no bautiza la fórmula por el mecanismo esencial que usa, sino por una pretensión incierta. En efecto, es importante ver que, si bien la pretensión de proporcionalidad puede ser cumplida, también puede ser frustrada por la acción de otros factores (por ejemplo, circunscripciones pequeñas, umbrales altos, etc.). Seguramente, los conceptos quedan más claros si se llama a las fórmulas por aquello que hacen (distribuir la representación) y no por lo que quieren (lograr la proporcionalidad). En este sentido, algunos expertos han distinguido acertadamente entre proporcionalidad en los procedimientos y proporcionalidad en los resultados. Las fórmulas distributivas garantizan un procedimiento proporcional (la distribución del escaño), pero tomadas de manera aislada no pueden garantizar la proporcionalidad de los resultados. Lo que sí se puede denominar proporcional o no es el conjunto de un sistema electoral, y lo será más o menos en función del grado de proporcionalidad que logre en conjunto, no meramente por la fórmula que use.

Hay varias fórmulas distributivas, como por ejemplo la de Hare o Droop (las llamadas fórmulas del resto más elevado con cuota Hare o Droop son las que se considera que consiguen un resultado más proporcional), la Hare-Andrae (la precursora de las formas distributivas, y que requiere la forma de voto preferencial y un escrutinio bastante complejo), la d'Hondt (que perjudica en la práctica a los partidos pequeños), la Sainte-Laguë o Sainte-Laguë modificada (que favorecen a los pequeños), o la Imperiali (que favorece a los grandes).

Tradicionalmente, se han criticado las fórmulas electorales distributivas porque se considera que hacen aumentar la fragmentación del sistema de partidos, y una gran fragmentación dificultaría la existencia de un partido con mayoría absoluta que pueda formar Gobierno a solas, o complicaría incluso la formación de pactos de gobierno suficientes para gobernar en coalición, puesto que requiere un número mayor de signatarios. Sin embargo, si bien es cierto que hay una relación empírica entre el número de partidos parlamentarios y la duración de los gobiernos, también es cierto que el bipartidismo no tiene por qué ser siempre y en todo lugar una fuente de estabilidad (por ejemplo, en Irlanda del Norte), y en cambio, la fragmentación propiciada por sistemas de representación proporcional puede haber generado inestabilidad en sociedades conflictivas, como la República de Weimar, pero también ha consolidado la estabilidad de sociedades consensuales, como los Países Bajos.

f) La barrera legal o umbral de representación

La aplicación de fórmulas distributivas puede ir asociada a una elevada fragmentación del sistema de partidos. Para impedir que una multitud de grupos con un apoyo electoral muy pequeño accedan al Parlamento, muchos sistemas electorales exigen a las candidaturas **un porcentaje mínimo de votos para**

poder tomar parte en la asignación de escaños. Este número mínimo de votos que hace falta que tengan las fuerzas políticas concurrentes para entrar en el reparto de escaños se denomina barrera o umbral electoral.

Actúa como un mecanismo de «contrapeso» a las fórmulas distributivas. Así, la barrera electoral asegura que las fuerzas políticas (partidos, federaciones, etc.) que obtengan representación tengan un apoyo mínimo del cuerpo electoral, y al mismo tiempo intenta evitar que se fraccione excesivamente el parlamento, problema que ya hemos visto que algunos autores consideran que constituye el principal defecto de los sistemas proporcionales y puede desembocar en la formación de gobiernos poco estables. Los umbrales altos suelen propiciar la aparición del fenómeno del llamado voto útil, que desanima el voto para los partidos pequeños, de modo que puede acabar provocando una reducción de los partidos que se presentan a las elecciones; junto con esto, los umbrales altos suelen estimular el establecimiento de coaliciones preelectorales porque los dirigentes de los partidos pequeños a menudo optan por esta estrategia para intentar superar el umbral legal.

Por otro lado, hay que tener presente que un partido puede haber superado la barrera legal y quedarse igualmente sin ningún escaño; el porcentaje de voto con el que un partido consigue su primer escaño se denomina umbral efectivo (y depende de los resultados de los otros partidos y de la concentración del voto, pero también del número de escaños que se elijan en la circunscripción, de la fórmula electoral y del umbral legal).

g) La forma de voto

La forma de voto es la operación física que tiene que hacer el votante para ejercer el sufragio. Tal y como subraya el profesor Agustí Bosch, se podría pensar que el hecho de que el votante marque un nombre en una papeleta, o los ordene o elija una lista ya imprimida de nombres, es una formalidad meramente accidental; sin embargo, la experiencia ha demostrado que la forma de voto puede producir consecuencias importantes sobre el proceso electoral y sobre sus resultados. **Principalmente, hay tres formas de voto** (a pesar de que de cada una hay algunas variantes): **el voto personalizado** (en que el votante marca el nombre del candidato que prefiere), **el voto de lista** (en que el votante elige una candidatura presentada por un partido) y **el voto preferencial y transferible** (en el que el votante ordena los candidatos de más a menos preferido, y si la primera preferencia de un votante no es aprovechable –por alguna eventualidad que la fórmula utilizada ya especifica–, el voto se transfiere automáticamente a los candidatos que el votante ha colocado en la segunda preferencia, y así sucesivamente hasta que es aprovechado por un candidato elegido por el elector).

El voto preferencial es probablemente la forma de voto más elaborada y, por lo tanto, la más compleja, pero es la que permite explicitar mejor las preferencias de los electores, de una manera más precisa y completa. Aun así, en la práctica, muchos de los electores no hacen uso de la misma: la gran mayoría de los electores suelen establecer una ordenación de preferencias idéntica a la que les sugiere su partido preferido. Esta forma de voto elimina el voto útil (la tendencia de votar una candidatura que no es la preferida, con la intención de evitar un mal mayor). En cambio, **el voto personalizado** es el más simple (y el que históricamente se utilizó primero), y permite que el elector no solo elija un partido, sino precisar a la persona que quiere que ocupe el cargo; de manera contraria a lo que a menudo se afirma, el voto personalizado no tiene consecuencias positivas ni negativas sobre la proporcionalidad, sino que la baja proporcionalidad de algunos sistemas que lo utilizan no es el resultado de la forma de voto, sino que es consecuencia de la fórmula y

de las circunscripciones que están establecidas. Finlandia es un ejemplo de sistema electoral que consigue una alta proporcionalidad con voto personalizado. **El voto de lista** (también llamado voto de aceptación, porque el votante acepta una propuesta que ya viene establecida por el partido) presenta una ventaja que a menudo se olvida, y es que los partidos pueden aprovechar el hecho de que las listas son un conjunto inseparable de nombres para confeccionarlas según criterios complementarios a la mera popularidad electoral de los candidatos. Así, existe la posibilidad de equilibrar las listas para conseguir representación de grupos de lo contrario marginados (mujeres, jóvenes, minorías étnicas, etc.). También se puede aprovechar para constituir grupos parlamentarios más coherentes, introduciendo, por ejemplo, a expertos útiles en la tarea parlamentaria que quizá serían poco atractivos electoralmente, o se pueden intentar evitar grupos divididos ideológicamente; ahora bien, también es cierto que en la práctica los criterios de confección de listas no siempre son tan loables, que el aparato del partido tiene capacidad para infiltrar a candidatos con méritos dudosos (pero de gran fidelidad al líder o al aparato burocrático del partido). En cualquier caso, el voto de lista ordinario (también denominado de lista cerrada y bloqueada) a menudo es criticado por poco democrático, pues no permite que el votante modifique de ninguna manera una lista de candidatos previamente confeccionada por los partidos. **Hay dos variantes del voto de lista ordinario** que quieren solucionar este problema: **la lista no bloqueada y la lista abierta**. En la lista no bloqueada, el elector puede enmendar la lista presentada por el partido, eliminando a un candidato, expresando preferencia por alguno de ellos o reordenando la lista a su gusto, pero no puede introducir nombres que no figuren en la lista del partido, de modo que continúa votando por un solo partido. **El voto de lista cerrada pero no bloqueada**, que incorpora elementos personalizantes al voto de lista ordinario, puede afectar decisivamente a la cohesión de los partidos (porque los candidatos estarán interesados en competir entre ellos) y propicia el hecho de que los candidatos desarrollen más vínculos al exterior del partido (en las circunscripciones pequeñas, preocupándose más del trabajo del distrito y de los intereses de los ciudadanos, y en las circunscripciones grandes, desarrollando vínculos con grupos de interés, asociaciones o medios de comunicación). **El voto de lista abierta** permite al elector eliminar uno o varios candidatos de la lista y sustituirlos por candidatos de otras listas o por candidatos independientes. El elector, pues, puede efectuar una mezcla de candidatos de la lista y de fuera de la lista, lo que se aleja mucho de lo que es el voto de lista ordinario.

Los sistemas electorales, pues, implican un conjunto complejo de decisiones en el que sus diferentes elementos interactúan entre sí. A menudo, una reforma de uno de estos elementos puede tener consecuencias no deseadas, **de modo que siempre hay que tener en cuenta el conjunto del sistema y no solo una de sus piezas.**

Finalmente, debemos tener presente que aunque el derecho de sufragio activo en los diferentes tipos de elecciones es hoy día el principal mecanismo de participación, no es el único, porque **también se participa en democracia, como mínimo, de otras cuatro maneras:**

- Directamente, mediante el derecho de sufragio activo en los diferentes tipos de referéndum (incluidos los de revocación del mandato) o en el sistema asambleario de los municipios, como, por ejemplo, los que se rigen en Consejo Abierto en el Estado español (una treintena) o en dos cantones de Suiza, en los que se reúnen en *Landsgemeinde* (asamblea territorial).
- Mediante el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, es decir presentándose como candidato, haciendo uso del derecho de acceso a los cargos públicos electivos.
- Y por medio de otras vías que no requieren el uso del sufragio como, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular, el acceso a cargos y funciones públicas no electivas (formando parte de la Administración, como funcionario o empleado público, con acceso por mérito y con carácter permanente

o indefinido, o como cargo de confianza política y, por lo tanto, con un acceso vinculado al resultado de las elecciones y con carácter no permanente); y ejerciendo otros derechos políticos como la libertad de expresión o de información, el derecho de asociación (y no solo por medio de partidos, sindicatos y asociaciones empresariales), el derecho de reunión (a diferencia de la asociación, que tiene un carácter estable, la reunión privada o pública es la concurrencia concertada de varias personas con una finalidad común, pero siempre de tipo temporal) o manifestación (reunión en lugar público y en movimiento) o el derecho de petición.

Este derecho tuvo una gran importancia históricamente cuando el rey era la encarnación absoluta del poder y constituía toda una conquista hacerle llegar peticiones y quejas sin sufrir por ello persecución. Cuando el parlamento ocupó el centro del sistema político, pero se sustentaba todavía en el sufragio censitario, el parlamento pasó a ser el habitual destinatario de las quejas y peticiones de los ciudadanos, que no podían ni ser parlamentarios ni siquiera votar a quienes podrían llevar sus peticiones al parlamento. Durante mucho tiempo, el derecho de petición fue la única vía de participación para más del 95 % de la población. Actualmente, con otro contexto político, este derecho que parecía haber quedado como residual o marginal tiene un nuevo recorrido en la sociedad digital, mediante internet y especialmente las redes sociales.

- Además de la participación estrictamente política, en democracia los ciudadanos también pueden participar en la Administración de Justicia, mediante la institución del jurado.

1.1.4. El Estado social

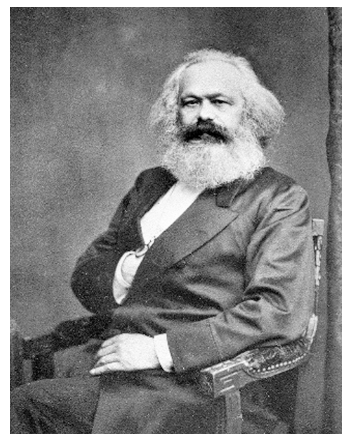
En la mayoría de los países occidentales, el Estado de derecho evolucionó hacia el Estado democrático, y en algunos, esta evolución continuó con el Estado social, que se podría definir como **el tipo de Estado que interviene en el orden económico con el fin de asegurar determinados bienes y prestaciones que garanticen a los ciudadanos las condiciones económicas y sociales suficientes para hacer reales y efectivas la libertad y la igualdad**. Es decir, un Estado obligado a intervenir no solo para garantizar un mínimo vital para los ciudadanos, sino también una mayor igualdad entre ellos. En el Estado social **la igualdad no puede ser solo una igualdad formal** (a todo el mundo el mismo trato), propia del Estado liberal de derecho, que se basaba en la libre oferta y demanda, y en la autorregulación del mercado y, por lo tanto, quería un Estado mínimo y no interventor. En el Estado social, la igualdad **tiene que ser también una igualdad material: real, efectiva y, por lo tanto, que implica tratar desigualmente a los que son desiguales**, ayudando a quienes menos tienen, con el objetivo de la igualdad de oportunidades.

1) Surgimiento, constitucionalización y consolidación del Estado social

Para poner una fecha orientativa, podríamos decir que el Estado social de derecho **empieza a surgir después de la Primera Guerra Mundial**, como reacción a las graves consecuencias que para buena parte de la población se derivan del Estado liberal del siglo XIX y que se agudizan con la crisis de 1929; el

Estado social quiere dar respuesta a las amplias capas sociales que empiezan a expresar su inquietud y sus reivindicaciones ante una situación muy grave de desigualdad y de empobrecimiento. **Sin embargo, la constitucionalización de la cláusula «Estado social» no llega hasta la segunda mitad del siglo XX, con el constitucionalismo democrático europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial.** Así, la Constitución francesa de 1946 calificaba la República francesa como «social» (art. 1), pero **la primera constitución que recoge la expresión Estado social de derecho es la Ley fundamental de Bonn de 1949**, que en su art. 20.1 establece que «La República Federal de Alemania es un estado federal, democrático y social», y en el 28.1 dispone que los estados miembros (los *Länder*) tienen que responder a los principios de «el Estado de derecho republicano, democrático y social». **Dos precedentes importantes serían la Constitución de México de 1917** (que por primera vez cuestionaba el carácter ilimitado de la propiedad privada y sostenía su función social) **y la Constitución alemana de Weimar de 1919** (que también consideraba que la propiedad privada no era absoluta sino limitada por las leyes, y que la ordenación de la economía se tenía que ajustar a los principios de la justicia para garantizar a todo el mundo una existencia digna).

La expresión «Estado social» tiene el origen en la fórmula «Estado social de derecho», que utilizó por primera vez en 1929 el jurista socialdemócrata Hermann Heller para defender una intervención estatal que diera contenido económico y social al Estado liberal de derecho. Para este autor, la sociedad capitalista está basada en la desigualdad y la dominación, y está regida por normas creadas por el Estado que tienen que ser cambiadas para poder avanzar hacia la igualdad social y económica entre las personas, que es lo que puede permitir crear una sociedad democrática. **No obstante, las primeras reflexiones sobre la transformación social del Estado las encontramos a mediados de siglo XIX, con autores tan diversos como Lorenz von Stein** (que propugna reformas sociales desde el Estado para corregir las desigualdades extremas y evitar una revolución social), **Louis Blanc** (en Francia, siguiendo las ideas de Henri de Saint-Simon) o **Ferdinand Lassalle** (en Alemania, que disientirá de Karl Marx y Friedrich Engels, y sostendrá la posibilidad de que con el sufragio universal y el acceso al parlamento de los representantes de los trabajadores, el Estado podía impulsar una legislación de transformación social). Desde posiciones sin duda más conservadoras, también hubo contribuciones teóricas relevantes sobre las relaciones del Gobierno, las empresas y los trabajadores, como, por ejemplo, con los inicios de la llamada doctrina social de la Iglesia (con la encíclica de 1891 *Rerum novarum* del papa León XIII). Sin embargo, de hecho, lo que seguramente impulsó más la evolución de muchos países hacia el Estado social fue el triunfo, en 1917, de la Revolución de Octubre en Rusia, liderada por Lenin y por los bolcheviques y basada en las ideas de Karl Marx, que supuso el establecimiento de la Unión Soviética (URSS), el primer Estado comunista del mundo; Lenin (seudónimo de Vladimir Ilich Uliánov), al igual que Lev Trotski, creía que el objetivo del socialismo en Rusia no se podía conseguir sin exportar con éxito la revolución a otros países. Así, algunos autores consideran que el Estado social que se irá construyendo progresivamente a



Karl Marx (1818-1883), uno de los pensadores que más han influido en el movimiento obrero, es autor, entre otras obras, de *El capital* (1867), que acabó de publicar, después de su muerte, su amigo y colaborador Friedrich Engels, con quien también escribió el *Manifiesto del partido comunista* (1848).

partir de la Segunda Guerra Mundial (sobre todo en los treinta años que van de 1945 a 1975) sería el resultado de la lucha contra el comunismo durante la denominada Guerra Fría, que aboca a la gran burguesía a nuevas estrategias para mantener su dominio, los cuales van desde el apoyo a fuerzas fascistas donde la revolución socialista está ya en marcha (América del Sur), hasta la alianza con la socialdemocracia en Europa occidental (que implica una ampliación de derechos sociales y un cierto desarrollo del Estado del bienestar, con un pacto no escrito entre los partidos demócrata-cristianos y los socialdemócratas).



Lenin (1870-1924), el ideólogo principal de la Revolución de Octubre y primer dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), es autor, entre otras obras, de *El desarrollo del capitalismo en Rusia* (1899), *El derecho de las naciones a la autodeterminación* (1914) o de *Las tareas del proletariado en la presente revolución*, nombre oficial de las *Tesis de abril* (1917).

Con la crisis de después de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo **con la gran depresión económica de 1929** (y sus secuelas, que se prolongaron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial), **se generalizó la aceptación de que convenía que el Estado democrático, mediante la ley y las políticas públicas, interviniese en la vida económica** para evitar el caos, regulando varios aspectos sociales y laborales, y **garantizando el acceso de todos los ciudadanos a algunos servicios considerados esenciales, como la sanidad, la Seguridad Social o la educación**. Las doctrinas de William Beveridge y de John Maynard Keynes **argumentaron las razones económicas y políticas de este intervencionismo**; por eso, Keynes, que defendió la imposibilidad de que el mercado, por sí mismo, consiguiera crear la plena ocupación, afirmó la conveniencia de una importante política de inversiones públicas y de medidas sociales, fiscales y monetarias, que ayudaría a aumentar la ocupación y a mitigar los efectos adversos de los ciclos económicos y los efectos más negativos en los sectores más empobrecidos de la sociedad.



El economista inglés Keynes (1883-1946) es reconocido como el padre de la macroeconomía moderna, y considerado como uno de los más importantes teóricos de la economía del siglo XX. Su principal obra es *La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero* (1936).

Ahora bien, a partir de los años treinta y durante **toda la segunda mitad del siglo XX, este intervencionismo estatal se concretó con medidas diferentes en cada Estado e implicó, por lo tanto, un grado de desarrollo del Estado social también con muchas diferencias de un Estado a otro**. Así, por ejemplo, en EE. UU. la política del New Deal ('nuevo acuerdo'), del partido demócrata y del presidente Franklin D. Roosevelt, fue un programa de intervención estatal en la economía entre 1933 y 1937, con medidas destinadas a conseguir un equilibrio del mercado y la reducción del desempleo: las primeras medidas de intervencionismo económico se centraron en la banca y el crédito, después vinieron ayudas a los pequeños granjeros, la reglamentación del trabajo industrial y las grandes inversiones en obras públicas, con el objetivo de mantener los precios y aumentar el poder adquisitivo, pero también se hicieron algunos cambios en el sistema de relaciones laborales liberal, y el Gobierno federal creó

⁽⁴⁾ Los resultados de la política del New Deal fueron limitados, y la profunda crisis económica de sobreproducción solo se superó cuando la Segunda Guerra Mundial permitió a la industria del país, sobre todo a la de armamento, la venta de grandes partidas de material.

pensiones de jubilación y desempleo, y reconoció derechos de sindicación, negociación colectiva, salario mínimo o jornada laboral semanal de 44 horas en algunos sectores. Este conjunto de medidas se podrían considerar atrevidas para la época y en aquel país, pero no tuvieron un desarrollo posterior que haya consolidado un Estado social⁴. En cambio, en Suecia, también a partir de los años treinta, el Estado dirigido por el partido socialdemócrata empezó a aplicar toda una serie de medidas (en buena parte pactadas entre empresarios y trabajadores) que fueron el inicio del desarrollo de un potente Estado social: pensiones de jubilación, seguros por accidentes de trabajo, jornada de ocho horas, valor normativo en los convenios colectivos, vacaciones pagadas, formación profesional o comités de empresa.

En cualquier caso, tal y como señala Molas, **los países que han optado por el Estado social a lo largo de la segunda mitad del siglo XX han consolidado la existencia de un inmenso aparato administrativo situado bajo la dirección del Gobierno** que interviene activamente en el terreno de la economía y **que lleva a cabo prestaciones sociales**, para ofrecer servicios públicos o dar respuesta a las demandas procedentes de sectores en situaciones de inferioridad. Todo esto ha implicado un enorme crecimiento de la Administración pública, en unas proporciones desconocidas hasta entonces, y esta Administración, al estar situada bajo la dependencia directa del Gobierno, ha generado un desequilibrio en el funcionamiento y el peso de las instituciones creadas en el marco de la tradicional división de poderes.

2) Objetivo e instrumentos del Estado social

El Estado social tiene que disponer de unos mecanismos y unas técnicas que le permitan intervenir en el sistema económico y social y lo obliguen a hacerlo, y el ordenamiento debe exigir que esta intervención tenga como objetivo asegurar determinados bienes y prestaciones que garanticen a los ciudadanos las condiciones económicas y sociales suficientes para hacer reales y efectivas la libertad y la igualdad.

Con el Estado social, **la libertad y la igualdad adquieren otro significado**, son concebidas de una manera radicalmente diferente a como las había teorizado el Estado liberal. **La libertad no exige ausencia de normas sino que, al contrario, las necesita para corregir la realidad social y económica que se sostiene en la desigualdad.**

Como hemos apuntado, el Estado liberal se construyó a partir del presupuesto teórico de la división entre la sociedad (que estaba dotada de un orden natural y se regía por unas leyes indisponibles) y el Estado (dotado de un orden artificial que se regía por leyes humanas, que tenían que respetar y proteger las leyes naturales). Los dos órdenes constituían ámbitos no solo diferenciados, sino separados: la sociedad estaría regida por el principio de la libertad individual y sometida a las leyes de la naturaleza, y el Estado estaría regido por el principio de la obediencia a las leyes decididas libremente por los ciudadanos. En esta concepción, cuanto menos leyes hubiera, mejor, porque se consideraba que cuanto menor fuera el peso del Estado, más espacio habría para la libertad. La sociedad libre era

la que tenía las mínimas leyes posibles, destinadas únicamente a garantizar que el orden «natural» no fuese alterado y, por lo tanto, tenía que haber el mínimo Estado posible, el indispensable para velar para que se respetara este orden natural. Por eso, el Estado liberal fue calificado como «gendarme» o «vigilante» que vela por hacer posible que las personas disfruten de libertad. En consecuencia, se defendía el criterio de que «el mejor Gobierno es el que gobierna menos» (ved I. Molas: *Dret constitucional, op. cit.*, págs. 58-59).

Con la instauración del Estado de derecho, la ley tenía que ser universal (aplicable a todo el mundo), abstracta (sin prever personas o situaciones concretas) y general (no se tiene que elaborar para un grupo social concreto). Todos los hombres eran iguales ante la ley porque eran considerados de manera abstracta como ciudadanos, pero sin tener en cuenta las diferencias personales, económicas y culturales que en realidad había entre ellos.

En el Estado social, **la ley pierde algunas de las características que la definían hasta entonces (universalidad, generalidad, abstracción) y tendrá que tratar desigualmente a los que son objetivamente desiguales** para lograr finalmente una cierta igualdad; **y deberá ser invalidada si su contenido es contrario a la igualdad material**. Así, **varios tribunales constitucionales** (como el alemán o el español) **han acogido en su jurisprudencia** lo que se conoce como **el juicio de razonabilidad, un criterio que supone** que ante un trato desigual, **hace falta siempre una ponderación sustantiva** (y no solo formal) **entre posiciones realmente diferentes** (A. Garrorena).

Así pues, **la igualdad también cambia su significado con el Estado social**. Ya no puede ser solo una igualdad jurídica o formal, la igualdad *ante* la ley (art. VI de la Declaración de 1789), sino que **tiene que ser sobre todo una igualdad material, igualdad en la ley**, de modo que, como se ha apuntado, la ley deberá establecer muchas veces tratos diferenciados respecto a situaciones de hecho (o destinatarios) que son realmente distintos. La opción por el Estado social **implica una intervención proactiva en la vida social y económica «para promover que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas», y significa, por lo tanto, «remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud»**. Y no solo esto, sino que también corresponde a los poderes públicos promover y «facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Es **el mandato que establece el art. 9.2 de la Constitución española de 1978**, que recoge en términos muy parecidos lo que estableció, en 1947, la Constitución italiana (art. 3.2⁵). Para algunos autores, como Gavara y Roig, este tipo de precepto **condensa y expresa el concepto constitucional de Estado social**. Ángel Garrorena (*El Estado español como Estado social y democrático de derecho*, Tecnos, 1992) remarca que esta cláusula es «la clave» del nuevo concepto constitucional de igualdad en el ordenamiento jurídico español y considera que este artículo significa asumir una importante contradicción en la Constitución porque implica que «después de la constitucionalización del modelo neocapitalista» se acepta y se reconoce que esta misma estructura económica y social que se ha establecido es un «obstáculo» que hay que «remover» en el camino hacia la libertad e igualdad del individuo y de los grupos. Finalmente, Lelio Basso, citado por Garrorena, con la autoridad que le concede haber sido uno de los principales autores de la formulación contenida en el art. 3.2 de la Constitución italiana, hace notar que la intención principal

⁽⁵⁾El art. 3.2 de la Constitución italiana establece que «corresponde a la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando el derecho a la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país».

para introducir este precepto fue desmentir todas las afirmaciones de la misma Constitución que parecen dar por logrados algunos objetivos (igualdad, democracia, etc.) y recordar que estos objetivos están todavía por hacer y, por lo tanto, dejar a cuerpo descubierto el valor puramente ideológico de aquellas afirmaciones constitucionales y tender a desmitificarlas; en definitiva, lo que se quería era evidenciar que hay que seguir andando. Asumir constitucionalmente las contradicciones obliga al Estado a hacer transformaciones sustanciales de la estructura social establecida.

El Estado social no solo afecta a la concepción de la libertad y la igualdad, también la seguridad adquiere un nuevo matiz: ya no es solo seguridad contra el abuso de poder, sino también seguridad frente a la miseria, el trabajo excesivo, la enfermedad, etc. A partir de la publicación de los dos famosos *Informes* de William Beveridge sobre la Seguridad Social (1941 y 1944), no él, como a veces se afirma, sino Winston Churchill sintetizó en un eslogan la función de aquellos seguros y, por extensión, del Estado social: buscar para todas las personas una cierta «protección desde la cuna hasta la sepultura». Sin embargo, la cláusula de igualdad real de las constituciones italiana y española va más allá de intentar asegurar a lo largo de toda la vida de la persona una existencia digna en el aspecto material: son un mandato doble a los poderes públicos para que intervengan en la sociedad para remover los obstáculos que dificultan que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y a la vez un mandato para que faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, es decir, un trabajo que no tiene final.

Ahora bien, **la igualdad jurídica o igualdad ante la ley** continúa siendo un valor en el Estado social y **llega a ser un límite: no se puede otorgar un tratamiento diferente sin que haya una base objetiva y razonable, porque entonces constituiría una discriminación** (una diferenciación no justificable).

En el Estado social, la igualdad ya no es un punto de partida, sino una finalidad (Fossas y Pérez Francesch). Es **la finalidad, el objetivo último o la razón de ser del Estado social: unas condiciones de libertad para todo el mundo que hagan posible unas condiciones de igualdad real también para todo el mundo**. Aun así, en la mayoría de los estados sociales se trata de un objetivo todavía por conseguir, y en los mejores casos podríamos decir que «está en proceso» o «se está trabajando».

Hay que remarcar el carácter progresista que a finales del siglo XVIII representó el reconocimiento a toda persona humana de unos derechos y libertades, y de una igualdad ante la ley (frente a las desigualdades y privilegios que había por razón de nacimiento en periodos históricos precedentes). Sin embargo, hoy es más que evidente que por el hecho de que las leyes reconozcan la igualdad jurídica, unas libertades o el derecho de propiedad no significa que, en la práctica, haya una igualdad efectiva para todo el mundo, ni que cada persona pueda disfrutar en la misma medida de las libertades, ni siquiera que todo el mundo tenga alguna propiedad. No hay que ser un gran jurista para darse cuenta de que de poco o nada sirve tener la libertad de poder comprar todo lo que se quiera si se pasa hambre, porque no se tiene ni el dinero mínimo para comprar una barra de pan; de poco o de nada sirve tener la libertad de comprar un palacio si no se tiene ni el dinero para pagar el precio de un pisito de alquiler. El Estado social tendría que servir para ayudar a crear unas condiciones de libertad e igualdad, para hacerlas reales y efectivas para todos sus ciudadanos. Lejos está, aún en el siglo XXI, el cumplimiento de este objetivo.

No obstante, más lejos está todavía la solidaridad internacional, la de los estados que se califican ellos mismos de sociales respecto a otros estados con un índice de desarrollo bajo; muy lejos, a pesar de que sería posible que aquellas condiciones de libertad e igualdad no fueran solo para los ciudadanos del Estado social, sino para todas las personas, como parte del objetivo de solidaridad internacional que tendría que ser propio de cual-

quier Estado social. Sin embargo, la solidaridad internacional estatal es actualmente muy exigua (por no decir ridícula). Y hoy día es fácil constatar que no solo hay desigualdades muy grandes dentro de un mismo país (a menudo en estados sociales), sino sobre todo entre países, porque, por ejemplo, en el mundo todavía hay pobreza extrema y hambre, no hay educación primaria universal, ni igualdad entre hombre y mujer, existen niveles muy diferentes de mortalidad infantil o hay enfermedades que son causantes de una gran mortalidad en algunos países, mientras que en algunos lugares, o para algunas personas, los tratamientos médicos han conseguido que estén erradicadas o ya no sean mortales. La distancia entre las personas, colectivos y países ricos y pobres es muy grande, y si no se hace nada para corregirlo se puede hacer todavía más grande. En el siglo XXI, para la gran mayoría de las personas no se dan todavía las condiciones de libertad y de igualdad que propugna el Estado social.

La mayoría de la doctrina coincide en que «solo sobre el régimen democrático se puede construir un verdadero y eficaz Estado social» (García-Pelayo). No obstante, Molas apunta no solo esto, sino que, sobre todo desde posiciones socialdemócratas, se considera que la democracia acaba llevando al Estado social porque:

«El Estado democrático no está destinado a proteger las desigualdades y la dominación sociales, sino que tiene que dotarse de una voluntad intervencionista para reformar la realidad económica y social.»

La necesaria y obligada intervención estatal no impide que en cada uno de los estados se lleve a cabo de una manera y con un alcance muy diferentes. Y no solo esto, sino que **dentro de un mismo Estado**, de acuerdo con las distintas ideologías políticas que accedan al Gobierno, **también se pueden generar propuestas muy diferenciadas**: la mayoría parlamentaria en cada momento decide cuántos recursos públicos se destinan a finalidades sociales y cómo se reparten. Sin embargo, tanto si se decide avanzar mucho o poco, la dirección en la que hay que avanzar en un Estado social tiene que ser garantizar a los ciudadanos las condiciones económicas y sociales suficientes para hacer reales y efectivas la libertad y la igualdad.

¿Cómo se da esta intervención? En un Estado social, el aparato estatal **interviene principalmente por tres grandes vías**:

- **Proclamando unos derechos económicos y sociales** (que exigen una intervención activa de los poderes públicos para reformar las condiciones sociales preexistentes, y exigen la prestación de determinados servicios o derechos de prestación), y **regulando las relaciones laborales** en defensa de la parte más débil, que generalmente es el trabajador: horarios (jornadas máximas, horas mínimas de descanso), salario mínimo, vacaciones, condiciones de seguridad y de higiene en el trabajo, etc.
- **Creando empresa pública**: en un Estado social no solo puede haber iniciativa privada, sino que también debe poder haber iniciativa pública en la actividad económica. En los sectores que se consideran clave, estratégicos para el Estado, o que no son cubiertos suficientemente por la empresa privada (porque son deficitarios desde una valoración solo económica).

Y el Estado puede decidir crear empresas públicas nuevas o privatizar las existentes.

- **Prestando servicios directamente.** De una manera básica en enseñanza, sanidad, asistencia social, pensiones (jubilación, invalidez, dependencia, desempleo, renta mínima, etc.), transporte público e infraestructuras.

De manera sintética, López Guerra ha afirmado que **el contenido social del Estado se despliega en tres dimensiones: el Estado regulador, el Estado empresario y el Estado benefactor.**

1.2. La forma de gobierno

Las formas de gobierno se dan dentro del seno de una determinada **forma de Estado**. Como hemos visto, las diferentes formas de Estado dependen del tipo de relaciones que mantiene el poder (los poderes públicos) con los ciudadanos. En cambio, en la **forma de gobierno** nos fijamos básicamente en uno de estos elementos: el poder, y es **determinada por las atribuciones fijadas por los diferentes órganos superiores del aparato estatal y por sus relaciones (básicamente entre el parlamento y el Gobierno)**, así como por el sistema de partidos y la configuración de mayorías y minorías.

Dentro de la forma de Estado democrático, se acostumbran a distinguir tres grandes formas de gobierno: el sistema parlamentario, el presidencial y el mixto o semipresidencial (que se ha desarrollado más recientemente).

Algunos autores hacen referencia a **una cuarta forma de gobierno, el régimen de asamblea** o sistema convencional, pero que en realidad **es más una forma histórica que real**. Teóricamente, se trata de una forma de gobierno en la que el parlamento nombra un comité (o directorio) que hace las funciones de Gobierno, pero con absoluta subordinación a la asamblea. No hay tampoco un jefe del Estado unipersonal, sino que este cargo corresponde colegiadamente a los miembros del comité. La Constitución francesa de 1973 se basaba en este modelo asambleario o convencional y es vigente en Suiza (quizá más en la Constitución que en la práctica, porque el Consejo Federal no es un mero comisionado de la asamblea, sino un auténtico órgano de dirección política).

Por otro lado, para intentar sistematizar mejor las múltiples variantes de las tres grandes formas de gobierno que van apareciendo en diferentes países, algunos especialistas se refieren al **semiparlamentarismo** o al **neoparlamentarismo**, en relación con las formas de gobierno de algunos países latinoamericanos, como Uruguay, por ejemplo, o de las regiones italianas después de las reformas constitucionales de 1999.

1) **El sistema presidencial:** en contraste con el sistema parlamentario, **la forma presidencial de Gobierno se basa teóricamente en una separación rígida de poderes**. Es la forma que adopta la Constitución de Estados Unidos de América (1787), y por su influencia, muchos estados latinoamericanos. **Podríamos definirla a partir de tres grandes características:**

- **Hay elecciones separadas para el presidente (o presidenta) de la República y para el parlamento (legitimidad dual)**, que tienen lugar con pe-

riedad fija e inalterable. La legitimidad democrática directa del presidente justifica sus poderes y la independencia frente al parlamento.

- No hay los elementos de colaboración entre poderes propios del sistema parlamentario: **el presidente no necesita la confianza del parlamento** ni para ser elegido ni para mantenerse, **el parlamento no puede obligar a dimitir al presidente, y este tampoco puede disolverlo de manera anticipada**. Sin embargo, **a pesar de esta separación teóricamente rígida de poderes, en la práctica a menudo tiene que haber colaboración** y hay más control por el parlamento **que en el sistema parlamentario**. Porque el presidente puede vetar leyes (y hará falta una negociación política para evitarlo), pero el parlamento le tiene que aprobar los presupuestos, sin los cuales el presidente no puede gobernar; además, en EE. UU. el control de idoneidad de muchos cargos que quiere nombrar el presidente implica el visto bueno del parlamento. Este control y esta necesidad de colaboración todavía aumentan más cuando el partido mayoritario en una o en las dos cámaras no coincide con el partido del presidente.
- **El presidente de la República reúne las funciones de jefe de Estado y de jefe de Gobierno** (ejecutivo monista), de tal manera que el poder ejecutivo corresponde personalmente al presidente, que lo ejerce asesorado por secretarios y colaboradores, pero no hay un Consejo de Ministros como órgano colegiado y con responsabilidad solidaria (que es una de las características de la forma parlamentaria).

2) **El sistema mixto o semipresidencial** (también denominado de ejecutivo dual) se ha ido extendiendo durante las últimas décadas y lo encontramos actualmente en Francia, Portugal, Finlandia, Polonia, Rumanía, Rusia o Colombia (y teóricamente en otros países como, por ejemplo, Austria, Irlanda o Islandia, en los que un semipresidencialismo aparente encubre un parlamentarismo real, fruto de una mutación constitucional). En esta forma de gobierno, **se combinan algunos elementos típicos del sistema parlamentario con otros que lo acercan al presidencial**. Las condiciones necesarias para poder considerar un sistema político como semipresidencial son fundamentalmente cinco:

- **Existencia de un poder ejecutivo dual** (presidente o presidenta de la República y Gobierno).
- Elección del presidente de la República por medio de sufragio universal directo; hay **elecciones separadas para el presidente de la República** (elegido directamente por los ciudadanos) **y para el parlamento** y, por lo tanto, es posible que la mayoría presidencial y la parlamentaria no coincidan.
- **El presidente de la República tiene atribuidos amplios poderes constitucionales**. En el caso francés, el jefe del Estado (que no es responsable ante el parlamento pero, en cambio, lo puede disolver anticipadamente)

es el auténtico centro del sistema político y ejerce importantes poderes de decisión incluso sin necesidad de contrafirma en algunos supuestos. **El dualismo de presidente y primer ministro se resuelve mediante un reparto de funciones** que permite al presidente tomar cierta distancia en relación con los asuntos cotidianos.

- **El presidente de la República nombra al primer ministro** y puede presidir el consejo de ministros.
- El Gobierno es responsable ante el parlamento y **necesita**, por lo tanto, **la doble confianza del presidente de la República y del parlamento**.

3) **La forma de gobierno parlamentaria** parte de una concreción del principio de división de poderes que **se basa en la colaboración entre el Gobierno y el parlamento**, y se caracteriza por **la necesidad de una permanente relación de confianza entre estos dos órganos**, de tal manera que el ejecutivo **deriva del poder legislativo y es responsable ante el mismo**. Así, podríamos definir sintéticamente el sistema parlamentario a partir de cuatro grandes características:

- **El Gobierno deriva del parlamento y debe tener en todo momento su confianza**, que se expresa generalmente mediante el voto de investidura inicial del Gobierno o de quien lo preside, y continúa mediante el apoyo parlamentario a la acción política del Gobierno a lo largo de la legislatura; esto supone que la mayoría parlamentaria y el Gobierno actúan de mutuo acuerdo para tomar decisiones políticas (una parte importante de las cuales se concretarán en leyes que serán mayoritariamente de iniciativa del Gobierno).
- **El Gobierno es políticamente responsable de sus actuaciones ante el parlamento**, que tiene encomendada una función de control político sobre el Gobierno. **Si la mayoría parlamentaria rompe la confianza en el Gobierno, este está obligado a dimitir**; los instrumentos para exigir esta responsabilidad política son la aprobación de una moción de censura (voto parlamentario de desconfianza) y la denegación de una cuestión de confianza (el parlamento vota en contra de la solicitud de confianza presentada por el Gobierno). Además de estos dos mecanismos extraordinarios de control (extraordinarios por el poco uso que se hace de los mismos en la práctica y por la relevancia de su consecuencia: el cese del Gobierno), también denominados mecanismos de control-sanción, hay varios instrumentos de control ordinario (que no suponen la ruptura de la relación de confianza entre el parlamento y el Gobierno), como son las preguntas y las interpelaciones al Gobierno, las sesiones informativas de los miembros del Gobierno, las solicitudes de información y las comisiones de investigación. Este segundo tipo de control, también llamado control-verificación o control-inspección, tiene por objetivo la fiscalización de la actuación cotidiana del Gobierno y de la Administración, en el doble sentido de li-

mitar sus posibles excesos y de mostrar a la opinión pública sus defectos y las virtudes y alternativas de la oposición, para poder ser mayoría en las elecciones siguientes.

- Además de estas dos características fundamentales (el Gobierno deriva del parlamento y es responsable ante él), también suele estar presente en los sistemas parlamentarios la facultad del Gobierno o de su presidente o presidenta de disolver el parlamento antes de que se acabe la legislatura. Así, **el Gobierno o quien lo presida pueden disolver anticipadamente el parlamento** no solo si ven peligrar su apoyo parlamentario sino, en la práctica, a menudo cuando consideren que es el mejor momento para revalidar o, incluso, ampliar el apoyo.
- También suele estar presente en los sistemas parlamentarios la distinción entre la figura del jefe del Estado y la del presidente o presidenta del Gobierno, que no coinciden en la misma persona. Así, **hay una separación orgánica entre el jefe del Estado (que es una figura básicamente simbólica y representativa) y el presidente del Gobierno** (o primer ministro), con poder ejecutivo y de dirección política. **El Gobierno se estructura como un órgano colegiado** que responde políticamente de manera solidaria ante el parlamento. **Teniendo en cuenta la figura del jefe del Estado, se pueden distinguir dos variantes de la forma parlamentaria de gobierno: la monarquía parlamentaria** (en la cual el jefe del Estado es un rey o reina, con un mandato vitalicio y hereditario, e irresponsable políticamente de sus pocas atribuciones) **y la República parlamentaria** (con un jefe del Estado elegido por un parlamento generalmente ampliado, con un mandato limitado y responsable de sus también pocas atribuciones). Suecia, el Estado español o el Reino Unido de Gran Bretaña son ejemplos de monarquía parlamentaria, mientras que Italia o Alemania lo serían de sistema parlamentario con república. Actualmente, tanto en una república como en una monarquía parlamentaria, **el jefe del Estado se ha convertido en un elemento secundario del sistema parlamentario, que ya no forma parte del ejecutivo y con unas funciones básicamente representativas**. En una monarquía parlamentaria, el presidente o presidenta del Gobierno (o algún otro de sus miembros) asume la responsabilidad de los actos del rey mediante la contrafirma.

El sistema parlamentario no se deriva de una fórmula prefijada o cerrada (como sucede en el caso del sistema presidencial de Estados Unidos), sino que procede de la acumulación histórica y **ha sido el resultado de una evolución** a partir de los sistemas preexistentes. Así, la forma parlamentaria de gobierno (que tuvo sus orígenes en la monarquía limitada de la Inglaterra de finales del siglo XVII) **ha tenido tres grandes fases**: el parlamentarismo dualista, el monista y el racionalizado.

En el **parlamentarismo dualista**, los dos centros fundamentales de poder eran el rey (que participaba activamente del poder político) y el parlamento; el Gobierno tenía que

disponer de la confianza de los dos. Esta es la situación de Inglaterra hasta 1837, la que establece la Constitución belga de 1831 y la de Alemania bajo la Constitución de 1871, y es también la fórmula que rige en el Estado español con las constituciones del siglo XIX e, incluso, durante la II República.

A medida que el jefe del Estado fue perdiendo buena parte del poder político (hacia finales del siglo XIX) se desarrolló el denominado **parlamentarismo monista**, en el cual el Gobierno deviene responsable únicamente ante el parlamento; era nombrado presidente del Gobierno aquel que disponía del apoyo de la mayoría de las cámaras, una mayoría que siempre tenía la posibilidad de obligarlo a dimitir retirándole la confianza; y el parlamento era –al menos aparentemente– la institución más importante del Estado, el órgano predominante, de tal manera que el Gobierno se convirtió en un «poder ejecutivo», que tenía que limitarse a ejecutar sus órdenes.

El parlamentarismo monista ha evolucionado desde una centralidad inicial del parlamento, que tenía en sus manos grandes facilidades para exigir la responsabilidad política del Gobierno (característica de los sistemas parlamentarios de entreguerras) hasta la actual subordinación al Gobierno (que es quien realmente dirige la política), propia del **parlamentarismo racionalizado**. En esta etapa, se produce un fuerte incremento de las cláusulas que protegen la estabilidad del Gobierno y dificultan su remoción. Al mismo tiempo, la implantación del Estado social ha supuesto un gran crecimiento de la Administración, que depende del Gobierno, que junto con una cierta personalización de la política ha implicado un fuerte protagonismo político de quien ejerce la presidencia de Gobierno. Así, paralelamente a la pérdida de peso del jefe del Estado, se ha producido un aumento de la importancia política, jurídica y constitucional del jefe del Gobierno o primer ministro, hasta el punto de que muchos regímenes parlamentarios actuales son llamados **regímenes de gabinete o de primer ministro**. Además, con la extensión del sufragio electoral (hasta llegar a ser universal) y el consiguiente desarrollo de los partidos políticos, estos han adquirido también un importante protagonismo en las decisiones de las cámaras y del mismo Gobierno, hasta convertirse a menudo en los auténticos protagonistas del sistema político, al que han dado estabilidad y previsibilidad.

Así, a pesar de que formalmente los sistemas parlamentarios tienen el mismo fundamento, todos estos elementos mencionados y, especialmente, la presencia de partidos fuertes y disciplinados en los parlamentos, mediante los grupos, han cambiado la posición de los parlamentos y su funcionamiento, y, por lo tanto, las características del régimen parlamentario. Las principales decisiones parlamentarias son adoptadas por los grupos y no por los diputados individualmente; el parlamento ha dejado de ser en buena parte el órgano decisorio que teóricamente es, para convertirse sobre todo en una instancia de mediación entre el Gobierno y los grupos que están en la oposición y de publicidad de sus posiciones. Porque a pesar de que continúa siendo decisiva la confianza parlamentaria del Gobierno (su ruptura implica la dimisión), en realidad la mayoría del parlamento y el Gobierno pertenecen al mismo partido o coalición (y tienen a menudo un mismo líder, que suele ser el presidente o presidenta del Gobierno) y, por lo tanto, es el Gobierno quien impulsa la actuación de la cámara y no a la inversa. **El diálogo político real no es entre el parlamento y el Gobierno, sino entre el gobierno (y a menudo especialmente quien lo preside) y la oposición**; si la mayoría parlamentaria y el Gobierno actúan de acuerdo, la oposición no tiene la posibilidad de cambiarlo y su actividad de control parlamentario se dirigirá principalmente a influir en la opinión pública para intentar cambiar la mayoría de la cámara en las próximas elecciones. **El control parlamentario ha cambiado su destinatario**. El control de la oposición, de la minoría, no va tan dirigido a intentar el convencimiento de la mayoría (respecto a la conveniencia de rectificar) como a conseguir el convencimiento de la opinión pública respecto a la existencia de una opción diferente, mejor y posible. **La oposición, con muy**

pocas posibilidades de influir en el contenido de la acción de Gobierno, prácticamente solo tiene la posibilidad de utilizar el parlamento como caja de resonancia de sus críticas y propuestas alternativas. La acción de oposición es una acción básicamente de desgaste y que va dirigida a aquel que con su decisión tiene la posibilidad de cambiar la situación política, es decir, la opinión pública convertida en cuerpo electoral. Esta circunstancia, junto con las ya comentadas de reforzamiento del Gobierno (y de la persona que lo preside) y del nuevo papel de los partidos políticos, ha condicionado de manera decisiva la evolución del sistema parlamentario en la actualidad, y ya hay quien ha hablado de una nueva etapa que han denominado como **parlamentarismo estructurado**. Así pues, este liderazgo y preeminencia de la presidencia del Gobierno (junto con otros factores que ya hemos apuntado – igual de importantes o más– como el cambio de papel del parlamento y una disminución de la eficacia de los controles interorgánicos en el marco de lo que hemos denominado democracia de partidos) han propiciado una práctica del parlamentarismo –o, al menos, una percepción mediática de esta praxis– que lo acerca en algunos aspectos al sistema presidencial. En el parlamentarismo europeo, se mantienen formalmente las estructuras de la forma parlamentaria de gobierno, pero se introduce una práctica política presidencialista, pasando de un parlamentarismo de canciller o de primer ministro a lo que se ha denominado «**parlamentarismo presidencial**».

Esta presidencialización del régimen parlamentario produce una situación deformada: precisamente porque se trata de un presidencialismo encubierto, lo que suele suceder es que este híbrido reúne los defectos del presidencialismo y del parlamentarismo, y ninguna de sus virtudes. Así, la conexión (y no separación) entre ejecutivo y legislativo, propia del parlamentarismo, queda sin el contrapeso (también consustancial al régimen parlamentario) de una cámara capaz de servir de freno al Gobierno; por otro lado, la legitimación popular directa del ejecutivo y la autonomía política de su actuación, propias del presidencialismo, quedan sin el contrapeso (también consustancial al régimen presidencial) de la separación entre ejecutivo y legislativo. En síntesis, este híbrido (parlamentarismo presidencial) tiende a convertirse en una forma de gobierno que descansa casi exclusivamente en el control electoral y no en el control que resulta del equilibrio institucional, y se debilita (o se pierde) así el sistema de frenos y contrapesos en el que se basa el Estado constitucional, con lo cual se daría la paradoja de que en este tipo de régimen parlamentario, el legislativo pueda ser más débil y el ejecutivo más fuerte que en el régimen presidencial.

1.3. La forma de organización territorial

Históricamente, hay dos modelos de organización territorial, el Estado unitario y el Estado federal, que surgieron a finales del siglo XVIII en Francia y en EE. UU., respectivamente.

1) El Estado unitario

El Estado unitario surge de la Revolución Francesa a partir de las ideas racionalistas de una parte de los revolucionarios, los llamados «jacobinos»; después de una etapa inicial revolucionaria muy breve, en la que se intentó imponer una organización administrativa uniforme, pero descentralizada y

democrática, desde la Constitución de 1791 los jacobinos establecieron una organización uniforme y centralizada, que Napoleón culminó y que **se extendió durante los siglos XIX y XX por muchos estados europeos**, entre ellos el español (entrelazándose con un modelo que ya venía de la dinastía borbónica, desde 1714).

El Estado unitario centralizado se caracteriza porque tiene solo una instancia dotada de capacidad de dirección política y, por lo tanto, un **único centro con capacidad legislativa**; concentra, pues, todo el poder del Estado en unas **únicas instituciones políticas** (solo un parlamento, solo un Gobierno y una Administración única, y un solo poder judicial) que ejercen sus atribuciones sobre todo el territorio del Estado. **De este centro dependen todos los órganos de la administración, en una relación de subordinación jerárquica, y tienen la función de ejecutar de manera uniforme en el conjunto del territorio las decisiones y las normas adoptadas por los órganos políticos centrales**; las posibles divisiones territoriales existentes (municipios, departamentos, regiones, provincias) solo tienen el carácter de circunscripciones administrativas para la prestación de servicios estatales. **El ordenamiento jurídico, en consecuencia, es también único**, el mismo para todos los ciudadanos y, por lo tanto, **la unidad jurídica no se basa solo en una única constitución, sino en las mismas leyes y las mismas normas infralegales** con eficacia para todo el territorio y vinculantes para todos los ciudadanos. El Estado unitario, en contraposición al Estado federal, **se basa en tres principios: la unidad** (un solo Estado), **la uniformidad** (la misma ley para todo el territorio) y **la centralización** (la dirección política y la decisión administrativa se ejercen desde el centro, se concentran en la capital del Estado).

A lo largo del siglo XX, **el Estado unitario ha experimentado una notable evolución**. Junto con el modelo inicial centralizado, y para dar respuesta a los síntomas de crisis y agotamiento que presenta, **surgen otras fórmulas de descentralización territorial del poder, con una descentralización de carácter administrativo** con entes territoriales dotados de órganos propios; descentralización administrativa que hay que diferenciar de la descentralización política (también llamada autonomía política). Sintéticamente, podemos decir que **el Estado unitario con descentralización administrativa** es el Estado que, pese a haber un solo centro con pleno poder político y poder legislativo, **reconoce una cierta capacidad de autoadministración a los entes territoriales** (municipios, departamentos, provincias o regiones), **para decidir la manera de aplicar en su territorio las decisiones tomadas por el poder central**; los órganos de estos entes territoriales son elegidos por los ciudadanos y disponen de capacidad de decisión administrativa y potestad reglamentaria. En estos tipos de Estado **se descentralizan la Administración y la decisión administrativa, pero no la decisión política**.

La **autonomía política** significa ir más allá en el proceso descentralizador y **distribuir la capacidad de decisión política y la potestad legislativa entre los órganos centrales del Estado y los órganos territoriales**. En este tipo de

Estado, se mantiene una única constitución, pero junto a los órganos generales del Estado **se crean unos entes políticos territoriales con capacidad no tan solo para autoadministrarse, sino también para autogobernarse**, es decir, **con capacidad para establecer** (dentro de su ámbito de competencias) sus propias leyes y, por lo tanto, **sus propias orientaciones políticas**. Este tipo de Estado **surge con la Constitución de la Segunda República española (1931)**, que crea el llamado Estado integral, en un intento de encontrar una fórmula a medio camino entre el Estado unitario y el federal. El modelo de la Segunda República española **sirvió de inspiración para el Estado regional previsto para la Constitución italiana de 1947**, a pesar de que solo se empezó a desplegar a partir de los años setenta; también hay elementos de estos tipos de Estado regional en Bélgica y en Portugal.

A pesar de algunos parecidos entre este tipo de estados con autonomía política y el Estado federal actual, se mantienen ciertas diferencias: por un lado, los entes territoriales no tienen un poder constituyente propio e independiente, no participan como tales en la formación de la voluntad estatal ni en la reforma de la constitución y, por otro lado, y quizá más importante todavía, están sometidos a controles mucho más rigurosos que los de los estados federados. Sí hay una cierta coincidencia entre los estados con descentralización política y los estados federales en los **motivos que pueden impulsar estos tipos de organización territorial del poder**:

- **motivos técnicos o de eficacia** (cuanto más cerca se viven los problemas, mejor se pueden conocer, en toda su complejidad, y se pueden resolver mejor);
- **motivos democráticos** (acercar al pueblo las instancias desde donde se toman las decisiones políticas posibilita una participación mayor y más directa en la gestión pública y un control mayor y más eficaz; y la participación y el control son la base de la democracia), y
- **motivos de respeto a las naciones o nacionalidades** diversas que puede haber dentro del Estado (el reconocimiento de su existencia y la capacidad de autogobernarse en determinadas materias puede facilitar la convivencia a los estados plurinacionales, como son la mayoría de los estados hoy, aunque no lo reconozcan constitucionalmente).

2) El Estado federal

Surge con la Constitución de Estados Unidos de América de 1787, fruto de un pacto entre varios estados preexistentes (las antiguas colonias) que deciden integrarse para crear un Estado nuevo (el Estado federal), que es común a todos; estos estados independientes que se federan ya estaban asociados bajo la estructura de una confederación. Así pues, **el origen del Estado federal se encuentra en el pacto, un pacto entre iguales**, entre varios estados soberanos que deciden la creación, por medio de una constitución, de una nueva en-

tividad (el Estado federal) en la que se integrarán todos ellos y a la cual delegarán algunas competencias (las que quieren ejercer conjuntamente, como por ejemplo defensa, relaciones internacionales, comercio, pesas y medidas, o la moneda). El resto de las competencias se las reservan los estados miembros: gracias a la cláusula llamada residual (que funcionaba a favor de los estados miembros), se consideraba que todas las competencias que la constitución no atribuía explícitamente al Estado federal les pertenecían.

Así, tal y como sintetizan Enric Fossas y Joan Lluís Pérez Francesch (*Lliçons de Dret Constitucional*, op. cit., págs. 174-176), **el Estado federal es, pues, un «Estado de estados» en el que el poder político se ejerce desde dos instancias: la instancia central (Federación), que dispone de unos órganos propios (parlamento, presidente, tribunales), los cuales ejercen sus funciones sobre todo el territorio del Estado federal; y la instancia territorial (estados miembros), que dispone cada una de una constitución propia, de una organización política propia y de unos poderes políticos propios que ejercen solo sobre el territorio del Estado miembro. No hay solo una división clásica funcional (horizontal) del poder (legislativo, ejecutivo, judicial), de acuerdo con el principio del Estado de derecho, sino también una división territorial (vertical) que hace que aquel poder (ya dividido) sea también repartido territorialmente.**

El Estado federal supone, pues, un reparto del poder que se lleva a cabo precisamente por medio de la norma que lo crea, la constitución, la cual articula técnicamente una distribución de competencias entre la federación y los estados miembros atribuyéndoles respectivamente unos ámbitos de poder (legislativo, ejecutivo, judicial) dentro de los cuales pueden actuar libremente. **Esto genera una pluralidad de centros de decisión política que, dentro del campo de competencias que tienen atribuido, pueden determinar sus propias orientaciones adoptando distintas soluciones frente a los mismos problemas.**

Los estados miembros, debido al origen (pacto) del Estado federal, no tan solo mantienen un ámbito de poder político garantizado constitucionalmente que les permite ejercer unas competencias sobre su territorio, sino que **disponen de un poder de participación en la voluntad del Estado federal**, es decir, que pueden tomar parte en las decisiones adoptadas por los órganos que ejercen el poder sobre todo el territorio. **La manifestación más importante de esta participación es la existencia dentro del parlamento federal de una segunda cámara (el senado), en la que están representados directamente los estados miembros (mediante, por ejemplo, delegados de sus órganos de Gobierno). Otra manifestación del poder de participación de los estados miembros la encontramos en la reforma constitucional; por ejemplo, para reformar la Constitución de Estados Unidos hace falta aún la aprobación de las tres cuartas partes de los parlamentos de los estados federados. Asimismo, en este federalismo inicial, los estados miembros tenían un poder consti-**

tuyente muy amplio para darse y reformar su propia constitución y, en consecuencia, podían tener incluso formas de Estado y de gobierno diferentes en cada Estado miembro (como sucedió en Alemania a finales del siglo XIX).

Así pues, en contraposición al Estado unitario, **el Estado federal se basa en tres principios: pluralidad** (de centros de poder), **diversidad** (de normas y orientaciones políticas) y **descentralización o no centralización** (distribución territorial de la capacidad de decisión). Aun así, como remarcan Fossas y Pérez Francesch, **el Estado federal combina los elementos anteriores con la unidad**: continúa siendo una unidad de poder que actúa como tal de cara al exterior (en relación con los otros estados), que mantiene unas estructuras unitarias de cara al interior (ejército, moneda, sistema económico, aduanas, comunicaciones, símbolos) y que dispone de unos órganos que ejercen algunas competencias sobre todo el Estado federal y que, por lo tanto, adoptan las mismas soluciones para todo el territorio.

El modelo de Estado federal nacido en Estados Unidos de América fue adoptado posteriormente en el continente europeo por Suiza (1848, a pesar de que Suiza todavía se denomina Confederación, tal y como indica su nombre: Confederación Suiza), Alemania (1871) y por algunos países iberoamericanos (México, Brasil o Argentina, entre otros), pero hoy día también encontramos estados federales en África (por ejemplo, en Camerún o la República Sudafricana) y en países de Asia, como la India o Malasia.

El esquema inicial de Estado federal también ha experimentado una profunda evolución (como el modelo de Estado unitario), igualmente por distintas razones: consolidación del Estado social, homogeneización de las sociedades, conveniencias del sistema económico, etc. A grandes rasgos, se podría decir que la evolución del modelo federal ha tenido lugar por medio de tres fenómenos:

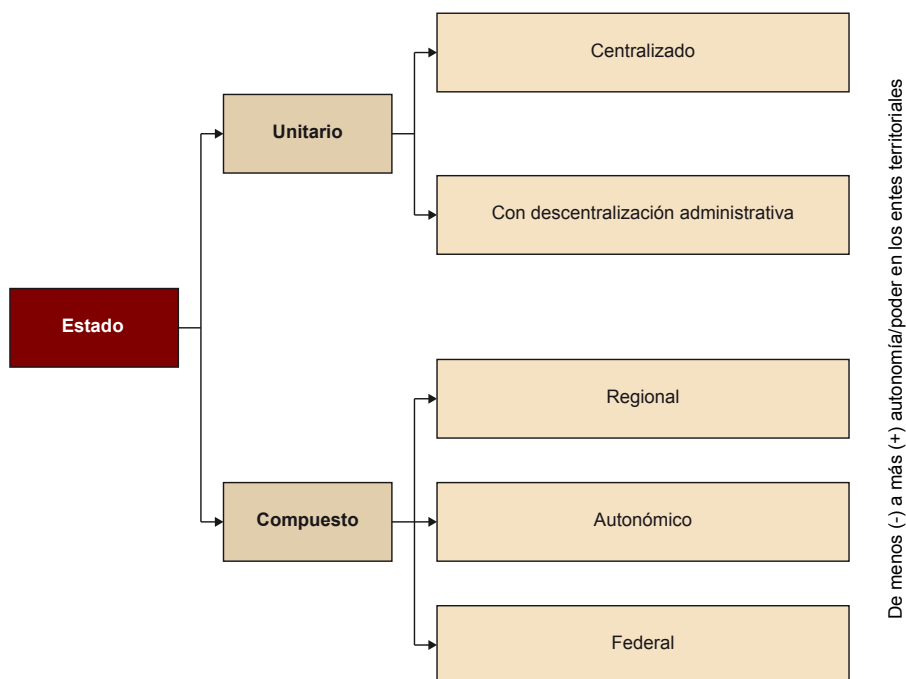
- la centralización, que se manifiesta en el incremento de competencias de la federación;
- la disminución de la participación de los estados en la formación de la voluntad federal (por el cambio en la composición y las funciones de las segundas cámaras, o por la exclusión de los estados miembros del poder de reforma constitucional), y
- por las técnicas del denominado *federalismo cooperativo*, que parte de la necesidad del ejercicio conjunto de funciones sobre los mismos ámbitos.

Por lo tanto, **el esquema tradicional tanto del Estado federal como del Estado unitario ha sufrido una serie de alteraciones y matices durante estos dos últimos siglos** a causa, por un lado, de la evolución experimentada por estas dos formas de estado en los países donde surgieron (EE. UU. y Francia) y, por otro lado, por el hecho de que estos modelos de organización territorial

fueron adoptados por muchos estados que, a su vez, introdujeron características específicas propias. El Estado federal de EE. UU. o el Estado unitario centralista francés sirvieron de modelo a otros muchos estados, que «imitaron» total o parcialmente estos modelos históricos, lo que dio lugar en la práctica a muchas concreciones diferentes.

Para poder englobar todos los tipos de organización territorial que hay hoy día en los diferentes estados y para explicar mejor la evolución de los dos modelos históricos (unitario y federal), **actualmente una parte de la doctrina ha propuesto una nueva categoría, el Estado compuesto, que incluiría todos los estados que reconocen varios centros de poder político (el Estado federal, el autonómico y el regional).**

Modelos de organización territorial del poder



Así, dejando de lado el sistema confederal (que no es propiamente una forma de organización territorial de un Estado, sino una forma de organización internacional formada por varios estados), **actualmente podemos considerar que hay dos grandes modelos de organización territorial: el Estado unitario**, en el que se parte de un criterio de organización unitaria en el que **solo se reconoce un único centro de poder político**, y el **Estado compuesto**, que puede ser federal, autonómico o regional, pero parte de un criterio de organización pluralista **en el que se establecen varios centros de poder político**. El Estado unitario sería, pues, aquel en el que hay un solo nivel de instituciones políticas (un parlamento, un Gobierno y unos órganos jurisdiccionales) que concentran todo el poder del Estado, de modo que todos los ciudadanos de todo el territorio son vinculados por las mismas decisiones de Gobierno. Por el contrario, **en el Estado compuesto hay dos instancias territoriales de poder, cada una dotada de sus propias instituciones de decisión política,**

de manera que las normas que cada una produce se proyectan sobre ámbitos propios y diferenciados. Así, el Estado en su conjunto tiene un parlamento, un Gobierno y un poder judicial que toman decisiones que afectan a todo el territorio y todos los ciudadanos del Estado, pero junto con este centro de poder conviven una pluralidad de otros centros de poder en cada uno de los territorios que componen el Estado. Estos entes territoriales son organizados, como mínimo, por un parlamento y un Gobierno que aprueban normas a las cuales solo están sujetos los ciudadanos de su territorio. **Las instancias territoriales no están subordinadas a las instancias centrales, sino que disfrutan de autonomía política, es decir, tienen capacidad de autogobierno, capacidad legislativa,** que les permite desarrollar una política propia y diferente de las otras en las materias en las que tienen competencia.

1.4. El modelo de justicia constitucional

Junto con las decisiones fundamentales sobre la forma de Estado, forma de gobierno y organización territorial, cualquier constituyente que quiera hacer una constitución como norma suprema y que, por lo tanto, adopte un concepto de constitución racional-normativo, prácticamente está obligado a establecer uno u otro sistema de justicia constitucional. Porque la justicia constitucional busca asegurar el respeto a la constitución y, por lo tanto, garantizar la aplicación real de todas las decisiones del constituyente. Por eso, no nos tendría que extrañar que un jurista como Hans Kelsen considerase el capítulo sobre las garantías de la constitución y de la Administración como el núcleo jurídico de la Constitución⁶.

⁽⁶⁾Según su discípulo y biógrafo Rudolf Aladár Métaál, Kelsen veía en el principio de la constitucionalidad de la legislación y en el de la legalidad de su ejecución la garantía más efectiva de la constitución y el sello característico de la Constitución Federal austríaca (R. Aladár, 1976. *Hans Kelsen, vida y obra*. México: UNAM).

Como hemos visto al final del módulo 1, **la primera decisión que hay que tomar es optar por un control** llevado a cabo por uno o más de un órgano jurisdiccional o bien por uno o más de un órgano político. **Si el control es eminentemente político, también hay varias opciones,** porque este control se puede encomendar a varios tipos de órganos, como por ejemplo un órgano específicamente creado para esta función (como es el caso francés) o una comisión del parlamento (como ocurre con algunos países nórdicos), o puede ser una prerrogativa del jefe del Estado, aunque compartida con otros órganos (Grecia, Polonia o Perú). **Dentro del sistema jurisdiccional también hay varias opciones,** porque el control puede estar concentrado en manos de un solo órgano (tribunal constitucional), o ser un control difuso (ejercido por todos los integrantes del poder judicial). **E incluso puede haber sistemas como los mixtos** (que nacen de una fusión o mixtura de otros sistemas, como es el caso de Brasil) y **los duales o paralelos**, en los que el control de constitucionalidad de las leyes ha sido encargado simultáneamente a la jurisdicción ordinaria y a un tribunal constitucional (es el caso de países como por ejemplo Perú o Portugal, o también como Grecia que, además, ha optado por un Tribunal Supremo Especial que no es un órgano permanente, sino que se constituye cada vez que aparece un asunto del que es competente y se disuelve después de resolverlo).

En el módulo 1, además de explicar las razones que más peso suelen tener a la hora de elegir un sistema u otro de justicia constitucional, hemos sintetizado las características principales de los tres grandes sistemas originarios (sistema americano o modelo difuso, sistema europeo o modelo concentrado, y sistema francés o de control político) y su evolución, hemos apuntado también la existencia de dos sistemas más que se pueden denominar derivados (sistema mixto y sistema dual o paralelo) y hemos remarcado que las opciones concretas que han adoptado las constituciones hoy día todavía son más variadas porque los constituyentes han adoptado algunos elementos o características de otro sistema diferente al que teóricamente pertenecen. Por eso, lo que ahora **interesa destacar** es, por un lado, **la importancia de la función de control de constitucionalidad de la ley y también de todos los procesos de defensa de la constitución** (como por ejemplo los conflictos entre entes territoriales o entre órganos constitucionales, o la protección de los derechos fundamentales), porque son la última garantía del cumplimiento efectivo de la constitución y, por lo tanto, garantía del Estado de derecho y de la democracia; **pero, por otro lado, también hay que tener presentes los peligros de un ejercicio ilegítimo de estas funciones**. Así, tanto si el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes es un órgano político como un tribunal constitucional o, en última instancia, un tribunal supremo (en el sistema de control difuso), este órgano no tan solo es el supremo intérprete de la constitución, sino también el órgano supremo de interpretación de la ley, en conformidad con la constitución. El peligro es doble: **puede incurrir en la ilegitimidad de ocupar el papel del poder constituyente**, porque encuentre un significado en los preceptos constitucionales no justificado en los métodos de interpretación jurídica; **y también puede incurrir en la ilegitimidad de ejercer la función de legislador** y, por lo tanto, invadir la función reservada constitucionalmente al poder legislativo, al interpretar la ley no en conformidad con la constitución, sino de acuerdo con parámetros que no sean los constitucionales. Y es grave y antidemocrático que la justicia constitucional sustraiga inconstitucionalmente la capacidad de hacer leyes a la mayoría parlamentaria (que representa una mayoría de la ciudadanía) y lo es también que no ampare a la minoría contra el abuso de una mayoría que aprueba leyes que vulneran derechos de la minoría garantizados por la constitución. Por lo tanto, la función de la justicia constitucional no solo es muy importante, sino muy difícil de llevar a cabo porque requiere encontrar un equilibrio entre el exceso y el defecto en la tarea de control de constitucionalidad de la ley y de interpretación de la constitución. Porque, del mismo modo que hay que subrayar que la justicia constitucional (sea cual sea el sistema adoptado) **tiene una plena legitimidad democrática de origen** por el hecho de haber sido incluida por el mismo poder constituyente en la constitución (sobre todo si han sido reguladas con precisión sus funciones, lo que no ocurriría, por ejemplo, con el TS de EE. UU.), también **hay que advertir del peligro de que en sus actuaciones se extralimite en cuanto a sus funciones y pueda incurrir en actividades que escapen de la legitimidad democrática**.

Tradicionalmente **se han utilizado varios mecanismos para intentar evitar o minimizar estos peligros**, como la actuación a instancia de parte, y toda una serie de principios y técnicas especialmente pensados para procurar garantizar la independencia, neutralidad, imparcialidad y la alta cualificación técnica de los miembros de estos órganos. Así, son habituales algunas garantías como la autonomía funcional, organizativa y presupuestaria de estos órganos; la inamovilidad de sus miembros (que no pueden ser trasladados, suspendidos ni cesados, si no es por las causas previstas por la ley); algunas causas de inelegibilidad o prohibiciones (como la de ser empleados, directivos o simplemente miembros de partidos políticos); un amplio régimen de incompatibilidades o unos mandatos largos (o, como mínimo, más largos que el de las instituciones que los han designado), que llegan en algunos casos a ser cargos vitalicios (como los miembros del TS en EE. UU. o los casos de Bélgica y Austria, a pesar de que con un límite de edad de 70 años). También es frecuente la exigencia de requisitos como por ejemplo una determinada formación, experiencia y prestigio profesional o unas mayorías reforzadas (en los casos en los que todos o una parte de sus miembros sean elegidos por el parlamento) que persiguen un elevado consenso no solo sobre su calidad técnica y el resto de los requisitos que se exijan, sino en conjunto sobre su idoneidad para ejercer el cargo. En esta misma línea de buscar la idoneidad y la transparencia (y para evitar que una mayoría política pueda imponer cualquier candidato), también están las comparecencias o audiencias (*hearings*), que pueden tener un carácter meramente informativo (como, por ejemplo, los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional español propuestos por el Congreso y Senado) o ser decisorias (como por ejemplo en EE. UU., donde el candidato al TS propuesto por el presidente del país puede ser sometido a un intenso escrutinio ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado sobre su formación jurídica, su trayectoria profesional o sus convicciones sobre los temas más diversos, y la propuesta presidencial únicamente prosperará si consigue la mayoría simple del pleno del Senado⁷). Sin embargo, en estos casos de las comparecencias y también en el de muchos de los otros mecanismos previstos, **el grado de eficacia en la búsqueda de independencia, imparcialidad y cualificación técnicas no depende solo de cómo se configuren jurídicamente, sino sobre todo de la cultura institucional y política de cada país**, que determina que un mismo requisito cumpla o no la función para la que ha sido pensado. Así, por ejemplo, la mayoría reforzada de tres quintas partes del Congreso y Senado fijada por la Constitución española perseguía conseguir un alto grado de consenso para elegir los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional; ahora bien, la práctica política ha llevado en muchos casos a saltarse esta voluntad del constituyente y pervertir el sentido de este requisito, haciendo que los dos grupos parlamentarios más grandes se repartan por «cuotas» los magistrados que les tocan a cada cual, sin consensuar nada más que el voto favorable a «su» candidato, a cambio de hacer lo mismo con el del otro grupo. Y es importante tener presente que **del correcto funcionamiento de la justicia constitucional depende no solo su prestigio sino, en último término, la calidad democrática del sistema jurídico**. Y si el viejo problema de quién controla el último controlador es siempre una cuestión de difícil solución,

⁽⁷⁾ Desde mediados del siglo XIX, la gran mayoría de candidatos al TS han sido personas cercanas al mismo partido que el presidente que los proponía, y el Senado ha confirmado al 90 % de los candidatos cuando el partido del presidente controlaba esta Cámara, pero menos del 60 % cuando la mayoría correspondía al otro partido.

si es que la tiene, sin una profunda cultura política democrática es seguro que será un problema mal resuelto que puede generar otros muy graves, demolidores de los fundamentos del Estado democrático de derecho.

2. Las opciones básicas de la Constitución española

En la primera parte de este módulo, hemos visto las cuatro grandes decisiones que tiene que tomar cualquier constituyente y las principales opciones que hay a la hora de tomar estas decisiones fundamentales. En la segunda parte de este módulo, analizaremos cuáles han sido las opciones elegidas por el constituyente español de 1978: el Estado social y democrático de derecho, el sistema parlamentario en su variante monárquica, el Estado autonómico y un tipo de justicia constitucional jurisdiccional y concentrada que tiene el Tribunal Constitucional como garantía de la supremacía normativa de la Constitución.

Entre los principios constitucionales, el carácter social y democrático de derecho del Estado (art. 1.1 CE), la monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE), los principios de unidad, autonomía y solidaridad (art. 2) y el principio de supremacía de la Constitución (art. 9.1) son principios que podemos considerar *básicos* porque son el fundamento de todo el sistema constitucional español y los que más lo definen; configuran el *núcleo esencial* de la Constitución española y expresan las decisiones fundamentales de los constituyentes, las opciones políticas básicas de la Constitución española de 1978.

Estos principios constitucionales básicos se encuentran en el **título preliminar de la Constitución** (que en el texto del anteproyecto se denominaba *Principios generales de la Constitución*) y están desarrollados en uno o más de los diez *Títulos de la Constitución*. Así, la supremacía de la Constitución, que se garantiza también con la rigidez constitucional (título x, de la reforma constitucional), se encomienda sobre todo al TC (título xi), porque sus funciones no se limitan al control de la constitucionalidad de las leyes, sino que también se le confía la garantía de la división de poderes (horizontal y vertical) y la tutela de los derechos fundamentales, que en el fondo son tres concreciones de la tarea fundamental de garantizar la supremacía de la Constitución. Asimismo, los principios de unidad, autonomía y solidaridad se desarrollan principalmente en el título viii (de la organización territorial del Estado) y la monarquía parlamentaria, fundamentalmente en el título v (de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales). En cambio, la fórmula con la que se define la forma de Estado (el Estado social y democrático de derecho) se despliega de una manera más transversal a lo largo de toda la Constitución.

2.1. La forma de Estado: el Estado social y democrático de derecho

2.1.1. Tres calificativos para un concepto unitario

El artículo primero de la Constitución española de 1978 utiliza tres calificativos para definir la forma de Estado (social, democrático, de derecho) que, como hemos visto, no son incompatibles, sino plenamente complementarios.

La fórmula que figura en el art. 1.1 de la Constitución española, el Estado social y democrático de derecho (que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político), **es un concepto unitario**, que algunos autores, como Francesc de Carreras, consideran una variante del Estado de derecho con unas dimensiones, la democrática y la social, que lo reinterpretan y se corresponden con las del Estado contemporáneo occidental.

No hay precedentes en la historia constitucional española con una redacción⁸ igual o análoga, pero sí que se nota la influencia de algunas constituciones aprobadas después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la alemana y la francesa.

«La República Federal de Alemania es un Estado federal, democrático y social». «La orden constitucional de los estados miembros tendrá que responder a los principios del Estado de derecho republicano, democrático y social, en el sentido de la presente Ley fundamental» (arts. 20 y 28 de la Ley fundamental de Bonn de 1949). También contiene una fórmula parecida a la española el primer inciso del art. 1 de la Constitución francesa de 1958: «Francia es una República indivisible, laica, democrática y social». Sin embargo, el art. 1.1 de la Constitución española invierte el orden de los calificativos de la forma de Estado de las constituciones francesa y alemana, en una sucesión que puede considerarse cronológicamente exacta y que remarca cuál es el último estadio logrado, porque, como hemos visto, posee un carácter acumulativo, de tal manera que cada nueva etapa no anula, sino que integra las consecuencias de la anterior.

La fórmula resultante no constituye solo una simple yuxtaposición de los tres elementos (social, democrático, de derecho), sino que origina una nueva forma de Estado en la que cada uno de estos tres componentes influyen y son influidos por los otros, están vinculados entre ellos por relaciones directas e indirectas que necesariamente obligan a reinterpretar sus principios y presupuestos por los de los otros, de forma que el conjunto de la fórmula tiene un alcance normativo diferente de la simple suma de sus elementos integrantes (Ángel Garrorena).

Siguiendo a Gerpe Landín, el concepto unitario de Estado social y democrático de derecho queda prolongado por la implicación recíproca de los tres términos que lo componen:

- El carácter *social* del Estado democrático supone que la participación no pueda agotarse en la participación política en sentido estricto, sino que se tenga que extender a

Lectura complementaria

F. de Carreras (2003). «El Estado y la Constitución». En: *Sistema constitucional español* (págs. 84-102). Barcelona: UOC.

⁽⁸⁾Solo la Constitución de 1931, la primera que establece un sistema democrático en el Estado español, recoge una fórmula con algún parecido: en su art. 1 se declaraba que «España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia».

Lectura complementaria

A. Garrorena Morales (1984). *El Estado español como Estado social y democrático de Derecho*. Madrid: Tecnos.

Lectura complementaria

M. Gerpe (2000). «Principios estructurales de la Constitución española». En: M. Gerpe (coord.). *Derecho Constitucional I* (págs. 18-39). Barcelona: UOC.

ámbitos sociales, económicos y laborales; y el adjetivo social también afecta al contenido del Estado de derecho porque no solo diluye el abstencionismo estatal y económico con alternativas intervencionistas, sino que introduce cambios tanto en el catálogo como en la eficacia y la interpretación de los derechos fundamentales, de las libertades públicas y de los deberes de la ciudadanía.

- El carácter *democrático* del Estado social matiza el intervencionismo estatal en la sociedad y en la economía, cuando por ejemplo obliga a desarrollar las políticas públicas respetando a la audiencia y la participación de los interesados, y también por el hecho de que las organizaciones sociales (partidos, sindicatos, asociaciones empresariales) han de tener una estructura interna y un funcionamiento democráticos. Asimismo, el principio democrático tiene consecuencias fundamentales sobre la concepción liberal del Estado de derecho, desde la exigencia de legitimar popularmente el derecho del Estado con el reconocimiento de la soberanía popular y el sufragio universal, hasta la garantía e integración del pluralismo, que en su vertiente política es reconocido como valor superior del Estado.
- El carácter de Estado *de derecho*, por un lado, puede actuar como freno ante las tentaciones totalitarias de la mayoría, garantizando el estatus de la minoría, limitando la actuación del legislador y disciplinando jurídicamente la elaboración de las decisiones de los poderes públicos; pero el respeto a los presupuestos del Estado de derecho también actúa como garantía de la libertad de las personas ante el intervencionismo estatal y obliga a que las políticas públicas se tengan que elaborar y aplicar respetando los principios que ordenan la sujeción de todos los poderes públicos al derecho.

Así, por ejemplo, el mandato del art. 9.3 CE a los poderes públicos de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los cuales se integra sean reales y efectivas» y de «remover los obstáculos que impidan su plenitud» es limitado por la garantía de los derechos a la propiedad privada y la herencia (art. 33.1 CE), que aun así también son delimitados por «la función social» que fijará el contenido por ley (art. 33.2 CE) y por «la utilidad pública y el interés social» que pueden justificar la expropiación de bienes o derechos, con la correspondiente indemnización (art. 33.3 CE), porque tal y como establece el art. 128.1 CE, «toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual sea la titularidad, queda subordinada al interés general». Otro ejemplo lo encontramos en la libertad de información (art. 20.1.d CE), que ya no se concibe solo como un derecho que solo obliga al Estado a una actitud pasiva, de no injerencia, sino que la Constitución prevé la existencia de medios de comunicación públicos cuyo pluralismo tiene que ser garantizado por la ley, asegurando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos (art. 20.3 CE).

En síntesis, la Constitución define el actual Estado español como:

«Un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.»

Un concepto unitario formado por tres elementos complementarios que se influyen mutuamente y que, por lo tanto, hay que interpretar de manera sistemática e integral. Aun así, para procurar una exposición lo más ordenada y comprensible posible, a continuación analizaremos por separado estos componentes, siguiendo el mismo esquema que nos sirvió para explicar cada uno de estos conceptos.

2.1.2. El Estado de derecho en la Constitución española

Hemos visto que no todo Estado *con* derecho es un Estado *de* derecho, y que solo merece este nombre el Estado que responde a tres presupuestos: la división de los poderes como principio de organización del Estado; la sujeción de la actuación de los diferentes órganos del estado al derecho (a la ley y a la constitución), y la proclamación y la garantía de unos derechos y libertades que pertenecen a todas las personas por igual.

1) La división de los poderes como principio de organización del Estado

La Constitución española no recoge explícitamente el principio de separación de poderes, pero se tiene que entender que está implícito en la cláusula del Estado de derecho del art. 1.1 CE y, además, la Constitución incorpora una pluralidad de divisiones del poder que supera el esquema tripartito originario de Montesquieu. Así, **en primer lugar, se establece la división entre el poder constituyente** («el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado», art. 1.2 CE) **y los poderes constituidos**, a los cuales la Constitución reparte unas funciones y establece unas relaciones. **En segundo lugar, estos poderes constituidos son divididos territorialmente** (la llamada *división vertical* del poder), tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo (o de Gobierno), aunque no en cuanto al poder judicial, porque como veremos es un poder único en el Estado de las autonomías. **En tercer lugar, la llamada división horizontal del poder**, es decir, **la división funcional** entre una pluralidad de órganos generales del Estado, es recogida en la Constitución, pero **de una manera más compleja que la tripartición clásica** entre legislativo, ejecutivo y judicial. Así, la Constitución establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa (art. 66 CE), el Gobierno, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE), y los jueces y magistrados, la potestad jurisdiccional (art. 117.1 CE), pero **la misma Constitución incrementa la complejidad de la estructura de los poderes constituidos creando otros órganos con importantes competencias** propias que no pueden ser integrados en ninguno de los tres poderes o funciones, como la Corona, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial (que no forma parte del Poder Judicial, porque no es un órgano que tenga potestad jurisdiccional). Además, algunos de estos órganos no hacen solo una función ni las que llevan a cabo son exclusivas de los mismos, como por ejemplo el Gobierno, que además de una función ejecutiva también tiene la potestad de aprobar normas con rango de ley y una función de dirección política que comparte con las Cortes Generales; o por poner otro ejemplo, el TC, como veremos, tiene una cierta incidencia en la función legislativa como legislador negativo o, en algunos casos, cuando llega a actuar como legislador positivo.

Y es precisamente al TC al cual la Constitución española atribuye la **garantía última de la separación de poderes**, de las distintas divisiones del poder, porque es el que dispone de la competencia exclusiva para decidir con carácter inapelable sobre si los otros órganos del Estado han hecho un uso de sus

competencias ajustado a la Constitución. Por eso es tan importante la función del TC, porque es **la última garantía** de la división de poderes y, en definitiva, **del cumplimiento de la Constitución**. Y, por ser la última garantía, no tiene ningún otro órgano que lo controle, más allá de la crítica de la ciudadanía, de la academia (principalmente la universidad) o de los medios de comunicación.

2) La sujeción de la actuación de los diferentes órganos del Estado al derecho (a la ley y a la Constitución)

Ya hemos visto que la necesidad de sujetar todos los poderes del Estado al derecho, incluso el poder legislativo, exige la existencia de una norma superior a todas las demás: la constitución. **El principio de constitucionalidad significa la sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución como norma suprema.** El art. 9.1 CE recoge este principio y establece que la Constitución española tiene el carácter de norma jurídica y de norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la cual todos los poderes públicos «quedan sujetos». **El poder legislativo está limitado por lo que establece la Constitución**, tanto respecto a los procedimientos (por ejemplo, los de aprobación de las leyes, título III), como materialmente (está sujeto a los contenidos sustantivos de la Constitución, a todos sus principios y normas materiales, como por ejemplo los derechos fundamentales). La sujeción del legislador, estatal y autonómico, se garantiza mediante los procedimientos de inconstitucionalidad que son competencia del TC (arts. 161.1a y 163 CE). **Igualmente, los gobiernos (estatal, autonómicos y locales) y las administraciones que dependen del mismo están también vinculados a la Constitución**, y por eso los reglamentos y los actos administrativos están sujetos a la norma suprema y es posible anularlos cuando la contradigan. **También los jueces están sujetos a la Constitución**, porque no solo están obligados a interpretar todo el ordenamiento jurídico en conformidad con la Constitución (como se ha explicado en el módulo 1) sino que, además, antes de aplicar cualquier norma jurídica en un juicio tienen que analizar su constitucionalidad. Si el órgano judicial la considera contraria a la Constitución, puede decidir inaplicarla o incluso declarar su nulidad, siguiendo el procedimiento previsto (explicado en el módulo 2), solo si se trata de una norma con rango reglamentario; en cambio, si se trata de una ley o norma con valor de ley, lo que tiene que hacer el juez o tribunal es plantear una cuestión de inconstitucionalidad al TC (art. 163 CE), como explicaremos más adelante. La sujeción de los jueces al derecho se garantiza y controla por medio de los recursos ante la misma jurisdicción ordinaria y, en el momento en que afecta a derechos fundamentales, por medio del recurso de amparo ante el TC. Y, además del poder legislativo, ejecutivo y judicial, **todos los otros órganos, instituciones o poderes públicos (del Estado central o de ámbito territorial) están también sujetos a la Constitución**: Corona, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, fuerzas armadas, policía, diputaciones, ayuntamientos, etc., e incluso el mis-

mo Tribunal Constitucional que, precisamente por el hecho de ser el intérprete supremo de la Constitución, también está sujeto a ella (sometido *solo* a la Constitución y a la LOTC, tal y como especifica el art. 1.2 de la LOTC).

El artículo 9.3 CE establece el principio de legalidad y toda una serie de principios vinculados directamente a los de legalidad y constitucionalidad **que quieren hacer efectiva la subordinación al derecho** de todos los poderes públicos y **garantizar la seguridad jurídica**:

- **El principio de legalidad**: significa que todos los poderes públicos están sometidos a la ley, que expresa la voluntad popular dictada por el parlamento (el órgano que representa al pueblo). Ya hemos visto que hay dos versiones del principio de legalidad, que a lo largo del siglo XIX se configuraron en Francia y Alemania como dos maneras diferentes de articular la vinculación del reglamento a la ley: o bien entender la ley como el fundamento previo de cualquier actuación administrativa (vinculación positiva), o bien entender que la ley no es el fundamento, sino tan solo un límite a la actividad de los poderes públicos (solo los vincula negativamente). En el Estado español, **se ha adoptado el criterio de vinculación positiva del reglamento a la ley, que implica que**:
 - se adopta **una definición formal de ley** (cualquier materia se puede regular por ley, mientras sea aprobada por el parlamento con este carácter de acuerdo con la Constitución);
 - se establece **la primacía de la ley** sobre las normas reglamentarias (art. 97): la ley es jerárquicamente superior a cualquier otra norma jurídica (excepto la Constitución), y la ley es la que habilita al Gobierno para aprobar reglamentos (fijando unas directrices básicas que el reglamento tendrá que concretar), pero, sin embargo, el TC ha admitido la existencia de reglamentos independientes, como hemos visto en el módulo 2;
 - se establece **una reserva de ley**: la Constitución prevé que determinadas materias solo pueden ser reguladas por ley formal, de tal manera que se excluye que puedan ser reguladas por el Gobierno (ni por reglamento ni siquiera por decreto ley o mediante una delegación legislativa que le permitiese al Gobierno aprobar un decreto legislativo);
 - **no se prevé la existencia de una reserva reglamentaria** (una reserva material a reglamento), y
 - **el Gobierno, la Administración pública y los jueces están sometidos a la ley**: el Gobierno «ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes» (art. 97 CE), la Administración también tiene que actuar «con plena sumisión a la ley y al derecho» (art. 103.1 CE) y los jueces y magistrados que integran el poder judicial tienen que administrar justicia «sometidos únicamente

al imperio de la ley» (art. 117.1 CE). **El respeto del Gobierno y la Administración a principios de legalidad se controla por diferentes mecanismos, tanto internos a la misma Administración** (mediante, por ejemplo, el control jerárquico u organismos de control interno) **como externos al aparato administrativo**; y en este caso, pueden ser de tipo político (el control parlamentario), institucional (como el Defensor del Pueblo o como el Tribunal de Cuentas) o jurisdiccional (órganos judiciales y el TC). Son estos últimos los mecanismos más importantes de control de la legalidad en el sistema jurídico español, y aunque el TC incide también en esta función, **el control ordinario lo ejerce la jurisdicción contenciosa administrativa**: «los Tribunales controlan la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y su sumisión a los fines que la justifican» (art. 106 CE); la Constitución pone en manos de los ciudadanos la facultad de activar este control configurando como fundamental el derecho a «obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos» (art. 24.1 CE). Y **la sumisión de los jueces a la ley los condiciona a obedecerla sin poder dejar de aplicarla**, y se garantiza del mismo modo que hemos visto en relación con el principio de constitucionalidad (por medio de los recursos ante la misma jurisdicción ordinaria, y se puede recurrir en última instancia dentro del Estado al TC solo si se han vulnerado derechos fundamentales).

- **La jerarquía normativa**: es consecuencia del principio de constitucionalidad y de legalidad y, como hemos visto en el módulo 2, implica estructurar el ordenamiento jurídico en una escala de rangos o niveles, de tal manera que **la norma de rango inferior no puede contradecir la superior**. No es un criterio de relación entre normas de diferentes ordenamientos, sino una de las cuatro grandes reglas para encontrar la norma aplicable dentro de un mismo ordenamiento. Hemos visto también que, como norma general, el rango deriva del órgano que crea la norma: la CE, el pueblo español; la ley, los representantes de este pueblo, y los reglamentos, el Gobierno, que son los dirigentes elegidos por una mayoría de los representantes del pueblo.
- **La publicidad de las normas**: los destinatarios de las normas han de tener una oportunidad efectiva de conocerlas **mediante un instrumento de difusión general que dé fe de su existencia y contenido** y, tal y como ha reconocido el TC, serían contrarias a este principio las normas que fueran de conocimiento imposible o muy difícil (STC 179/1989). **La publicación asegura la publicidad**. Todas las disposiciones emanadas de los poderes públicos tienen que ser publicadas en los diarios o boletines oficiales (del Estado, de cada comunidad autónoma o provincia); en este sentido, la Constitución prevé la publicación de las leyes (art. 91 CE) y de las sentencias del TC (art. 164.1 CE).

- **La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales:** esto significa que la Constitución no prohíbe la retroactividad de las normas en otros supuestos (STC 8/1982), pero **no resulta adecuado en un Estado de derecho sancionar a alguien por una actuación que, en el momento de hacerla, la ley no la consideraba sancionable.** Interpretando este precepto *a contrario sensu*, se puede entender que la Constitución garantiza también la retroactividad de la ley penal favorable o más beneficiosa para el reo (STC 21/1993).
- **La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos:** esta prohibición **implica que los poderes públicos tienen que actuar con justificación suficiente y deben resolver de manera igual los casos iguales** y, por lo tanto, no pueden actuar arbitrariamente porque sería contrario a la ley. El juicio de arbitrariedad acostumbra a referirse a los actos del Gobierno o de la Administración, pero tal y como lo prevé la Constitución, se extiende a todos los poderes públicos, incluido el poder judicial y también el legislativo, aunque para poder apreciar la presencia de arbitrariedad en la ley, hace falta que se haya producido una falta de proporción entre las finalidades perseguidas y los medios utilizados que implique «un sacrificio excesivo e innecesario de derechos que la Constitución garantiza» (STC 129/1987).
- **La responsabilidad de los poderes públicos:** tienen que asumir la responsabilidad **por las actuaciones que representen una infracción del ordenamiento jurídico;** si estos están obligados a actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes, el incumplimiento de esta obligación debe comportar necesariamente una reacción del ordenamiento jurídico, sancionando a las personas responsables o indemnizando a los perjudicados por su infracción (arts. 106.2 y 121 CE), además de la aplicación correcta del derecho.
- **La seguridad jurídica:** es la **suma de los principios anteriores** (STC 27/1982), de tal manera que los principios recogidos en el art. 9.3 CE podrían agruparse bajo la rúbrica general de seguridad jurídica. Representa **«la expectativa razonablemente fundamentada del ciudadano de cuál debe ser la actuación de poder, en aplicación del derecho»** (STC 36/1991); exige, pues, que los actos del poder sean predeterminables y, por lo tanto, previsibles y que garanticen un trato idéntico en situaciones idénticas; implica una certeza sobre la norma jurídica aplicable (predictibilidad de la norma) y una previsibilidad de la interpretación y aplicación del derecho por los poderes públicos, especialmente la Administración y los jueces. Solo si hay seguridad jurídica los ciudadanos pueden ejercer plenamente sus derechos y defenderlos de manera adecuada. Por lo tanto, **son requisitos para la seguridad jurídica conocer el derecho que tiene que ser aplicado y, en el supuesto de que no fuera así, tener vías de reposición del orden jurídico.** La seguridad jurídica es el concepto que resume todo lo que se busca con el Estado de derecho: hacer efectiva la

supremacía del derecho sobre los poderes (que implica evitar la arbitrariedad y someter a responsabilidad las actuaciones contrarias al derecho) **y garantizar unos derechos y libertades.**

3) La proclamación y la garantía de unos derechos y libertades que pertenecen a todas las personas por igual

Cuando hemos analizado la evolución del Estado constitucional hasta que se constituye en Estado social y democrático de derecho, hemos constatado que en el ámbito de los derechos fundamentales esta evolución ha sido muy grande; las concepciones liberales originarias que partían de unos derechos de autonomía o de libertad ante el Estado en algunos países se fueron enriqueciendo con el reconocimiento de los derechos de participación política y posteriormente con los derechos sociales o prestacionales. **La Constitución española refleja esta evolución en su articulado e incorpora derechos de libertad, de participación política y derechos sociales, pero configura con más precisión y tutela los dos primeros tipos que los derechos sociales.** La regulación del principio social es jurídicamente más débil que la del principio democrático y la del Estado de derecho (M. Gerpe).

Aun así, **la Constitución opta por la configuración de una forma de Estado que tiene los derechos fundamentales como elementos esenciales.** Según ha reiterado el Tribunal Constitucional, **los derechos fundamentales no son solo derechos subjetivos, individuales, sino que tienen una doble naturaleza o doble dimensión: subjetiva y objetiva**⁹ (o axiológica).

⁽⁹⁾Sobre la doble naturaleza de los derechos fundamentales, podéis ver STC 25/1981, de 14 de julio (FJ 5) y STC 53/1985, de 11 de abril (FJ 4), entre otras.

Los derechos fundamentales como derechos subjetivos representan un conjunto de facultades que las personas pueden ejercer para pedir una tutela pública en caso de vulneración por una tercera persona o un poder público. Los derechos subjetivos otorgan la capacidad de reaccionar frente a violaciones de los poderes públicos, los cuales tienen que resarcir a la persona. Hay derechos subjetivos de diferentes tipos, otorgados por los contratos, por la ley o por la Constitución. En este último supuesto están los derechos fundamentales, derechos subjetivos que disfrutan de una protección singular y superior a la de los otros derechos subjetivos creados por la ley.

Los derechos fundamentales son también elementos objetivos del ordenamiento jurídico, es decir, aquello que le da sentido. Son elementos estructurales básicos del ordenamiento, de modo que expresan unos valores esenciales del Estado de derecho, que los ciudadanos y los poderes públicos tienen que respetar. Representan un sistema objetivo de valores. Son fundamento del orden político de la comunidad constituida y, por lo tanto, un elemento estructurador del Estado en tanto que determinan la actuación de los poderes públicos. Y de aquí, también deriva el carácter de derechos irrenunciables.

Por eso, la división del poder del Estado y su limitación subordinando la actuación de todos sus órganos a la ley y a la Constitución se tienen que entender como instrumentos que solo adquieren sentido al servicio del objetivo principal del Estado de derecho: el reconocimiento y la garantía de los derechos y libertades, que son expresión de la dignidad de la persona. En este sentido, como pórtico de todo el catálogo de derechos, la Constitución española establece en el art. 10.1 la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes como fundamentos del orden político¹⁰.

(10) El art. 10.1 CE está situado al comienzo del título I (dedicado a los «derechos y deberes fundamentales»): «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los otros son fundamento del orden político y de la paz social».

La dignidad «inherente a todos los miembros de la familia humana» es el centro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (DUDH), que tuvo una influencia notoria en el articulado de la Constitución española. Desde la DUDH (1948) se podría reinterpretar la evolución de los derechos humanos (desde que fueron concebidos como derechos naturales hasta convertirse en derechos subjetivos contenidos en las constituciones estatales y dotados de garantías jurídicas) como la lucha por el respeto a la plena dignidad de la persona, que sería la finalidad última de los derechos humanos. Así, se podrían entender los derechos humanos como ámbitos concretos de esta dignidad humana, que se han considerado relevantes para protegerlos específicamente: los derechos humanos se habrían ido organizando jurídicamente para proteger los aspectos de la dignidad de la persona que eran vulnerados; por eso, han ido aumentando en el transcurso del tiempo y no siempre son iguales en todos los países.

Como núcleo de todo Estado de derecho, **los derechos fundamentales son irrenunciables**. Sin embargo, en relación con si los derechos fundamentales pertenecen a todas las personas por igual, hay que decir que la titularidad y, en su caso, el ejercicio de los derechos, se puede someter a límites según las circunstancias personales, como por ejemplo los menores de edad, los condenados por sentencia firme, los declarados incapaces o los internados en hospitales psiquiátricos. En otros casos, el hecho de pertenecer a un colectivo puede hacer que no puedan disfrutar de todos los derechos como el resto de los ciudadanos: militares, jueces, policías, etc. Por otro lado, algunos derechos pueden corresponder también a las personas jurídicas, como por ejemplo el derecho de propiedad (art. 33 CE), el de la inviolabilidad de domicilio (art. 18.2 CE), el de la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) o el derecho a la igualdad (art. 14 CE). Finalmente, la distinción entre ciudadanos españoles y extranjeros afecta también a la titularidad de los derechos fundamentales: el art. 13.1 CE afirma que los extranjeros disfrutarán en España de las libertades públicas que garantice el título I, en los términos que establezcan los tratados y la ley. El art. 13.2 CE solo admite que puedan ser titulares del derecho de sufragio activo y pasivo, cuando así se establezca por ley o tratado internacional, y atendiendo a criterios de reciprocidad¹¹. No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia del TC, el art. 13.1 CE no se puede interpretar en el sentido de que los extranjeros solo son titulares de los derechos fundamentales que les reconozcan la ley o los tratados internacionales; son titulares de todos los derechos del título I, con la excepción que prevé el art. 13.2 CE (los derechos políticos del art. 23 CE), y lo único que puede hacer la ley es una regulación diferente o más restrictiva del ejercicio de algunos de los derechos fundamentales de los extranjeros.

(11) En relación con los derechos de los extranjeros, el art. 13.1 CE establece la regla general, y el art. 13.2, la excepción.

Así, la jurisprudencia del TC ha aclarado que **hay derechos que se fundamentan directamente en la dignidad humana y tienen que corresponder a todo el mundo**, como por ejemplo el derecho a la vida y a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, la libertad personal, los derechos de la vida privada, la libertad de expresión y de comunicación o la tutela judicial efectiva. Sin embargo, **hay otro tipo de derechos cuyo ejercicio nada impide que esté restringido, o sea diferente del caso de los nacionales españoles**, como por ejemplo el derecho de voto, la libre circulación, o el derecho de reunión y manifestación. La legislación de extranjería introducirá en cada derecho limitaciones, si es el caso.

Hasta ahora, la mayor restricción pasa por el ejercicio de los derechos políticos, como el de voto, entendiendo que no disfrutan del vínculo jurídico que los hace miembros de la comunidad política estatal. Por eso, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación afecta al trato dado a los extranjeros, puesto que también son titulares de estos derechos, pero con las condiciones particulares y limitaciones que se pueden establecer por ley o tratado internacional. Por otro lado, a partir de 1992, con el Tratado de Maastricht, se crea la llamada ciudadanía europea, que permite a las personas que la posean disfrutar del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales y al Parlamento Europeo. Por otro lado, el art. 11.3 afirma el derecho a la doble nacionalidad en virtud de tratados que recojan una vinculación especial con el Estado español. La legislación española en materia de derechos y libertades de los extranjeros ha sido problemática, así como su desarrollo reglamentario. La legislación en esta materia se encuentra en la LO 4/2000 de 11 de enero, modificada este mismo año por la LO 8/2000 de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y todavía modificada posteriormente varias veces.

La CE dedica su título I a la ordenación de los derechos y libertades, pero aunque la denominación de este título sea la de «derechos y deberes fundamentales», el contenido de esta parte (arts. 10 a 55 CE) es más complejo que el simple enunciado de derechos y deberes. Así, el título I está encabezado por el art. 10 que, como hemos visto, remarca en su apartado primero el carácter básico de la dignidad de la persona y de sus derechos para el orden político (art. 10.1 CE) y, en su apartado segundo, establece que los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán en conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España (art. 10.2 CE). El capítulo I («de los españoles y los extranjeros») regula las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales (nacionalidad, extranjería y mayoría de edad), a pesar de que también se reconoce algún derecho subjetivo, como el derecho de asilo (art. 13.4 CE). **En el capítulo II («derechos y libertades») está la auténtica declaración de derechos, que se divide en dos secciones precedidas del reconocimiento del principio de igualdad y el derecho de no discriminación** (art. 14 CE). En cambio, en el capítulo III («principios rectores de la política social y económica»), como su propia denominación indica, no se reconocen derechos subjetivos, sino solo «principios rectores», que tienen que orientar la acción de los poderes públicos. En el capítulo IV tampoco se establecen propiamente derechos, sino las garantías de los derechos fundamentales, que tienen que asegurar la plena efectividad de los derechos. Y finalmente, **el capítulo V establece las bases de la regulación de la suspensión de los derechos fundamentales (para hacer frente a situaciones de extrema gravedad, y con el fin de volver a la normalidad, la Constitu-**

ción prevé que **el ejercicio de algunos derechos fundamentales se puede suspender temporalmente y con unas condiciones previstas previamente** en la misma Constitución, porque la posible suspensión de algunos derechos no significa su desaparición, sino la sustitución del régimen ordinario por uno extraordinario que también tiene sus límites y controles).

Por lo tanto, **resulta claro que no todo el título I de la Constitución reconoce derechos fundamentales**. Asimismo, la Constitución establece derechos fuera del título I, como sucede en los artículos 119 (derecho a la gratuidad de la justicia, dentro del título VI) y el 125 (derecho a participar en la Administración de justicia por medio del jurado, también dentro del título VI). Son derechos constitucionales o constitucionalizados, pero no son derechos propiamente fundamentales. **Los derechos fundamentales son una parte de los derechos constitucionales, aquellos a los cuales la constitución otorga las máximas garantías**: en un sentido estricto, los derechos contenidos en la sección primera del capítulo segundo del título I (arts. 15 a 29).

En un sentido amplio o laxo, se puede afirmar que todos los derechos del título I de la Constitución son derechos fundamentales, puesto que así lo indicaría la rúbrica global del título I («de los derechos y deberes fundamentales»). Ahora bien, en un sentido más estricto, tanto la doctrina como el mismo Tribunal Constitucional acostumbran a reservar esta denominación de derechos fundamentales a los derechos contenidos en la sección primera del capítulo segundo del título I (arts. 15 a 29). Aun así, más que etiquetar con uno u otro nombre los diferentes derechos, lo más importante son las garantías que tienen cada uno de ellos.

La clasificación de los derechos en la Constitución se fundamenta en las garantías⁽¹²⁾. Las garantías que encontramos en el ordenamiento jurídico español **se pueden agrupar en dos grandes bloques: las jurisdiccionales y las no jurisdiccionales⁽¹³⁾**. Dentro de las jurisdiccionales, se incluyen la tutela ordinaria y los procedimientos de carácter preferente y sumario, el recurso de amparo ante el TC y la protección internacional de los derechos (el recurso ante el TEDH).

⁽¹²⁾Ved los arts. 53 y 54 CE.

⁽¹³⁾Cada uno de los derechos fundamentales y sus garantías se explican en la asignatura *Derecho constitucional*.

Ante una vulneración de los derechos, los jueces son la primera y principal garantía. En el caso de los derechos fundamentales, por su especial importancia, el Estado se compromete a garantizar una mayor protección. Por este motivo, además de ser defendibles ante la jurisdicción ordinaria ejercitando el derecho a la tutela judicial efectiva como cualquier derecho o interés legítimo, la Constitución proporciona todavía dos mecanismos extraordinarios de protección: el procedimiento preferente y sumario a la jurisdicción ordinaria y el recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Ya fuera del ámbito estatal, la protección de los derechos todavía se puede buscar mediante el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Dentro de las garantías no jurisdiccionales, podemos distinguir dos subgrupos: las garantías normativas (las que se derivan de la regulación jurídica de los derechos fundamentales, que son la vinculación inmediata, la rigidez constitucional, la reserva de ley y el respeto al contenido esencial) **y las garantías institucionales** (instituciones que el Estado pone a disposición de las personas para proteger sus derechos y libertades, como por ejemplo la policía,

el ministerio fiscal o el defensor del pueblo, e incluso algunas otras para proteger derechos específicos, como la Agencia Española de Protección de Datos o la Administración electoral).

La Constitución ordena los derechos de acuerdo con las garantías que les otorga para protegerlos. La lógica de la estructura interior del título I de la Constitución española se tiene que buscar sobre todo en el art. 53 CE, que es el que establece varios procedimientos de garantía de los derechos y libertades. El art. 53.1 CE establece que los derechos del capítulo II del título I (artículos 14-38 CE) «vinculan todos los poderes públicos» y de manera complementaria nos dice que estos derechos **tienen un «contenido esencial»** declarado constitucionalmente **que el legislador tendrá que respetar**. Es el constituyente quien formuló el contenido del derecho, su núcleo básico. **Son derechos de aplicación directa** desde el texto constitucional, sin necesitar la interposición de la ley. No dependen del desarrollo legislativo, dado que existen por la misma declaración constitucional. Asimismo, de acuerdo con el art. 53.2 CE, el derecho a la igualdad del art. 14 CE, los derechos de la sección primera del capítulo II del título I (art. 15 a 29 CE) y el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar del art. 30.2 CE son los que tienen la garantía del recurso de amparo; es decir, a excepción de este último, son **el núcleo duro de la declaración constitucional de derechos (los que hay del art. 15 al 29 CE)** y, por lo tanto, los que **reúnen las máximas garantías**: tienen también la garantía del recurso preferente y sumario a la vía judicial ordinaria, el recurso de amparo al Tribunal Constitucional y el desarrollo mediante ley orgánica para regular su ejercicio (según el art. 81.1. CE), y solo pueden ser objeto de reforma constitucional según el procedimiento agravado del art. 168 CE, de modo que forman parte del contenido más rígido del texto constitucional. **En cambio, en contraposición a todas estas garantías, el art. 53.3 CE establece que los principios del capítulo III del título I solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen; no son, por lo tanto, derechos subjetivos, sino normas finalistas** dirigidas a los poderes públicos para orientar su actuación hacia los objetivos del Estado social.

En conjunto, el sistema de derechos y garantías recogido en la Constitución española de 1978, a pesar de que carece de rigor, tanto en lo que respecta a la terminología (confusa) como por la clasificación (poco sistemática), **se puede considerar bastante ambicioso por la amplitud del catálogo de derechos y por las garantías que se recogen en el mismo**; en parte, por la necesidad de blindarse de su pasado (como reacción al hecho de que se salía de una dura represión de los derechos durante una larga dictadura), pero también porque se supo incorporar buena parte de la doctrina y tradición constitucional europea más moderna y avanzada de la época, la Constitución española diseña un notable sistema de protección de los derechos. Ahora bien, hoy lo más importante es que los derechos de las personas estén no tan solo declarados en los textos constitucionales, sino sobre todo garantizados, y no solo sobre el papel, sino de manera real y efectiva. Esto es lo que el Estado español

y cualquier otro Estado del mundo que quiera ser un Estado de derecho tienen que demostrar en la práctica, cada día. Y la tarea de hacer efectivo el Estado de derecho no corresponde solo a las instituciones públicas, sino también a las personas y entidades, porque de una manera parecida a lo que pasa con la musculatura, si los derechos se ejercen se refuerzan y, si no, se pueden llegar a atrofiar. La garantía de los derechos no es un objetivo que se gana una vez y ya se disfruta para siempre: puede evolucionar e ir a mejor o involucionar y que el Estado de derecho sufra una regresión.

Para acabar este apartado, solo una referencia a los deberes constitucionales.

Además de derechos y libertad, la CE regula también deberes¹⁴. El art. 9.1 CE afirma que los ciudadanos y los poderes públicos quedan sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, **los deberes que establece la Constitución tienen exigibilidad jurídica. Ahora bien, estos deberes jurídicos, genéricos, solo son exigibles de acuerdo con la configuración legal, que los llena de contenido y los plasma en obligaciones concretas.** Por lo tanto, los deberes constitucionales **necesitan la complementariedad de la ley para hacerlos totalmente exigibles.** En la CE hay varios deberes como, **por ejemplo, el deber de defender España** (art. 30.1 CE), que se predica de los españoles, de acuerdo con la ley que fije las obligaciones militares; **o el deber de pagar tributos** (art. 31.1 CE), siempre de acuerdo con las leyes, que establecerán la forma y cuáles serán los tributos en cada momento. La CE establece unos criterios: todo el mundo tiene que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (principio de generalidad), de acuerdo con su capacidad económica, y según un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscador.

(14) En todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, hay derechos y deberes. También en la Constitución.

Otros deberes que encontramos en el texto constitucional son: el deber de trabajar (art. 35.1 CE); el deber de colaborar con la Administración de justicia (art. 118 CE); el deber de conocer el castellano (art. 3 CE); el deber de ir a las comisiones parlamentarias de investigación (art. 76.2 CE); el deber de respetar el medio ambiente (art. 45 CE); deberes de los ciudadanos en casos graves de riesgo, catástrofes o calamidades públicas (art. 30.4 CE); deberes derivados del derecho a la salud pública (art. 43.2 CE); el deber de recibir enseñanza básica (art. 27.4 CE); o el deber de los padres de prestar asistencia de todo tipo a los hijos tenidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los otros casos en los que legalmente proceda (art. 39.3 CE).

2.1.3. El Estado democrático en la Constitución española

Hemos visto que el Estado democrático incorpora los presupuestos del Estado de derecho y añade tres elementos nuevos que lo definen:

- la soberanía popular (que implica el sufragio universal);
- el reconocimiento y la garantía del pluralismo de la sociedad, y muy especialmente del pluralismo político, y

- la participación política, ejercida directamente mediante mecanismos como el referéndum o la iniciativa legislativa popular, o bien por medio de la elección libre y periódica de representantes.

La soberanía popular

En el preámbulo de la Constitución, se explicita la voluntad de «garantizar la convivencia democrática» y «establecer una sociedad democrática avanzada», y después de fijar en el art. 1.1 la cláusula que define la forma de Estado (Estado social y democrático de derecho), **la Constitución establece en el art. 1.2 que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado»**. El precepto, inspirado en el art. 3 de la Constitución francesa de 1958, utiliza una fórmula en la que aparece el término «soberanía nacional», lo cual podría confundir porque hemos visto que este término históricamente iba asociado a una concepción no democrática, pero **dado que incluye a continuación la idea clave de que la soberanía reside en el pueblo, hay que interpretar que la voluntad del constituyente era establecer la soberanía popular**, es decir, que el fundamento de toda autoridad reside en la voluntad de la comunidad. Una parte de la doctrina critica esta formulación por falta de rigor técnico, pero otros autores consideran que hay que interpretar que la Constitución quiso eliminar cualquier contraposición entre nación y pueblo y remarcar que no hay otra voluntad de la nación que la formada por el pueblo.

En un sistema político como el español, dotado de una constitución normativa y basada en el principio democrático, **la soberanía se concreta en un primer momento en la capacidad de ejercer el poder constituyente originario**, como hemos visto que se hizo cuando el pueblo español ratificó el 6 de diciembre de 1978 la constitución que habían elaborado y aprobado unas cortes constituyentes *de facto*. A partir de aquí, **el pueblo se reserva su intervención en el poder de reforma y la Constitución configura los poderes estatales** (los poderes constituidos), **de modo que su composición provenga directa o indirectamente de la voluntad popular**: directamente, las Cortes Generales, los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos; indirectamente, y por vía parlamentaria, el presidente del Gobierno del Estado y los presidentes de las comunidades autónomas; más indirectamente todavía, y por vía de la misma Constitución, el rey y los jueces encuentran su referencia última en el pueblo, por el hecho de que este aprobó la Constitución que los configura como órganos estatales.

La soberanía popular implica que todos los individuos de aquel pueblo tienen una parte de la soberanía y todos tienen derecho (como soberanos que son) **a participar en el Gobierno de la comunidad. Por este motivo, la Constitución establece el sufragio universal en los tres ámbitos territoriales en los que se organiza el estado**: los miembros de las Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66.1), son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (art. 68 CE), y el Gobierno del Estado

solo puede constituirse si su presidente consigue la confianza del Congreso en la votación de investidura (art. 99 CE); la organización de las comunidades autónomas «se basará en una asamblea legislativa elegida por sufragio universal», que elegirá al presidente de la comunidad autónoma (art. 152 CE); y el Gobierno y la Administración municipal corresponden a los ayuntamientos, integrados por los alcaldes y regidores, «elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto» (art. 140 CE).

Por lo tanto, atribuir la soberanía al pueblo no implica solo que este es la fuente teórica del poder y el parámetro de su legitimidad, sino también que es el pueblo el que efectivamente ejerce esta soberanía, lo cual requiere que se favorezca la máxima participación ciudadana en los asuntos públicos, en un contexto de garantía de la expresión del pluralismo social y político.

El reconocimiento y la garantía de la expresión del pluralismo de la sociedad, y muy especialmente del pluralismo político

La Constitución de 1978 propugna como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado «el pluralismo político» (art. 1.1 CE), pero **el pluralismo que reconoce y garantiza la Constitución no se limita al ámbito político, sino que también es social**, en dos vertientes: la profesional o de clase, y la derivada de las diversidades nacionales, lingüísticas, religiosas o ideológicas.

La Constitución garantiza la pluralidad de hecho (etnia, sexo, nacionalidad, etc.) y de opciones (políticas, sociales, religiosas, ideológicas, culturales, lingüísticas, de orientación sexual, etc.) **por medio de los derechos fundamentales y sus garantías**, porque el pluralismo es consecuencia de la libertad y, por lo tanto, consustancial a la democracia. De entrada, **el art. 14 CE prohíbe cualquier tipo de discriminación** («por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»). **La Constitución también reconoce el derecho de asociación** (art. 22 CE), es decir, el derecho a formar «agrupaciones estables de personas de carácter no lucrativo para la gestión de un interés común sobre una base consensual» (STC 244/1991): solo prohíbe las asociaciones secretas, las de carácter paramilitar y las que busquen finalidades o usen medios tipificados como delito, y garantiza que las actividades de las asociaciones solo pueden ser suspendidas o disueltas en virtud de una resolución judicial motivada. **Entre las diferentes clases de asociaciones, dos tienen una especial importancia** por el papel tan relevante que desarrollan en la esfera pública y en el proceso político democrático, **y se les ha dado un reconocimiento singular en la Constitución: los partidos políticos** (art. 6 CE) **y los sindicatos** (art. 7 y 28 CE). También están expresamente reconocidas en la Constitución las asociaciones empresariales (art. 7 CE) y los colegios y organizaciones profesionales (arts. 36 y 52 CE), y para todos estos tipos de asociaciones **la Constitución exige que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos**.

Además de constitucionalizar los principales instrumentos de expresión del pluralismo profesional y de clase social, **el constituyente español también quiso referirse a otras formas de pluralismo social para reconocer su legitimidad** frente a aquellos sectores que en el pasado la habían negado y habían preconizado su erradicación, en su afán de imponer un Estado español uniforme basado en una única nación, lengua y religión. Así, **la Constitución española reconoce**:

- **El pluralismo nacional:** en el preámbulo, la Constitución proclama la voluntad de proteger no solo a todos los españoles, sino también a «los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones». Además, en el art. 2 CE, se puede entender que hay un reconocimiento del pluralismo nacional del Estado español porque la Constitución incluye el término «nacionalidades» por primera vez en la historia constitucional española y no solo les garantiza el derecho a la autonomía, sino que también las «reconoce», lo que implícitamente pone de manifiesto que no las «establece» la Constitución, sino que ya existían antes que ella. Aun así, como veremos cuando expliquemos más adelante el Estado de las autonomías, la formulación del art. 2 es, al menos, equívoca, y pese a que algunos autores se han esforzado por encontrarle una coherencia, en la misma confluyen dos lógicas que se pueden considerar hasta cierto punto contradictorias: la que introduce el concepto de «Nación española, patria común e indivisible» y remarca repetitivamente que «la Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble» de esta nación, y la que incorpora el reconocimiento de que esta nación la integran no solo regiones, sino «nacionalidades», término que, a pesar de que se puede interpretar de varias maneras, puede ser entendido como una referencia a naciones sin Estado propio.
- **El pluralismo lingüístico:** además del castellano, como lengua española oficial del Estado (art. 3.1 CE), la Constitución reconoce la existencia de otras lenguas españolas que también pueden ser oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos (art. 3.2 CE), y añade que «la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio que será objeto de especial respeto y protección» (art. 3.3 CE). Asimismo, en el art. 20.3 la Constitución reconoce explícitamente el pluralismo social y exige que la ley garantice el acceso a los medios de comunicación del Estado (o que dependan de cualquier entidad pública) «de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diferentes lenguas de España».
- **El pluralismo religioso e ideológico:** la libertad ideológica y religiosa es proclamada como un reconocimiento de la expresión libre de la persona y garantizada como un derecho fundamental en el art. 16.1 CE («Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las co-

munidades sin ninguna más limitación, cuando sean manifestados, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley»).

En cuanto al pluralismo político, ya hemos visto que hoy en día se expresa principalmente mediante los partidos políticos, aunque no tienen el monopolio (ni es bueno que lo tengan). Y hemos visto también que a partir de 1945, las constituciones democráticas los fueron admitiendo, regulando algunas de las principales funciones en el sistema político y exigiéndoles determinadas características. La Constitución española de 1978 se incorporó a este proceso y en el art. 6, situado en el título preliminar, exige a los partidos políticos que su estructura y funcionamiento sean democráticos y reconoce la función constitucional de los partidos políticos, por primera vez en la historia constitucional española, a los cuales atribuye tres funciones:

- «expresan el pluralismo político» (el pluralismo de partidos excluye, por lo tanto, el sistema de partido único –incompatible con un sistema democrático–, pero esta función no la monopolizan los partidos, porque hay otros agentes políticos que también expresan este pluralismo);
- «concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular» (son, o tendrían que ser, canales de relación de doble dirección: ayudan a formar la voluntad popular enviando mensajes a la ciudadanía, pero también recogen y se hacen eco de lo que manifiesta la ciudadanía, y por eso la ley les otorga un lugar central en el proceso electoral);
- «son un instrumento fundamental para la participación política» (a diferencia de los *lobbys*, los grupos de presión, que «solo» quieren influir en el poder, los partidos políticos tienen como finalidad el ejercicio del poder: es decir, quieren que sus representantes, con un programa político, accedan a los órganos del Estado; ahora bien, son un instrumento *fundamental* para la participación política pero *no el único*, porque la Constitución tampoco les atribuye exclusivamente esta función, sino que también se permite concurrir a las elecciones por medio de agrupaciones de electores).

En cuanto a su naturaleza jurídica, los partidos políticos no son órganos del Estado (STC 10/1983), sino una forma particular de asociación (art. 22 CE); son asociaciones privadas, de carácter voluntario y, como expresamente declara la Constitución, pueden ser creados y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a la Constitución y la ley (art. 6 CE). Por lo tanto, su creación es libre, pero se tienen que inscribir en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior que, cuando de la documentación presentada deduzca que hay indicios racionales de ilicitud penal del partido, lo tiene que poner en conocimiento del ministerio fiscal, el cual podrá promover una declaración del juez penal de ilegalidad del partido y la consiguiente improcedencia de su inscripción. Además de la libertad de crear partidos políticos,

Lectura recomendada

STC 138/2012, de 20 de junio, que declara la vulneración del derecho de asociación en su vertiente de creación de partidos políticos (caso Sortu) por ausencia de elementos probatorios sólidos que acrediten que el partido que se quiere constituir viene a continuar o suceder la actividad de formaciones políticas ilegalizadas.

también hay libertad de afiliarse a los mismos (de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos), y nadie puede ser obligado a pertenecer ni a participar en un partido político.

Actualmente, **la regulación de los partidos la encontramos básicamente en la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, y en la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, las dos modificadas, entre otras, por la Ley orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos.**

Inicialmente, los partidos políticos fueron regulados por la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, aprobada poco antes que la Constitución, aunque cuando el texto constitucional ya estaba establecido; fue concebida, por su brevedad (tanto en artículos como en contenidos), como una ley que tenía que servir primordialmente para establecer un procedimiento sencillo de constitución en libertad de los partidos políticos (objetivo no menor en el momento fundacional en el que se dictó). Debía tener un periodo de vigencia no muy dilatado, pero estuvo vigente veinticuatro años, hasta que se aprobó la actual LO 6/2002.

La Ley 6/2002 desarrolla la exigencia constitucional de que los partidos deben tener una estructura y un funcionamiento democráticos (arts. 7 y 8): han de tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que pueden actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la cual corresponde, en todo caso, como órgano superior de gobierno del partido, adoptar los acuerdos más importantes, incluida la disolución; establece el sufragio libre y secreto como medio ordinario para cubrir los lugares directivos, que pueden ser censurados, y se reconocen algunos derechos que se consideran básicos dentro de cualquier ámbito asociativo, como el de participar en la elección y ser elegibles en los diferentes órganos del partido, o los derechos de información de las actividades, de la situación económica y de las personas que configuran los órganos directivos; la ley también determina algunas reglas básicas de funcionamiento de las reuniones de sus órganos colegiados internos.

Las dos novedades más importantes de la Ley 6/2002 son en relación con el deber de respeto de los partidos políticos a los principios democráticos y a los valores constitucionales, y la regulación de la competencia y el procedimiento para la disolución judicial de un partido porque no respete los principios democráticos y los derechos humanos. En este sentido, el art. 9 de la Ley recoge una lista muy larga de elementos indiciarios que tendrían que permitir conocer cuándo un partido no se ajusta a los principios democráticos y a los valores constitucionales y, por consiguiente, tiene que ser declarado ilegal¹⁵.

⁽¹⁵⁾El STC 48/2003 descartó la inconstitucionalidad de la tipificación de las causas de ilegalización y disolución previstas por la ley de partidos (LO 6/2002).

Según establece la Ley 6/2002, **un partido político tiene que ser declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, en particular cuando persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las conductas que detalla (apartados 2 y 3 del art. 9), llevadas a cabo de manera reiterada y grave.** Porque, según explicita la exposición de motivos de la Ley, se

quiere evitar la ilegalización por conductas aisladas (excepto las de naturaleza penal) y **por eso se exige una reiteración o acumulación de acciones que pongan de manifiesto de manera inequívoca toda una trayectoria de ruptura de la democracia** y de ofensa a los valores constitucionales, al método democrático y a los derechos de los ciudadanos.

En esta misma exposición de motivos, se afirma que la voluntad de la ley es fijar «nítidamente la frontera entre las organizaciones que defienden sus ideas y programas, sean cuales sean, con un respeto escrupuloso de los métodos y los principios democráticos, de las otras que sostienen su acción política en la connivencia con el terror o la violencia, o con la violación de los derechos de los ciudadanos o del método y los principios democráticos». Por lo tanto, «no se trata de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por más que estas se alejen del marco constitucional o, incluso, lo pongan en cuestión», porque la Ley, de acuerdo con la Constitución, «parte de considerar que cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución, siempre que no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos».

En conclusión, **la actividad de los partidos políticos tiene que respetar la Constitución y la ley, pero esto no significa que tengan que estar de acuerdo con ella, puesto que pueden estar en contra y propugnar su modificación** (recordemos que no solo las leyes son modificables, sino que la Constitución se puede reformar de arriba abajo, porque, como se ha explicado, no contiene ninguna cláusula de intangibilidad, es decir, puede ser reformada íntegramente).

La disolución de un partido político solo puede ser decisión de sus miembros (acordada por las causas y por los procedimientos previstos en sus estatutos) **o bien de la autoridad judicial competente porque se dé uno de los tres casos siguientes:**

- **cuando incurra en casos tipificados como asociación ilícita en el Código penal;**
- **cuando vulnere de manera continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos** (de acuerdo con lo que prevén los artículos 7 y 8 de la Ley orgánica 6/2002), y
- **cuando, de manera reiterada y grave, su actividad vulnere los principios democráticos** o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades, o imposibilitar o eliminar el sistema democrático (mediante las conductas a las que se refiere el artículo 9 de la ley de partidos).

En el primer caso, resuelve el juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo que disponen la Ley orgánica del poder judicial, la Ley de enjuiciamiento criminal y el Código penal; en los otros dos casos, resuelve la Sala Especial del Tribunal Supremo, regulada en el artículo 61 de la Ley orgánica del poder judicial, de acuerdo con un procedimiento específico que tiene carácter preferente. Y en estos dos últimos casos, solo están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político, y su disolución

consiguiente, el Gobierno y el ministerio fiscal; el Congreso de los Diputados o el Senado pueden instar al Gobierno a que solicite la ilegalización de un partido político (y el Gobierno permanece obligado a formalizar la solicitud correspondiente de ilegalización). **La sentencia dictada por la Sala Especial del Tribunal Supremo**, que puede declarar la disolución del partido político o desestimar la demanda, **no puede ser objeto de ningún recurso, salvo, si procede, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional**, y es ejecutiva desde el momento de su notificación.

Solo nueve meses después de haberse aprobado la Ley 6/2002, el Tribunal Supremo ya acabó el proceso para ilegalizar Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna, que consideró de hecho un solo partido, alegando el apoyo a la banda terrorista ETA y el no rechazo de la violencia como forma de hacer política (Sentencia de 27 de marzo del 2003 de la Sala Especial del artículo 61 LOPJ del Tribunal Supremo). A partir de esta sentencia del 2003 del TS, se ilegalizaron más partidos políticos y agrupaciones de electores que se quisieron presentar hasta a tres ciclos electorales: a las elecciones locales y forales del 2003, europeas del 2004, autonómicas del 2005, y otra vez las locales y forales del 2007 y las autonómicas del 2009, y las forales y locales del 2011, por considerar que sucedían de hecho a HB. Entre los casos que llegaron al TC, se pueden destacar las sentencias siguientes: SSTC 85/2003, 5 y 6/2004, 99/2004, 68/2005, 110/2007, 112/2007, 43 y 44/2009, 126/2009, 62/2011 y 138/2012.

También es interesante la Sentencia del TEDH de 13 de junio del 2017 (caso Atutxa contra España), en la cual el Tribunal de Estrasburgo condena a España y reconoce que se vulneró el derecho a un juicio equitativo de los exmiembros de la Mesa del Parlamento Vasco, cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo en el 2008 por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) después de la ilegalización de Batasuna en el 2003; en el 2013, el TC había denegado el amparo a los miembros de Mesa (STC 205/2013, de 5 de diciembre) y había avalado la decisión del TS.

La asignación a los partidos de importantes funciones constitucionales no altera su naturaleza de asociación privada, pero sí que **justifica que disfruten de una financiación pública**. La Constitución no hace ninguna referencia a la financiación de los partidos y, por lo tanto, deja mucho margen para su regulación en la ley, actualmente la LO 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos, que opta por un sistema mixto, en el que, además de ingresos privados, también los prevé públicos y fija límites en algunos ingresos y gastos electorales. En los partidos con más representación institucional, la mayor parte de los ingresos provienen del Estado, a pesar de que con diferente proporción entre unos y otros. **La financiación pública es principalmente directa** o dineraria (se hacen transferencias de dinero a los partidos políticos), **pero también se contemplan algunos tipos de aportaciones en especie** (financiación indirecta), como por ejemplo la cesión de locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral (art. 57 LOREG), la cesión de espacios gratuitos en medios de comunicación de titularidad pública (arts. 60 a 64 LOREG), las tarifas especiales para el envío de propaganda electoral (art. 59 LOREG), un régimen fiscal especial (exención de determinadas rentas del impuesto sobre sociedades) e incluso algunos incentivos a las aportaciones privadas a los partidos (las cuotas de afiliación son deducibles del impuesto de la renta de las personas físicas, y a determinadas donaciones también les son aplicables las deducciones de la Ley del mecenazgo, Ley 49/2002, de 23 de diciembre). **Entre la financiación pública dineraria, destacan tres tipos de subvenciones: una anual no condicionada para**

atender los gastos de funcionamiento; una también anual para los gastos de seguridad, y otra solo cuando haya elecciones: para los gastos que originen las actividades electorales, según el tipo de elección o referéndum (arts. 175, 193 y 227 LOREG); en los tres casos, la cantidad de la subvención es determinada por el número de votos y escaños obtenidos. Los partidos también pueden recibir aportaciones de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, de los parlamentos autonómicos y de los grupos de representantes en los órganos de las administraciones locales (art. 2 LO 8/2007).

En cuanto a la financiación privada, la LO 8/2007 fija límites y condicionantes: los partidos **pueden recibir cuotas y aportaciones de sus afiliados y también pueden recibir donaciones privadas, pero tienen que ser irrevocables, no finalistas** (no pueden ir condicionadas a una actividad o finalidad determinada), **nominativas** (no pueden aceptar donaciones anónimas) y **de personas físicas** (no pueden aceptar donaciones de empresas ni de ningún otro tipo de persona jurídica ni tampoco ente sin personalidad jurídica). Los partidos **tampoco pueden recibir donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales.**

Además, las cantidades dadas a los partidos políticos tendrán que abonarse en cuentas abiertas en entidades de crédito exclusivamente para este fin (los ingresos efectuados en estas cuentas serán, únicamente, los que provengan de estas donaciones); de estas donaciones, tiene que quedar constancia de la fecha de imposición, del importe y del nombre y la identificación fiscal del donante; las entidades de crédito tienen que informar anualmente al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones que hayan sido ingresadas en las mencionadas cuentas. Asimismo, la ley también prohíbe que los partidos acepten que «directa o indirectamente, terceras personas asuman de manera efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios o de cualesquiera otros gastos que genere su actividad». Finalmente, también se puede destacar otra previsión de la Ley respecto a las condiciones de deuda de los partidos: el tipo de interés no puede ser inferior al que corresponda a las condiciones de mercado (y de estos acuerdos, habrá que dar cuenta al Tribunal de Cuentas y al Banco de España, por parte del partido político y de la entidad de crédito, respectivamente), y las entidades de crédito no podrán efectuar condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos (quedan prohibidas las cancelaciones tanto del principal del crédito como de los intereses vencidos).

La Ley 8/2007 todavía prevé otras cautelas, como por ejemplo que los ingresos procedentes de las actividades propias del partido político, los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio, y también los beneficios derivados de sus actividades promocionales y los que puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus finalidades específicas necesitarán la identificación del transmitente cuando la transmisión patrimonial al partido político sea igual o superior a 300 euros (art. 6).

Finalmente, la Ley 8/2007 establece una serie de obligaciones contables y de gestión económica y financiera, entre las cuales se puede destacar la obligación de los partidos políticos de publicar en su página web, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de envío al Tribunal de Cuentas, el balance, la cuenta de resultados y, en particular, la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización, las subvenciones recibidas y las donaciones y legados de importe superior a 25.000 euros con referencia concreta a la identidad del donante o legatario (art. 14).

Por lo tanto, la Ley 8/2007, por un lado, quiere garantizar la suficiencia económica a los partidos políticos, en atención a la importancia de las funciones que tienen atribuidas, pero, por otro lado, también les exige transparencia y publicidad en sus actividades económicas y regula varios mecanismos de control que intentan impedir que se desvíen de sus funciones. Así, además de exigir controles internos de auditoría, se atribuye al Tribunal de Cuentas¹⁶ la competencia para acordar la imposición de sanciones al partido político que cometa alguna de las infracciones económicas que detalla la misma ley (siempre que no constituyan delito, porque entonces correspondería juzgarlo al juez penal). Entre estas infracciones, no solo las hay respecto a actividades de financiación, sino que la Ley 8/2007 remite a la LOREG (Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general) para establecer límites también para el gasto electoral y encomienda a la Junta electoral central (art. 19.1 LOREG) que vele por el cumplimiento de las normas relativas a las cuentas y a los gastos electorales de las candidaturas (durante el periodo comprendido entre la convocatoria y el centésimo día posterior a la celebración de las elecciones).

(16) Además de controlar la financiación de los partidos políticos, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado (art. 136.1 CE), y a pesar de que lleva a cabo una función jurisdiccional (art. 136.2 CE), no forma parte del poder judicial y sus decisiones jurisdiccionales son susceptibles de recurso ante el Tribunal Supremo (art. 49 LOTCU).

El límite de los gastos electorales es el que resulte de multiplicar el número de habitantes correspondientes a la población de la circunscripción por una determinada cifra de euros que varía según el tipo de elecciones: 0,37 euros para las elecciones a las Cortes Generales (175.2 LOREG); 0,11 euros para las elecciones municipales (art. 193 LOREG); 0,16 euros para las elecciones para los consejos insulares de las Canarias; 0,19 euros para las elecciones al Parlamento Europeo (art. 227 LOREG).

Finalmente, como hemos visto, el tercer gran pilar en el que se tiene que basar un Estado democrático es la participación política.

La participación política

La Constitución española opta por un modelo de democracia representativa en el que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos se articula básicamente por medio de la elección de representantes. Como veremos más adelante, el constituyente español regula con un cierto recelo los mecanismos de participación directa (como el referéndum) y semidirecta (como la iniciativa legislativa popular).

La Constitución prohíbe el mandato imperativo para los miembros de las Cortes Generales (art. 67.2 CE), que hoy día continúa siendo una garantía de la libertad de conciencia del parlamentario, sobre todo respecto a su partido o grupo parlamentario; con el sistema electoral hoy vigente en el Estado español, en la mayoría de los casos son los partidos (sus cúpulas) los que seleccionan y presentan a los candidatos, deciden el orden de las listas, elaboran el programa electoral y financian las campañas electorales. Esta posición tan predominante de los partidos políticos los puede inclinar a tener una cierta concepción de mandato imperativo respecto a los representantes elegidos en sus listas. El Tribunal Constitucional español tuvo que intervenir desde un primer momento, recordando la prohibición del mandato imperativo contenida en el artículo 67, y la relacionó con el derecho fundamental

del art. 23.2 CE, que no solo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también el derecho de mantenerse sin perturbaciones ilegítimas, de tal manera que **los partidos políticos no pueden revocar el mandato de un parlamentario** (a pesar de que abandone el partido o sea expulsado) porque, jurídicamente, la renuncia depende única y exclusivamente de la libre voluntad del parlamentario (SSTC 5/1983, 10/1983, 20/1983, 28/1983, 29/1983, 32/85 y 167/1991, entre otras). Por lo tanto, **la prohibición del mandato imperativo se ha convertido en una garantía que trata de dar una cierta autonomía al representante para poder defender sus ideas, así como para poder interpretar el interés general libremente y no como le indica el partido**. La disciplina de voto que puedan asumir los parlamentarios solo es admisible en la medida en que voluntariamente sea aceptada por ellos. Ahora bien, también es cierto que, en la práctica, la mayoría de los electores votan una lista de partido y un programa electoral, y que esperan un compromiso de los miembros que van en aquella lista respecto a las propuestas de aquel programa. No obstante, la opción del constituyente de prohibir el mandato imperativo, con toda su parte positiva, da cobertura a todos los representantes, tanto a quienes actúan en conciencia a pesar de que esto signifique enfrentarse a su partido (porque defienden que es el partido o su dirección quien se ha apartado del ideario fundacional o del programa electoral) como también a quienes por intereses personales inconfesables pactan con otras fuerzas políticas para cambiar o mantener la mayoría gobernante, o bien dificultan o hacen imposible la gobernabilidad. Cuando la ciudadanía considera que estas actitudes no responden a discrepancias políticas legítimas, sino a intereses espurios, aumenta el peligro de alejar a una parte de los votantes de la participación democrática. La solución del problema del «transfuguismo» no se puede buscar en la posibilidad de que los partidos puedan revocar el mandato de un parlamentario, sino por otros tipos de medidas, como por ejemplo el pacto previo entre las fuerzas políticas de no hacer decisivo el voto de los tránsfugas. Sin embargo, también tiene riesgos dejar en manos de los partidos la decisión sobre quién se considera tránsfuga: en algunos casos, puede ser muy controvertido determinar quién ha sido desleal al programa electoral y al compromiso con los electores (si el acusado de transfuguismo o la dirección del partido). En el ámbito local es donde se han dado más casos de este fenómeno político, y para hacerle frente, los partidos políticos con representación en las Cortes Generales firmaron un acuerdo contra el transfuguismo ya en 1998, que posteriormente fue ratificado y ampliado, y que supuso algún cambio legislativo, fruto del consenso al que se llegó en la comisión de seguimiento de este pacto antitransfuguismo. En cualquier caso, estos pactos son un ejemplo de que no todos los elementos que forman parte del sistema electoral están regulados en el derecho electoral.

La Constitución española regula algunos de los elementos del proceso electoral, especialmente en relación con las Cortes Generales, y **remite la concreción del derecho electoral a una ley orgánica** relativa al «régimen electoral general» (art. 81.1 CE), que según la jurisprudencia del TC tiene que incluir «el núcleo central de la normativa en lo referente al proceso electo-

ral» (STC 72/1984) y contener las normas que regulan la elección al Congreso y al Senado, las relativas a la elección de los órganos de la Administración local y la normativa básica en lo que respecta a las elecciones de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Así pues, en la Constitución y en la LOREG (Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general) están regulados los principales elementos del proceso electoral:

- la capacidad electoral activa y pasiva;
- la tutela del proceso electoral (Administración electoral y garantías jurisdiccionales);
- el número y la magnitud de las circunscripciones;
- la fórmula electoral y la barrera legal, y
- la forma de voto.

1) La capacidad electoral activa y pasiva

De acuerdo con la Constitución, **son titulares del derecho de sufragio activo** (derecho de poder votar) **las personas que tengan la ciudadanía española y, bajo condiciones de reciprocidad mediante ley o tratado, también los extranjeros pueden tener este derecho para las elecciones municipales**¹⁷ (art. 13.2 CE). Así, hoy, poseen sufragio activo en el Estado español:

(17) La relación de países con acuerdos en vigor sobre participación en las elecciones municipales incluye los siguientes: Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Corea, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Nueva Zelanda.

- los españoles mayores de dieciocho años;
- los extranjeros en las elecciones municipales, cuando así lo reconozcan los tratados o las leyes;
- los extranjeros que sean ciudadanos de países de la Unión Europea en las elecciones municipales y en las del Parlamento Europeo.

No obstante, para su ejercicio **es necesaria la inscripción en el censo electoral**, que es el registro público y único de todos los que reúnan los requisitos para ser elector (quienes forman parte del cuerpo electoral). Incluye el censo de electores residentes en el Estado español y el censo de los residentes ausentes, efectuado por los consulados, a instancia del interesado. La formación del censo es una tarea de los ayuntamientos y consulados, coordinada por la Oficina del Censo Electoral. A pesar de que el censo electoral es único (STC 154/1988) para todos los procesos electorales, se amplía en las elecciones municipales y europeas con los extranjeros que tienen el derecho de sufragio activo. De acuerdo con la LOREG (art. 2.2), no tienen este derecho:

- los declarados incapaces por sentencia judicial firme en la cual así se declare de manera expresa, y

- los internados en hospitales psiquiátricos con autorización judicial, cuando así se declare expresamente.

En el Estado español el **voto es un derecho, pero no un deber** (votar no es jurídicamente obligatorio). Tanto en el Congreso (art. 68.1 CE) como en el Senado (art. 69.2 CE), **la Constitución determina las características del sufragio: universal, libre, igual, directo y secreto**. El derecho de voto es ejercido personalmente por el elector en la mesa electoral correspondiente, pero se admite el voto por correo con los requisitos previstos por la ley (art. 72-75 LOREG). Como regla general, el sufragio es directo, pero la LOREG prevé dos excepciones: la elección de una parte de los miembros del Senado por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas (art. 69.5 CE), y la elección de las diputaciones provinciales (art. 141.2 CE).

La titularidad del derecho de sufragio pasivo (poder ser elegible) **corresponde, de acuerdo con la LOREG, a aquellos que poseen el derecho de sufragio activo**, con lo cual se asegura la plena igualdad de los ciudadanos exigida por el art. 23.2 de la Constitución. **También en la Constitución se fijan unas causas de inelegibilidad y de incompatibilidad** (arts. 67.1 y 70.1), que son las mismas a pesar de que, como hemos visto, unas y otras se diferencian tanto en la razón de ser como en el momento en que operan; la Constitución remite a la ley, que amplía el listado (arts. 6 y 154-155 LOREG) y las regula también para los otros tipos de elecciones (arts. 177 y 178, 202 y 203, 210 a 211 LOREG).

2) La tutela del proceso electoral: Administración electoral y garantías jurisdiccionales

La LOREG opta por crear **una Administración electoral independiente y especializada**, encargada de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad (art. 8 LOREG). Está **formada por tres tipos de órganos: las juntas electorales** (la central, las provinciales, las de la comunidad autónoma y las de zona), **las mesas electorales y la Oficina del Censo**. En la Administración electoral, participan los electores, los partidos políticos y los jueces, que tienen una posición destacada mediante su presencia en las juntas electorales, con el fin de asegurar la no injerencia de los gobiernos (estatal, autonómicos y locales) ni de la Administración pública situada bajo su dirección en el proceso electoral.

Las juntas electorales dirigen el proceso electoral y se encargan de garantizar el libre ejercicio del derecho de sufragio y los derechos que están conectados.

La Junta Electoral Central: de carácter permanente, está formada por 8 magistrados del TS (designados por el CGPJ mediante insaculación) y 5 catedráticos de derecho o de ciencia política y sociología (designados por los partidos políticos con representación en el Congreso). Su presidente y vicepresidente son elegidos entre los magistrados, y el secretario es el secretario general del Congreso. Dicta instrucciones, resuelve consultas de

las juntas provinciales, corrige las infracciones que se produzcan en el proceso electoral, siempre que no sean constitutivas de delito, e impone multas.

Las juntas electorales de comunidad autónoma están previstas en el artículo 8.2 de la Ley orgánica del régimen electoral general. Son órganos permanentes y su composición y competencias se establecen por la respectiva ley electoral autonómica. La composición es similar en todas; están integradas por vocales magistrados del Tribunal Superior de Justicia respectivo (designados por insaculación ante la Sala de Gobierno o el presidente del mencionado tribunal) y vocales catedráticos o profesores titulares de derecho, ciencias políticas y sociología en activo, o juristas de reconocido prestigio (propuestos por partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en la asamblea legislativa autonómica). En las comunidades autónomas uniprovinciales, las competencias atribuidas a las juntas electorales de comunidad autónoma y a las juntas provinciales se asumen por un único órgano.

Las juntas electorales provinciales: se constituyen con la convocatoria de las elecciones, y su mandato acaba 100 días después de las elecciones. Su competencia se extiende a la provincia. Están formadas por 3 magistrados de la Audiencia Provincial (designados por el CGPJ mediante insaculación) y 2 vocales nombrados por la Junta Electoral Central entre catedráticos y profesores titulares de derecho o de ciencia política y sociología, residentes en la provincia, a propuesta de los representantes de las candidaturas. A las juntas electorales provinciales les corresponde la mayor parte de la actividad de la Administración electoral: proclamación de candidatos; recepción de las actas procedentes del escrutinio de las mesas electorales y la realización del escrutinio general; proclamación de los electos y entrega de las credenciales.

Las juntas electorales de zona: como las juntas provinciales, son órganos que solo tienen vida desde la convocatoria hasta 100 días después de las elecciones. Su ámbito de actuación es el partido judicial, y su actividad es relevante en las elecciones municipales. Están formadas por 3 jueces de primera instancia o instrucción (designados mediante insaculación por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo) y 2 vocales designados por la Junta Electoral Provincial, entre licenciados en derecho o ciencias políticas y sociología, residentes en el partido judicial.

Las circunscripciones están divididas en secciones electorales, que son unidades de votación y de escrutinio que fijan las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Cada sección incluye un máximo de dos mil electores y un mínimo de quinientos. Cada término municipal tiene como mínimo una sección. Ninguna sección comprende áreas pertenecientes a distintos términos municipales. Los electores de una misma sección están ordenados en las listas electorales por orden alfabético. **Al frente de cada sección, hay una mesa electoral**, integrada por un presidente y dos vocales, que tienen que ser electores de la sección y que son designados mediante sorteo. Reciben un manual de instrucciones sobre sus funciones y unas dietas. Los cargos de presidente y de vocales son obligatorios, pero pueden alegar ante la junta electoral de zona causa justificada y documentada que les impida ejercer el cargo. Cuando el número de electores es muy elevado o están muy diseminados, es posible subdividir el censo alfabéticamente y establecer varias mesas electorales. Si se hacen varias elecciones a la vez, la mesa es común para todas. La mesa se constituye una hora antes de empezar la votación, y finaliza la actividad después de entregar las actas de la sesión.

La Oficina del Censo Electoral es un órgano administrativo permanente que depende funcionalmente de la Junta Electoral Central y **tiene por finalidad confeccionar el censo electoral, que se actualiza mensualmente** a partir de

las modificaciones del padrón municipal de cada ayuntamiento, de los consulados (para los electores que viven en el extranjero) y del registro de penados y rebeldes (para los privados judicialmente del derecho de sufragio).

La Administración electoral es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas que regulan el procedimiento electoral, que está contenido fundamentalmente en la LOREG y que consta de seis fases: la convocatoria de elecciones, el nombramiento de los representantes y administradores de los partidos y de las candidaturas, la presentación y proclamación de candidatos, la campaña electoral, la votación y finalmente el escrutinio y proclamación de electos. Todo el procedimiento electoral está minuciosamente organizado para evitar al máximo posible que se hagan actos administrativos no reglados; además, como hemos visto, la mayoría de los miembros de las juntas electorales son jueces o magistrados, pero en este caso actúan como miembros de un órgano administrativo y no jurisdiccional; por eso, **sus decisiones están sujetas a control judicial** y pueden ser objeto de los recursos especiales siguientes:

- **Recurso contencioso-electoral sobre rectificación del censo electoral:** en concreto, las decisiones de la Oficina del Censo Electoral (OCE) sobre la inclusión o la exclusión de ciudadanos. El procedimiento varía según se plantee la cuestión durante el periodo electoral o no. Fuera del periodo electoral, los recursos administrativos los resuelve en último término la OCE y se puede plantear un recurso contencioso-administrativo. Durante el periodo electoral, hay que recurrir ante el Juzgado de Primera Instancia (art. 40 LOREG), que resuelve en un plazo muy breve.
- **Recurso contencioso-electoral contra la proclamación de candidatos** (art. 49 LOREG). Se presenta ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo. Son legitimados activos los candidatos excluidos. Se trata de un procedimiento especialmente sumario, con pocos días para interponerlo desde la publicación de candidaturas y para dictar sentencia. **Se dispone, además, de la posibilidad de recurso de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional** contra las sentencias recaídas, que también se resuelve en días, antes del inicio de la campaña electoral.
- **Recurso contencioso-electoral contra la proclamación de candidatos electos** (arts. 109-113 LOREG). Se insta ante la Junta Electoral correspondiente y resuelve, en las elecciones al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados y al Senado, la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, y en las elecciones autonómicas o locales, la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. El contenido de la decisión puede ser inadmitir el recurso, declarar válidas la elección y la proclamación, declarar la nulidad del acuerdo de proclamación de uno o varios electos o, finalmente, declarar la nulidad de la elección celebrada en las mesas afectadas por irregularidades invalidantes y obligar a hacer unas nuevas elecciones solo en las mesas y siempre que la invalidación pueda afectar a la distribución de escaños. **También**

en este caso hay un recurso de amparo electoral ante el TC (art. 114 LOREG), a partir de la vulneración del derecho a la participación política (art. 23 CE) respecto a las sentencias dictadas en contencioso-electoral contra la proclamación de candidatos electos, que tiene que resolver en un plazo también muy breve. La legitimación se atribuye a los candidatos electos proclamados o no proclamados, así como a los representantes de las candidaturas, a los partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones que hayan presentado candidaturas a la circunscripción.

3) El número y la magnitud de las circunscripciones

La circunscripción (la unidad territorial que se toma como base para asignar los escaños) **varía según el tipo de elección**: puede ser municipal, provincial, única para todo el territorio estatal o especial (de acuerdo con lo que establecen algunos estatutos de autonomía o leyes electorales autonómicas). La circunscripción es **provincial para el Congreso de los Diputados y para el Senado** (arts. 68.2 y 69.2 CE), a pesar de que hay circunscripciones electorales específicas, como es el caso de Ceuta y Melilla (arts. 68.2 y 69.4 CE), o bien las islas o agrupaciones de islas (art. 69.3 CE). La circunscripción **para la elección de diputados al Parlamento Europeo es única para todo el territorio estatal**. Cada término municipal es la circunscripción para las elecciones municipales. Y para las elecciones a los parlamentos autonómicos, los respectivos estatutos de autonomía o las leyes electorales autonómicas fijan cuál es la circunscripción electoral, que generalmente es la provincia, a pesar de que hay excepciones, como Asturias, por ejemplo, donde el territorio del principado se divide en tres circunscripciones electorales (centro, occidente y oriente), las Canarias (donde cada una de las siete islas constituye una circunscripción electoral) o las islas Baleares (cada una de las cuatro islas más grandes).

La Constitución determina el número de escaños correspondientes a cada circunscripción en el caso del Senado, y remite a la ley en el caso del Congreso. En el caso del Senado, la determinación es directa por la Constitución (art. 69): **4 senadores por provincia, 3 en cada isla mayor** (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife), **2 en Ceuta y Melilla, y 1 en cada isla o agrupación de islas menores** (Ibiza-Formentera; Menorca; Fuerteventura; Gomera; Hierro; Lanzarote, y La Palma). En el caso del Congreso de los Diputados, el número de escaños es determinado directamente para Ceuta y Melilla (**uno para cada una de estas ciudades**) y exige un mínimo común, que la ley determina: la Constitución prevé que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, y que la ley distribuye el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuye los otros en proporción a la población (art. 68.2 CE). **La LOREG ha optado por fijar el número de diputados del Congreso en 350 y un mínimo inicial de 2 diputados por provincia**. Así, quedan asignados 102 escaños y los 248 diputados restantes se reparten entre las circunscripciones en proporción a su población (art. 172.3 LOREG). La atribución de escaños a las circunscripciones puede variar de una elección a otra, debido al

aumento o la disminución de la población; por esta razón, el decreto de convocatoria tiene que especificar el número de diputados que hay que elegir en cada circunscripción (art. 162.4 LOREG).

Esta regulación provoca una falta de proporcionalidad y una sobrerrepresentación de las zonas rurales poco pobladas, y una subrepresentación de las urbanas más habitadas, sobre todo en el Senado, porque se eligen 4 senadores en todas las provincias peninsulares, independientemente de la población que tenga cada una. No obstante, el sistema tampoco resulta muy proporcional en las elecciones del Congreso, puesto que la mayoría de las circunscripciones eligen un número reducido de diputados, y esto provoca que habitualmente solo obtengan representación los dos primeros partidos, y los votos obtenidos por los partidos que quedan terceros o cuartos «se pierden». Esto no pasaría si la circunscripción fuera estatal (una sola circunscripción para todo el Estado, como en el caso del Parlamento Europeo). Sin embargo, hay un gran número de circunscripciones pequeñas (más de 30) que eligen a menos de 7 diputados, que es el mínimo que haría falta para un funcionamiento realmente proporcional. Por eso, la causa más importante de la desigualdad del voto en el Estado español procede del sistema de distribución de escaños por circunscripciones, que distorsiona una plena igualdad del sufragio. Cada elector tiene un voto, pero «el peso» de cada voto no es el mismo: por ejemplo, para conseguir un diputado en Soria hacen falta unos 13.000 votos, mientras que en Madrid se necesitan unos 100.000.

4) La fórmula electoral y la barrera legal (umbral de representación)

A diferencia de lo que sucede en otros países, en el Estado español no se exige llegar a un *quorum* determinado de votos o de participación para que los candidatos sean elegidos. En otros países, como Francia, si no se llega a este *quorum* en una primera vuelta, se celebra una segunda vuelta que es definitiva. En el Estado español se hace una única votación y con los resultados logrados, sea cual sea la participación, se procede a la asignación de los representantes.

Como hemos visto, **hay dos grandes familias de fórmulas electorales: las mayoritarias y las distributivas (a menudo llamadas proporcionales). Las dos son aplicadas en el Estado español:**

- **En el Senado, la fórmula electoral se basa en el sistema mayoritario** (son proclamados senadores los candidatos que obtienen el mayor número de votos, hasta completar el número de escaños que hay que elegir). Aunque el Congreso se rige por un sistema distributivo, en Ceuta y Melilla solo se elige un diputado en cada ciudad y, por lo tanto, el sistema real resulta mayoritario. También los pequeños municipios que funcionan en Consejo Abierto eligen al alcalde por sistema mayoritario (art. 179.2 LOREG).
- **En cambio, se aplica un sistema distributivo en el Congreso, en el Parlamento Europeo, en las elecciones municipales y en las autonómicas.** Entre las distintas fórmulas distributivas que hay, la LOREG optó por el **método d'Hondt** (que es conocido con el nombre de su creador) para las elecciones al Congreso de los Diputados, para las municipales y para las elecciones al Parlamento Europeo. También es la fórmula elegida por las 16 comunidades autónomas que tienen ley electoral propia (todas salvo Cataluña, que se rige por la LOREG). **No es el más proporcional de los sistemas distributivos y tiende a perjudicar a los partidos pequeños.** En el art. 163 de la LOREG, hay un ejemplo práctico de cómo se hace la atribución de escaños siguiendo la fórmula d'Hondt (hecho insólito en la legislación española, en la que no es nada habitual que se incluyan ejemplos, pero que ha sido imitado por otras leyes electorales autonómicas).



Victor d'Hondt (1841-1901) fue un jurista belga, profesor de derecho civil y fiscal en la Universidad de Gante. Ideó un método, descrito en 1878 y adoptado actualmente en muchos países, que permite distribuir el número de cargos electos en proporción a los votos conseguidos por las candidaturas, asignándolos a las listas que tengan la media más alta.

La LOREG también ha optado por establecer una barrera electoral (un porcentaje de votos mínimo para poder obtener representación) en las elecciones al Congreso (3 %) y en las municipales (5 %), pero no en las del Parlamento Europeo. En las elecciones autonómicas, todas las comunidades autónomas han fijado una barrera legal, pero no todas han establecido el mismo umbral de representación: nueve comunidades autónomas han optado por el 3 %, siete por el 5 % y una, Canarias, ha establecido un umbral mucho más alto (solo se tendrán en cuenta las listas que logren un mínimo del 30 % de los votos válidos emitidos en la circunscripción insular o, sumando los de todas las circunscripciones donde hubiera presentado candidatura, al menos el 6 % de los votos válidos emitidos en la totalidad de la comunidad autónoma). A diferencia de otros países, como por ejemplo Alemania, la barrera se sitúa en el ámbito de la circunscripción provincial y esto hace que en la práctica, los efectos de la barrera electoral son casi irrelevantes en las elecciones al Congreso, excepto en las circunscripciones más grandes (como Barcelona o Madrid), porque la mayoría de las circunscripciones son pequeñas (tienen menos de 7 escaños para repartir) y la barrera no puede operar porque con un 3 % de los votos se queda muy lejos de poder tener un escaño. En las elecciones municipales, la barrera electoral sí produce efectos a menudo y deja fuera del reparto todas las listas que no llegan al 5 %. También produce efectos en las elecciones autonómicas, sobre todo en las que han establecido el umbral en el 5 % y especialmente en el caso de la Comunidad Valenciana, la única que ha fijado la barrera del 5 % de los votos emitidos en el conjunto de la Comunidad y no en la circunscripción.

5) La forma de voto

La Constitución prevé en dos casos un *sufragio uninominal* (se tiene que elegir un único representante votando un solo nombre). Se trata de la elección de un diputado en Ceuta y en Melilla (art. 68.2 CE) y de un senador en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma (art. 69.3 CE); la LOREG (art. 179.2) ha añadido un tercer caso: la elección del alcalde en los municipios que funcionan en régimen de Consejo Abierto (los electores eligen directamente al alcalde por un sistema mayoritario). **En todos los otros casos, en el Estado español se usa el *sufragio plurinominal*** (el elector vota a varias personas para elegir a una pluralidad de representantes). **En las elecciones al Congreso, al Parlamento Europeo y a las municipales, el sistema utilizado es el de *listas cerradas y bloqueadas***: el elector elige una candidatura entre las presentadas, pero tiene que aceptarla tal y como está configurada, porque no puede modificar ni los nombres ni el orden de colocación en la lista. **En cambio, en la elección de senadores se usa el sistema de *listas abiertas con panachage***: el elector puede confeccionar su lista con personas presentadas en candidaturas diferentes. Aun así, esta es una posibilidad que los electores acostumbran a utilizar poco y se inclinan mayoritariamente por un criterio de voto compacto, parecido al de la elección de diputados. También se usa este sistema de listas abiertas en las elecciones locales a municipios con menos de 250 habitantes que no funcionen en régimen de Consejo Abierto (art. 184 LOREG). **En estos municipios y en las elecciones al Senado, cada elector solo puede votar un número inferior de candidatos al de los representantes que tienen que ser elegidos, para asegurar una representación a la minoría.** Así, en las circunscripciones que eligen a 4 senadores, los electores pueden votar a un máximo de 3, y en las que eligen a 3, pueden votar a un máximo de 2, y a uno en el resto de los casos (art. 166.1 LOREG).

Además de la participación política mediante la elección de representantes, la Constitución también prevé mecanismos de participación directa (como el referéndum) **y semidirecta** (como la iniciativa legislativa popular), pero los regula de tal manera que resultan bastante más marginales de lo que suele ser habitual en el modelo de democracia representativa:

a) El referéndum: es un procedimiento de participación directa de los ciudadanos a los que se somete una resolución (un texto legal o una declaración) para que manifiesten su acuerdo o desacuerdo. No hay una diferencia comúnmente aceptada entre referéndum y plebiscito, pero mientras que el referéndum puede referirse a cualquier tema, el plebiscito quedaría limitado a la aprobación de leyes, siguiendo su origen romano (I. Molas). A diferencia de lo que sucede en otros países, la Constitución no admite el referéndum para ratificar o vetar las leyes aprobadas por las Cortes, ni tampoco el abrogativo de las leyes vigentes; la mayoría de la doctrina coincide en considerar que lo sitúa como un mecanismo residual o lateral del sistema político, y que una de las razones por las cuales los constituyentes no optaron por facilitar más el referéndum

fue por el uso del mismo que había hecho la dictadura franquista, como vía de confirmación personal del dictador en sustitución de las consultas democráticas.

La Constitución recoge tres tipos de referéndums: el consultivo, para «decisiones políticas de trascendencia especial» (art. 92 CE), cuando el presidente del Gobierno del Estado lo crea conveniente, con la previa autorización del Congreso de los diputados; **el de reforma constitucional**, que en el procedimiento ordinario del art. 167 CE tiene carácter facultativo y en el procedimiento agravado del art. 168 CE es preceptivo (obligatorio que se haga), pero en los dos casos es jurídicamente vinculante; **y el referéndum vinculado al proceso autonómico**: para la manifestación de la iniciativa autonómica (art. 151.1 CE), aprobación del Estatuto de autonomía (art. 151.2 CE) y su reforma (art. 152.2 CE). **La Constitución remite a una ley** para que regule «las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum», **la LO 2/1980** de 18 de enero, que establece unas disposiciones comunes (campaña, votación, recursos) y unas reglas específicas para cada referéndum. Entre las reglas específicas, destaca una limitación a la discrecionalidad del presidente del Gobierno a la hora de decidir hacer un referéndum consultivo: no solo exige el acuerdo del Consejo de Ministros, sino que la autorización del Congreso se tiene que hacer mediante mayoría absoluta; con esta medida, que altera lo que prevé la Constitución, seguramente se quiere evitar que un Gobierno minoritario pueda apelar directamente al pueblo para condicionar la mayoría parlamentaria, y hacer surgir una *democracia plebiscitaria* en contra de la democracia representativa al estilo de la que preconizaba C. Schmitt. En cuanto a las normas comunes para todos los tipos de referéndum, la LO 2/1980 establece que no se pueden celebrar durante los estados de excepción y asedio, ni en los 90 días anteriores o posteriores a la fecha de celebración, en el territorio que afecte, de elecciones parlamentarias, locales o de otro referéndum, salvo los de reforma constitucional.

b) La iniciativa legislativa popular: faculta a los ciudadanos a poner en marcha el proceso de discusión y, eventualmente, de aprobación de una ley. Ahora bien, **la Constitución admite este mecanismo con cautelas e impone unas duras condiciones y restricciones que la ley desarrolla**. Así, la Constitución remite a una ley orgánica, pero **exige** para las proposiciones de ley de iniciativa popular «**no menos de 500.000 firmas acreditadas**», una cifra que fue la finalmente adoptada por la LO 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.

El recelo del constituyente y del legislador hacia este mecanismo de participación semi-directa se pone de manifiesto muy claramente en el mismo preámbulo de la LO 3/1984:

«La regulación constitucional de la iniciativa legislativa popular recoge asimismo las limitaciones propias de este instituto, derivadas de las enseñanzas históricas, que demuestran la facilidad con que el recurso al pronunciamiento popular directo puede servir de vía fácil para manipulaciones demagógicas o, incluso, para intentar legitimar como un supuesto consenso popular lo que no es en sustancia sino la antidemocrática imposición de la voluntad de una minoría.»

Además de este número elevado de firmas, **la Constitución también excluye la iniciativa legislativa popular de determinadas materias**, en una lista amplia y de materias muy relevantes: «no procederá dicha iniciativa en materias propias de la ley orgánica, tributarias o de carácter internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia» (art. 87.3 CE); y tampoco en las leyes que tienen que ser elaboradas por el Gobierno, como la Ley de presupuestos generales del Estado (art. 134.1 CE) y las leyes de planificación económica (art. 131.2 CE), y la reforma constitucional (art. 166 CE).

Finalmente, además de la participación política mediante la elección de representantes, de los mecanismos de participación directa y semidirecta mencionados y de los pequeños municipios que se rigen por el sistema del Consejo Abierto (arts. 140 CE y 29 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local), hay que dejar constancia de que **también se puede participar políticamente cuando se ejercen derechos como el de reunión o manifestación** (art. 21 CE), **asociación** (art. 22 CE), **la libertad de expresión** (art. 20.1.a CE), **de información** (art. 20.1d CE) **o el derecho de petición** (art. 29 CE), que es un derecho que tuvo una gran trascendencia histórica (está en el origen del parlamentarismo) y que a pesar de que a finales del siglo XX había quedado en desuso y algunos autores ya lo consideraban casi inútil, ha tenido un resurgimiento importante a partir de la primera década del siglo XXI mediante internet y, en especial, las redes sociales. Consiste en la posibilidad de dirigirse individual o colectivamente a los poderes públicos (cualquier institución pública, Administración o autoridad) para formular preguntas o hacerles conocer un hecho y reclamar su intervención. De acuerdo con la Constitución, los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar pueden ejercer este derecho solo individualmente y de acuerdo con lo que dispone su legislación específica (art. 29.2 CE). La Ley orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición excluye las solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico ya establezca un procedimiento específico. La Constitución también prevé la petición individual y colectiva por escrito ante las Cortes Generales (art. 77 CE), que ha sido desarrollada por los reglamentos parlamentarios del Congreso, del Senado y también los de las asambleas legislativas autonómicas.

Entre todos los derechos políticos, **hay que destacar especialmente la libertad de expresión y el derecho a la información, porque son fundamentos esenciales de una sociedad democrática**. La opinión y la información crítica sobre asuntos de interés general y sobre instituciones públicas o personas que por el cargo que ocupan tienen interés público deben tener cabida en una democracia avanzada. Tal y como ha remarcado el TEDH, el derecho a la información:

«Comprende no solo las informaciones inofensivas o indiferentes o aquellas que sean favorables; también incluye las que puedan inquietar al Estado o una parte de la población, puesto que así resulta del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no hay una sociedad democrática.» (STEJ, caso Lingens.)

Sin libertad de expresión y de información no habría debate público y, por lo tanto, tampoco opinión pública libremente formada, que es la base del sistema representativo. Por eso, las vulneraciones de estas libertades y sobre todo la posible falta de tutela judicial efectiva sobre estas libertades se tienen que considerar un ataque al núcleo del sistema político democrático, que tendría que poner en alerta y hacer reaccionar a cualquier demócrata. Asimismo, la concentración de la propiedad de los principales medios de comunicación en solo dos o tres grandes grupos empresariales puede reducir la expresión del pluralismo y afectar, por lo tanto, a la calidad de la democracia¹⁸.

(18) Los derechos políticos (y sus límites) y el resto de los derechos fundamentales se explican en la asignatura *Derecho constitucional* del grado de Derecho.

Por otro lado, **aparte de la participación política** (electoral y no electoral), **la Constitución española también contempla otras formas de participación en los asuntos públicos, como la participación en la Administración de justicia mediante la institución del jurado** (art. 125 CE) **y varios mecanismos de participación administrativa.** Así, además del derecho de formar parte de la Administración pública (como funcionario o empleado público), que la Constitución recoge como derecho fundamental (el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, art. 23.2 CE, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, art. 103.3 CE), a lo largo del texto constitucional se prevén otros supuestos de participación administrativa: «la audiencia de los ciudadanos directamente o por medio de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que los afecten» (art. 105.a CE); la participación en la planificación de la actividad económica (art. 131.2 CE); la participación en la programación general de la enseñanza (art. 27.5 CE); la participación de profesores, padres y madres, y alumnos en el control y la gestión de los centros sostenidos con capital público (art. 27.7 CE); la audiencia de las organizaciones de consumidores y usuarios en los temas que puedan afectarlos, en la forma que la ley establezca (art. 51.2 CE), y participación en la Seguridad Social y otros organismos públicos (art. 129.1 CE). Y, más allá de la participación administrativa, la Constitución todavía prevé un supuesto de participación en el ámbito de las relaciones privadas, como es la participación en la empresa (art. 129.2 CE), que se puede entender como una concreción del mandato a los poderes públicos del art. 9.2 CE de «facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». En definitiva, un reflejo del Estado social que veremos a continuación.

2.1.4. El Estado social en la Constitución española

El primer adjetivo que el art. 1.1 CE usa para definir la forma de Estado es «social». Sin embargo, a lo largo del siglo XX y principios del XXI, el término *Estado social* ha sido reivindicado por fuerzas políticas y corrientes doctrinales distintas, de tal manera que se ha convertido en un término multívoco o incluso equívoco (Garrorena). Por eso, **para conocer la significación concreta del término en la Constitución española, hay que ver cómo se desarrolla a lo largo de las cuatro principales manifestaciones que contiene:**

- unas referencias principales contenidas en el preámbulo de la Constitución y sobre todo en el art. 9.2 (en el título preliminar);
- los principios rectores de la política social y económica del capítulo III del título I;
- el conjunto de normas que proporcionan el marco jurídico fundamental para la estructura y el funcionamiento de la actividad económica (conocido como «Constitución económica», que se encuentra básicamente en el título VII, «Economía y hacienda»), y
- una serie de derechos económicos, sociales y culturales que se garantizan en el capítulo II del título I.

Este desarrollo normativo de la definición del Estado como social marca una diferencia relevante respecto a la Constitución alemana, en la cual se inspira el art. 1.1 de la Constitución española, porque el texto constitucional alemán solo contiene la cláusula Estado social sin ninguna norma de desarrollo. En Alemania, la doctrina ha discutido sobre el alcance de aquel precepto, pero coincide en afirmar que, de la cláusula Estado social, no es posible deducir pretensiones jurídicas inmediatas para los ciudadanos y, por lo tanto, tendrá que ser en el desarrollo legislativo donde la fórmula despliegue eficacia práctica. En cambio, en el Estado español, la misma Constitución define mediante normas y principios el alcance de la definición social del Estado; además, ni doctrinal ni jurisprudencialmente se ha cuestionado el valor jurídico de la cláusula Estado social, porque hay consenso sobre el carácter normativo que tiene toda la Constitución. A pesar de esto, tendremos que ver cuál es la eficacia jurídica concreta de los principios y normas constitucionales relativos al Estado social.

1) La igualdad material (art. 9.2 CE) para conseguir «un orden económico y social justo» y «una sociedad democrática avanzada»

En el preámbulo de la Constitución, lo primero que se proclama es la voluntad de «garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes en conformidad con un orden económico y social justo», y más adelante se añade «promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todo el mundo una calidad de vida digna» y «establecer una sociedad democrática avanzada», cosa que una parte de la doctrina ha interpretado como una referencia a la aspiración del poder constituyente de lograr **no solo una democracia política, sino también una «democracia social»**, que tiene que asegurar determinados bienes y prestaciones que garanticen a los ciudadanos las condiciones económicas y sociales suficientes para hacer reales y efectivas la libertad y la igualdad; una democracia **que considera la igualdad material como criterio para su organización política y social**, y que encuentra su concreción en varios preceptos de la Constitución y especialmente en el mandato del art. 9.2 CE.

En efecto, la referencia de principio más importante que concreta el Estado social en la Constitución española es en el título preliminar, en el que se establece que:

«Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los cuales se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.» (Art. 9.2 CE.)

Como hemos visto, se trata de un precepto directamente inspirado en el art. 3.2 de la Constitución italiana de 1947, **que contiene un mandato a los poderes públicos para que configuren una sociedad donde la libertad y la igualdad de los individuos no sean solo formales, teóricas, sino también reales y efectivas**, y concreta más la finalidad del Estado de establecer una «sociedad democrática avanzada». El art. 9.2 CE explicita la ruptura de la rígida separación del Estado y la sociedad defendida por la lógica liberal, y atribuye al Estado una función de intervención en la sociedad para corregir las situaciones de desigualdad. Este mandato de intervención de los poderes públicos presupone reconocer la existencia de un déficit de libertad e igualdad reales en la sociedad, que se considera que hay que compensar legislando y llevando a cabo políticas públicas que favorezcan a los sectores sociales más débiles.

En palabras del TC:

«El art. 9.2 CE expresa la voluntad del constituyente de conseguir no solo la igualdad formal (art. 14 CE), sino también la igualdad sustantiva, al ser consciente de que únicamente desde esta igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del libre desarrollo de la personalidad; por eso, el constituyente completa la vertiente negativa de proscripción de acciones discriminatorias (art. 14 CE) con la positiva de favorecimiento de esta igualdad material.» (STC 12/2008, FJ 4.)

Se introduce, pues, el principio de igualdad material, que es una de las ideas clave del Estado social, como complemento y corrección de la igualdad formal (art. 14 CE), de tal manera que la igualdad ya no es solo igualdad *ante* la ley, sino también *en* la ley, la cual deberá tener en cuenta las diferencias sociales, económicas y culturales que hay en la realidad entre los ciudadanos y, por lo tanto, tendrá que establecer a menudo un trato diferenciado cuando se demuestre que hay una situación realmente diferente que merece una protección especial (STC 34/1981). Lo que no permite el art. 14 CE es tratar de manera diferente a los que son iguales, porque se produciría una discriminación; la igualdad del art. 14 CE no exige la uniformidad, sino la no discriminación. **Para otorgar un tratamiento diferenciado, hace falta que haya una base objetiva y razonable que lo justifique.** Así lo ha recogido el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, lo que se conoce como el *juicio de razonabilidad* (STC 52/2018, 60/2015, entre otros), un criterio que supone que ante un trato desigual, hace falta siempre una ponderación sustantiva (y no solo formal) entre posiciones realmente diferentes (SSTC 22/1981, 200/2001, 213/2005, 112/2006, entre otras muchas). Ahora bien, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, **no solo debe haber una justificación objetiva y razonable, sino que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción tienen que ser proporcionadas a la finalidad perseguida**, de modo que se eviten resultados excesivamente onerosos o desmesurados (entre otras, STC 255/2004, 10/2005, o 83/2014). Con estas cautelas, el art. 9.2 CE ha sido utilizado por el TC, desde muy pronto (STC 3/1983), para superar un concepto meramente formal de igualdad y para justificar un trato diferen-

te, por razón de género, por ejemplo (STC 128/1987), que podría parecer, de entrada, expresamente prohibido por el art. 14 CE, pero que se justifica como una medida correctora en favor de las mujeres trabajadoras, para asegurar una igualdad de oportunidades entre los dos géneros. Así pues, el TC parte del art. 9.2 CE (poniéndolo muchas veces en conexión con la cláusula social del art. 1.1 CE o con otros derechos o principios rectores) para reinterpretar el principio de igualdad y priorizar una idea sustantiva o material de igualdad.

2) Los principios rectores de la política social y económica

Buena parte de los artículos que forman el capítulo III del título I de la Constitución (arts. 39 a 52 CE) **explicitan una serie de mandatos y directrices de intervención y promoción en muchos ámbitos de la política económica y social**: la familia, el trabajo, la Seguridad Social, la emigración, la salud, la vivienda, el consumo, los discapacitados físicos y psíquicos, y las personas de la tercera edad.

En los preceptos del capítulo III, podemos encontrar normas que enuncian finalidades generales de la acción estatal (art. 40.1 y 44.2 CE) y preceptos que podríamos agrupar en cinco grupos, según incluyan normas relativas en la protección de: la familia (arts. 39 y 50 CE); los trabajadores (arts. 40, 41, 42 CE); sectores sociales específicos, como por ejemplo los niños, los jóvenes, los ciudadanos de la tercera edad o los discapacitados (arts. 39.4, 48, 49 y 50 CE); los ciudadanos como demandantes, consumidores o usuarios de bienes y servicios (art. 51, y también 43 y 47 CE), y determinados bienes materiales que tienen un valor y una función de interés general, como el medio ambiente o el patrimonio histórico, cultural y artístico (arts. 45 y 46 CE).

No son, pues, normas que establezcan límites a la actuación del Estado (como la mayoría de los preceptos constitucionales que despliegan el Estado de derecho), sino **normas que fijan a los poderes públicos unos objetivos vinculados al principio social**. Reciben el nombre de **normas de programación final**, que no concretan las conductas que se tienen que llevar a cabo, sino solo un objetivo final, y dejan al sujeto obligado una discrecionalidad para elegir los medios.

La eficacia de estas normas y principios se establece en el art. 53.3 de la misma Constitución:

«El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con aquello que dispongan las leyes que los desarrollen.»

Por lo tanto, **no son derechos subjetivos ni tampoco normas de aplicación inmediata para los ciudadanos**. Son un conjunto de «principios» que **cumplen una función orientadora de la actuación de los poderes públicos** (especialmente del legislativo y el ejecutivo, aunque expresamente se menciona también la práctica judicial), y esto a pesar de que se incluyan en el título I de la Constitución, cuya rúbrica es «de los derechos y deberes fundamentales». Dado que se trata de normas constitucionales y, por lo tanto, parámetro de constitucionalidad, los jueces los deben tener como un elemento indispensable

para la interpretación de las normas jurídicas. Más allá de esta función orientadora para los poderes públicos, **requieren un desarrollo legislativo previo para poder ser alegados ante los tribunales ordinarios**. No tienen eficacia inmediata, como sí la tienen los derechos y libertades del capítulo II (que son invocables directamente ante los tribunales de justicia, sin necesidad de otra norma que los desarrolle). La eficacia de estos principios rectores se despliega básicamente de manera negativa: **es posible cuestionar la inconstitucionalidad de una norma con rango legal que los vulnere**. Cuando el desarrollo legal se produce, los principios rectores **operan como un límite al legislador**, pero para que se pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma que los desarrolle, sería necesario que estuviese en abierta contradicción con los mismos. El TC declaró muy pronto (STC 80/1982) que su valor normativo tiene que ser «modulado» en los términos que establece el art. 53.3 CE, pero que este «impide considerar estos principios como normas sin contenido y que obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes» (STC 19/1982).

Una cuestión diferente es la exigibilidad jurídica a los poderes públicos para que conviertan estos principios en derechos subjetivos, mediante la ley o actos de Gobierno. Esta conversión en derechos supone generalmente la aplicación de recursos económicos, que por definición son escasos; y, en último término, son los ciudadanos quienes definen la aplicación de estos recursos y la medida en que estos principios se convierten en prioridades para los poderes públicos, cuando votan entre los diferentes programas políticos que se presentan a las elecciones.

En el capítulo III, también hay una serie de mandatos a los poderes públicos que no solo orientan la actividad fijando unos objetivos más o menos genéricos, sino **que implican necesariamente una importante actividad prestacional que refuerza el carácter asistencial del Estado**, porque se suman a las prestaciones que el Estado está obligado a llevar a cabo por el hecho de tener que asegurar derechos fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a la enseñanza básica obligatoria y gratuita (art. 27.4 CE), que implica una actividad prestacional muy relevante. Así, **los poderes públicos están obligados a mantener «un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes en las situaciones de necesidad, especialmente en caso de falta de trabajo» (art. 41 CE), y también tendrán que «organizar y tutelar la salud pública» (art. 43 CE).**

3) La «Constitución económica»

La tercera de las concreciones de la cláusula Estado social se despliega en **el conjunto de normas que proporcionan el marco jurídico fundamental para la estructura y el funcionamiento de la actividad económica**, lo que se conoce como «Constitución económica», un concepto elaborado por la doctrina alemana que posteriormente fue adoptado por la jurisprudencia del TC español (STC 1/1982). Estas normas se encuentran básicamente en el título VII de la Constitución («Economía y finanzas»), pero también en algunos otros preceptos situados en el título preliminar y en el título I que, en conjunto, **establecen reglas básicas del proceso económico y de sus actores**. Los prin-

cipales elementos de la constitución económica española se pueden agrupar en dos bloques: la garantía de las libertades económicas clásicas, pero subordinadas al interés general, y el reconocimiento de la intervención pública en la vida económica.

- **La garantía de las libertades económicas clásicas, pero subordinadas al interés general:** la Constitución garantiza como derechos fundamentales la propiedad privada (art. 33.1 CE) y la libertad de empresa dentro del marco de la economía de mercado (art. 38 CE). Sin embargo, no son derechos ilimitados (como sostenía el pensamiento liberal clásico), sino que la Constitución adapta estos derechos a las exigencias del Estado social: la libertad de empresa queda limitada por las «exigencias de la economía general, y en su caso, de la planificación» (art. 38 CE), y se podrá acordar «la intervención de empresas cuando lo exija el interés general» y reservar al sector público determinados bienes o servicios esenciales (art. 128.2 CE); «el interés general para impedir la especulación» es causa legítima para justificar la utilización del suelo (art. 47 CE) y «la función social» del derecho de propiedad y del derecho a la herencia delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes (art. 33.2 CE). Así, el Tribunal Constitucional ha afirmado que «utilidad individual y función social definen, por lo tanto, indivisiblemente el contenido del derecho de propiedad» (STC 37/1987). Y la Constitución aún establece que «la utilidad pública y el interés social» pueden justificar la expropiación de bienes o derechos, con la correspondiente indemnización (art. 33.3 CE), porque «toda la riqueza del país en sus diversas formas, y sea cual sea la titularidad, queda subordinada al interés general» (art. 128.1 CE).
- **El reconocimiento de la intervención pública en la vida económica:** junto a la iniciativa privada, la Constitución reconoce la posibilidad de la iniciativa pública en la actividad económica (art. 128.2 CE), como una manifestación más del principio social. Las empresas públicas habían sido mucho más importantes en el pasado que actualmente, pero todavía hoy son relevantes tanto por el número de empleados que tienen como por el porcentaje de producto interior bruto que generan. Actualmente, el sector público empresarial español incluye diferentes tipos de entidades (las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, consorcios, etc.). Solo una de estas entidades, el grupo SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que es una entidad pública empresarial que desde 1995 sucedió al Instituto Nacional de Industria (INI), está formada actualmente por 16 empresas participadas mayoritariamente y de manera directa por el Estado. Es un grupo de empresas muy diversificado por sus objetos sociales, que incluyen la construcción naval, los medios, la distribución alimentaria, la gestión de infraestructuras, la minería, el cultivo de tabaco, la promoción empresarial, la transformación agraria y medioambiental, el ocio y la energía nuclear, entre otras actividades.

Algunas de las empresas públicas más conocidas son: Renfe operadora, Adif, Enaire (la empresa que tiene el 51 % de Aena no privatizada), Correos, Loterías, Hispasat, Paradores de Turismo, Puertos del Estado, Agencia EFE, RTVE, Navantia o el Hipódromo de la Zarzuela. Aun así, quizá son más conocidas y aún más importantes las empresas que habían sido del Estado y fueron privatizadas (sobre todo en el periodo 1997-2001): Aceralia, Endesa, Iberia, Pegaso, Seat, Repsol, Tabacalera o Telefónica, entre muchas otras.

Además de esta faceta de Estado empresario que la Constitución permite, a lo largo del texto constitucional también se configura la intervención estatal por otras vías, especialmente desde la regulación. Así, la Constitución encomienda a los poderes públicos atender a «la modernización y el desarrollo de todos los sectores económicos», con la finalidad «de equiparar el nivel de vida de todos los españoles» (art. 130.1 CE), y les encomienda también que promuevan «las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, dentro del marco de una política de estabilidad económica», y de manera especial que hagan «una política orientada hacia la plena ocupación» (art. 40.1 CE). La Constitución también hace posible al Estado, mediante ley, «planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y la distribución más justa de esta última» (art. 131.1 CE). Todavía en esta vertiente de Estado regulador, la Constitución recoge el mandato de que la ley regule un Estatuto de los trabajadores (art. 35.2 CE), que regula aspectos esenciales del contrato de trabajo, de los derechos de representación colectiva y reunión de los trabajadores, de la negociación colectiva y de los convenios, y también otras cuestiones del ámbito laboral que los poderes públicos tienen que garantizar, como por ejemplo la seguridad y la higiene en el trabajo, el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral o las vacaciones periódicas retribuidas (art. 40.2 CE).

Además de configurar el Estado en estas dos facetas de Estado empresario y Estado regulador, en su título VII la Constitución recoge un conjunto de disposiciones dedicadas a la Hacienda pública, donde se establecen principios, procedimientos e instituciones relacionadas con los ingresos y los gastos públicos, como por ejemplo el principio de estabilidad presupuestaria, el déficit estructural o la deuda pública (art. 135 CE), que se complementan con principios contenidos en el título I, como el principio de generalidad y progresividad del sistema tributario (art. 31.1 CE) o la eficiencia en el gasto público (art. 31.2 CE).

4) Los derechos económicos, sociales y culturales

Finalmente, la cuarta y última concreción del principio social del art. 1.1 de la Constitución son una serie de derechos de contenido económico, social y cultural reconocidos en el capítulo II del título I, entre los cuales **los más importantes son el derecho a la educación (art. 27 CE) y los derechos vinculados a la protección de los trabajadores:** «el derecho de sindicarse libremente» (art. 28.1 CE), «el derecho a la huelga para la defensa de sus intereses» (art. 28.2 CE), el «derecho a la negociación colectiva» (art. 37.1 CE) y el «derecho

a adoptar medidas de conflicto colectivo» (art. 37.2 CE). Además de estos derechos, en el capítulo II, todavía hay otros como el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32.1 CE), que el TC ha reconocido que incluye también el matrimonio entre personas homosexuales (STC 198/2012), y el derecho al trabajo de todos los españoles, así como el derecho «a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción por medio del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que en ningún caso se pueda hacer discriminación por razón de sexo» (art. 35.1CE).

A diferencia de los principios rectores del capítulo III del título I, **estos derechos del capítulo II tienen fuerza vinculante o eficacia inmediata, es decir, son invocables directamente ante los tribunales de justicia sin necesidad de otra norma que los desarrolle** y que, en el supuesto de que tal desarrollo se produzca, operan como un auténtico límite al legislador.

El art. 53.1 CE establece que los derechos del capítulo II del título I (art. 14-38 CE) «vinculan todos los poderes públicos» y, de manera complementaria, afirma que estos derechos tienen un «contenido esencial» declarado constitucionalmente que los legisladores han de respetar. Es el constituyente quien formuló el contenido del derecho, su núcleo básico. Son derechos de aplicación directa desde el texto constitucional, sin necesitar la interposición de la ley. No dependen del desarrollo legislativo, dado que existen por la misma declaración constitucional. Asimismo, de acuerdo con el art. 53.2 CE, el derecho a la igualdad del art. 14 CE, los derechos de la sección primera del capítulo II del título I (arts. 15 a 29 CE) y el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar del art. 30.2 CE son los que tienen la garantía del recurso de amparo; es decir, a excepción de este último, son el núcleo duro de la declaración constitucional de derechos (los que encontramos del art. 15 al 29 CE) y, por lo tanto, los que reúnen las máximas garantías: tienen también la garantía del recurso preferente y sumario a la vía judicial ordinaria, el recurso de amparo al Tribunal Constitucional, el desarrollo mediante ley orgánica para regular su ejercicio (según el art. 81.1. CE) y solo pueden ser objeto de reforma constitucional según el procedimiento agravado del art. 168 CE, de modo que forman parte del contenido más rígido del texto constitucional. En cambio, en contraposición a todas estas garantías, el art. 53.3 CE establece que los principios del capítulo III del título I solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Tal y como está regulado en la Constitución, el derecho a la educación supone una prestación pública del servicio educativo y, al mismo tiempo, la garantía de la libertad de enseñanza. Es seguramente el derecho que contribuye de una manera más decisiva a crear igualdad de oportunidades. Sin embargo, decidir cuántos recursos económicos públicos se destinan y a qué se destinan es una decisión política que han de tomar las diferentes administraciones implicadas, de acuerdo con las mayorías políticas que hayan votado los ciudadanos en cada momento.

Entre los servicios que presta el Estado español, la enseñanza pública y la subvención de la escuela concertada son una de las partidas sociales más elevadas de los presupuestos públicos de cada año, junto con la sanidad, las pensiones de la Seguridad Social y la asistencia social. Aun así, en otros países de nuestro entorno, los porcentajes destinados a estas cuestiones son más elevados, seguramente porque no los perciben como un gasto, sino como una inversión. De este modo, a pesar de que las cifras varían según las fuentes consultadas, en el 2017 la educación representó un 9,59 % del gasto público español, y la sanidad, un 14,50 %, claramente por debajo del porcentaje que les destinan países como Alemania (11,14 % y 19,65 %) y el Reino Unido de Gran Bretaña (13,88 % y 16,52 %), mientras que el gasto español en defensa fue del 5,75 %, superior al de estos dos países (4,29 % en Alemania y 4,87 % en el Reino Unido). Años atrás, el gasto español

en defensa todavía había sido más alto: por encima del 8 % durante muchos años, y en algunos casos del 10 %.

A partir de estas distintas concreciones del principio social a lo largo del texto constitucional, el Estado español se configura como un Estado regulador, empresario y prestador de servicios, en el que son posibles muchas políticas sociales diferentes, dependiendo de la voluntad política de la mayoría que haya representada en las instituciones.

Con el mismo marco constitucional, de acuerdo con las distintas ideologías políticas que accedan a las diferentes instancias de Gobierno, **se pueden generar propuestas muy diferenciadas en los numerosos ámbitos en los que se despliega el Estado social**. La mayoría parlamentaria en cada momento decidirá cómo se desarrollan normativamente las disposiciones constitucionales que configuran el Estado social y decidirá cuántos recursos públicos se destinan a finalidades sociales y cómo se reparten.

A diferencia de la mayoría de los derechos vinculados al Estado de derecho y de los derechos políticos, la mayoría de los derechos y principios rectores en los que se proyecta la cláusula del Estado social requieren, para ser efectivos, no solo una actividad reguladora, sino también un despliegue de servicios públicos y una potente actividad prestacional.

2.2. La forma de Gobierno: la monarquía parlamentaria

La Constitución de 1978 elige como forma de Gobierno la variante monárquica del sistema parlamentario, la monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE), es decir, un sistema parlamentario que tiene un rey como jefe del Estado. En este concepto de monarquía parlamentaria, aquello que es sustantivo es el parlamentarismo, y lo que es adjetivo es la monarquía, es decir, que el jefe del Estado sea un rey. La opción por la monarquía parlamentaria del art. 1.3 CE es desarrollada en la parte orgánica del texto constitucional (títulos II, III, IV y V).

La Constitución española establece **los elementos que definen la forma de Gobierno como un sistema parlamentario**:

- **El Gobierno deriva del parlamento y ha de tener en todo momento su confianza**. Esta confianza se inicia con el voto de investidura del Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno (art. 99 CE); **para ser elegido, el candidato a presidente** (que no tiene que ser necesariamente parlamentario) **requiere el voto de la mayoría absoluta del Congreso** (el Senado no interviene en la investidura), **pero si no lo obtiene, puede presentarse a una segunda votación** cuarenta y ocho horas después de

la anterior, **en la cual será suficiente la mayoría simple** de la Cámara. La confianza inicial se otorga al presidente y a su programa político de Gobierno, y posteriormente **este presidente elige al resto de los miembros del Gobierno** (art. 100 CE). **A partir de la investidura, la mayoría parlamentaria y el Gobierno actúan de mutuo acuerdo para tomar decisiones políticas**, una parte importante de las cuales se concretarán en la Ley de presupuestos (art. 134 CE) y en el resto de las leyes, que en la actualidad son mayoritariamente de iniciativa del Gobierno (art. 87.1 CE), o en normas gubernamentales con rango de ley que necesitan también la intervención parlamentaria en un momento u otro (arts. 82 y 86).

- **El Gobierno es políticamente responsable de sus actuaciones ante el Congreso de los Diputados** (art. 108 CE). **Si la mayoría parlamentaria rompe la confianza en el Gobierno, este está obligado a dimitir** (art. 114 CE). Así, el Congreso puede cesar al presidente del Gobierno **si aprueba una moción de censura por mayoría absoluta** (art. 113 CE) **o rechaza por mayoría simple una cuestión de confianza** que le sea presentada por el presidente del Gobierno (art. 112 CE). Además de estos mecanismos de exigencia de responsabilidad política (que pueden llevar al cese del Gobierno), que están a disposición solo del Congreso, las dos cámaras (Congreso y Senado) tienen encomendada una función de fiscalización (para conseguir información del Gobierno) y también de impulso de la actividad del Gobierno (arts. 109 a 111 y art. 76 CE).

La función de impulso de la acción política y de Gobierno consiste en las manifestaciones de voluntad del parlamento que señalan los grandes objetivos políticos del Estado y orientan al Gobierno y la Administración indicándoles, si procede, los medios más adecuados para conseguirlos. Los dos procedimientos típicos de la función de impulso son las resoluciones y las mociones.

Los instrumentos del control parlamentario del Gobierno se acostumbran a clasificar en dos grupos según permitan o no una ruptura de la relación de confianza entre el parlamento y el Gobierno. Los primeros, los que permiten exigir la responsabilidad política del Gobierno y, por lo tanto, cesarlo, también llamados mecanismos de control-sanción, son la moción de censura y la cuestión de confianza. Los segundos, encaminados a reclamar al Gobierno explicaciones sobre sus actuaciones o su comportamiento y, en definitiva, a conseguir información del Gobierno (y, por eso, a menudo denominados como instrumentos de control-inspección o control-verificación), son las preguntas y las interpelaciones al Gobierno, las comparecencias y las sesiones informativas de los miembros del Gobierno, y también los debates generales, las solicitudes de información y las comisiones de investigación. Estos instrumentos de control-inspección, aunque directamente no darán lugar a la remoción del Gobierno porque normalmente son utilizados por las minorías (la oposición), pueden ser mecanismos eficaces de control, no solo a efectos de convencer a una mayoría del electorado de votar por otra mayoría posible, sino como desencadenante de un cierto autocontrol del Gobierno.

Las características principales del modelo parlamentario que fija la Constitución española de 1978 son las siguientes:

1) Es un parlamentarismo monista, puesto que el Gobierno deriva solo del Congreso de los Diputados y en ningún momento del jefe del Estado. El Gobierno no necesita la confianza del rey (o reina) para llevar a cabo ninguna de las funciones que tiene encomendadas. **El jefe del Estado tiene que**

nombrar necesariamente al presidente del Gobierno que elija el Congreso (art. 62.d CE) y al resto de los miembros del Gobierno que le proponga el presidente (art. 62.e y 100 CE); el nombramiento y también el cese de estos cargos son actos que la Constitución impone hacer al rey (*actos debidos*), que no implican ningún margen para sus preferencias personales, ningún margen de decisión política. Por lo tanto, tampoco es el jefe del Estado quien puede decidir cesar al Gobierno, en ningún caso, sino que el Gobierno responde de su gestión política ante el Congreso (art. 108 CE), que es el único que lo puede obligar a dimitir (art. 114 CE).

2) Es un parlamentarismo racionalizado en el que el Gobierno tiene el papel principal en la función de dirección política, y los mecanismos de exigencia de la responsabilidad política están configurados para intentar reforzar la estabilidad del Gobierno. Así, a diferencia de la moción de censura clásica (en la que la aprobación de la moción comporta el cese del presidente censurado y la necesidad de que el parlamento elija a un nuevo presidente), **la Constitución española adopta la moción de censura llamada «constructiva»**, inspirándose en el modelo alemán, **que exige que se presente un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno**, de tal manera que si se aprueba la moción por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, **no solo se cesa al presidente censurado, sino que al mismo tiempo se inviste al candidato alternativo como nuevo presidente del Gobierno**¹⁹ (art. 113 CE). Así pues, la Constitución exige conseguir el consenso de una mayoría absoluta del Congreso, no solo en la censura al presidente que está gobernando sino, además, la misma mayoría en torno a un candidato y un programa de Gobierno para que pueda ser elegido nuevo presidente; en cambio, como hemos apuntado, en el procedimiento ordinario de designación (investidura), la Constitución permite la elección del presidente por mayoría simple en segunda votación. Con estas diferentes mayorías, la Constitución facilita la formación del Gobierno y dificulta su censura; ahora bien, en la práctica, estas previsiones, en algunos casos, pueden efectivamente dar estabilidad al Gobierno, pero, en otros, solo conseguirán hacer posible una perdurabilidad más larga del Gobierno, que no son conceptos sinónimos ni se dan siempre conjuntamente. En esta misma línea, cuando se trata de confirmar la confianza parlamentaria en el programa de gobierno (cuestión de confianza), no se mantiene el nivel de exigencia de la mayoría absoluta, sino que es suficiente una mayoría simple (art. 112 CE); así, **si el presidente del Gobierno quiere, puede plantear una cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados** (una vez más, el Senado no interviene para nada) sobre su programa o sobre una declaración de política general, **y se entenderá que la confianza ha sido otorgada solo con el hecho de que voten favorablemente la mayoría simple de los diputados.**

⁽¹⁹⁾Un ejemplo de moción de censura exitosa es la que permitió a quien era candidato del PSOE, Pedro Sánchez, acceder a la presidencia del Gobierno del Estado (2018).



El palacio de la Moncloa es la residencia oficial de la presidencia del Gobierno español y la sede del Gobierno español, pero también la sede del Ministerio de la Presidencia, de la Vicepresidencia y la del portavoz del Gobierno, porque el «complejo de la Moncloa» está formado por trece edificios y jardines con un total de veinte hectáreas de superficie, una de las extensiones de terreno más amplias reservadas a una jefatura de Gobierno en Europa.

La falta de simetría entre censura constructiva e investidura (y cuestión de confianza) es una contradicción que puede producir situaciones paradójicas: a pesar de que no se haya logrado la mayoría absoluta, la votación de una moción de censura puede haber puesto de manifiesto –de manera más o menos inesperada– que el Gobierno solo tiene el apoyo de una mayoría relativa, o incluso ni esto. No es solo que el Gobierno puede tener una mayoría del Congreso en contra (que, aun así, no se ha podido unir en torno a un can-

didato y un programa); puede que el candidato de la moción de censura tenga más votos que el actual presidente, pero que no lo pueda desplazar porque no llega a la mayoría absoluta. Entonces, el presidente y el Gobierno se mantienen en su lugar por «razones jurídicas», pero en una situación de debilidad. La exigencia de la mayoría absoluta habrá permitido la continuidad del Gobierno censurado, pero esta precaria estabilidad del Gobierno puede tener el precio de la ingobernabilidad. El precio de la pérdida constante de sucesivas votaciones y de la imposibilidad de llevar a cabo el programa político del Gobierno. El fracaso o el triunfo dependerán de las expectativas con las que Gobierno y oposición encararán la votación. Así, no siempre el rechazo de una moción de censura refuerza al Gobierno. Con la votación no solo se puede dejar patente ante la opinión pública la situación minoritaria del Gobierno en el Congreso, sino que se pueden poner de manifiesto las contradicciones de la mayoría gobernante o una pérdida de apoyo parlamentario en relación con una votación anterior (investidura, cuestión de confianza, presupuestos o alguna otra votación de especial trascendencia para el Gobierno).

Finalmente, como sucede en la mayoría de los sistemas parlamentarios racionalizados, **la Constitución atribuye al presidente del Gobierno la facultad discrecional de disolver anticipadamente** (antes de que se acabe la legislatura) **una de las dos cámaras parlamentarias** (el Congreso o el Senado) **o el conjunto de las dos cámaras** (las Cortes Generales); **la decisión de disolver corresponde al presidente** (aunque se formaliza con un decreto firmado por el rey) **y solo requiere la deliberación previa del Gobierno** (art. 115 CE). Ahora bien, la Constitución establece una limitación temporal en la facultad presidencial de disolver anticipadamente el parlamento, **en una muestra clara de parlamentarismo racionalizado: no se puede disolver ninguna de las dos cámaras cuando haya en trámite una moción de censura** (se quiere impedir que el presidente pudiera evitar la censura y, por lo tanto, su cese).

Históricamente, en un inicio, la disolución fue una facultad que ostentaban algunos monarcas del Antiguo Régimen y que usaban como medio para deshacerse de un parlamento hostil, como pasó en Inglaterra. Posteriormente, con el Estado constitucional, la disolución del parlamento pierde este carácter y se transforma en un instrumento para resolver conflictos entre el poder legislativo y el ejecutivo. La facultad presidencial de disolver el parlamento deviene un contrapeso a la posibilidad de exigencia de responsabilidad política a manos del parlamento; la disolución se presenta como un arma de la que dispone el Gobierno, sobre todo para disciplinar la mayoría parlamentaria: si esta no facilita la gobernabilidad dando apoyo parlamentario a las iniciativas del Gobierno que requieran ser vehiculadas por el parlamento, el Gobierno puede replicar disolviendo el parlamento y convocando nuevas elecciones, en las cuales estos parlamentarios tendrán que afrontar el riesgo de perder su escaño. Es una apelación al pueblo para que dirima un conflicto surgido entre la mayoría del parlamento y el Gobierno: las elecciones confirmarán al Gobierno, si resulta una nueva mayoría afín, o provocarán su sustitución, en caso contrario. Sin embargo, el sentido de la disolución volvió a cambiar, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el parlamentarismo se basa en grandes partidos centralizados y muy disciplinados, en los que es poco frecuente que la mayoría parlamentaria ponga problemas al Gobierno. En este marco, hoy la disolución anticipada teóricamente puede continuar siendo una posibilidad de apelar a la ciudadanía cuando el Gobierno necesita hacer una corrección muy importante en su programa político o cuando se presenta una situación muy relevante no prevista. Sin embargo, en la mayoría de los casos, hoy día, la disolución es un instrumento a manos del presidente o del Gobierno para convocar elecciones en el momento que considere políticamente más favorable a sus intereses partidistas. Poder decidir de manera unilateral y por sorpresa la fecha de las elecciones se convierte en una ventaja para la formación política del presidente.

Por otro lado, si se observa el panorama internacional, se puede comprobar que hay una tendencia general contraria a la disolución de las asambleas que no pueden exigir responsabilidad política al Gobierno (es el caso de Reino Unido, Francia o de la República Federal Alemana, entre otros). Sí existe, en cambio, esta posibilidad en el caso de las segundas cámaras que pueden exigir esta responsabilidad, como ocurre en Italia. En el caso español, la solución adoptada por la Constitución española (poder disolver el Congreso o el Senado, o las dos cámaras a la vez) no parecería de entrada la más lógica, porque la relación de confianza con el Gobierno se produce respecto al Congreso de los Diputados y nunca respecto al Senado. Sin embargo, si el objetivo de la disolución fuera resolver

los posibles conflictos entre el parlamento y el Gobierno, y teniendo en cuenta que el sistema electoral establecido no solo permite, sino que favorece que pueda haber mayorías políticamente diferentes (y enfrentadas) en el Congreso y en el Senado, la solución constitucional podría tener un sentido práctico para resolver situaciones de ingobernabilidad que podría provocar una mayoría del Senado frontalmente opuesta a la que en el Congreso diese apoyo al Gobierno.

3) **Es un parlamentarismo con preeminencia del presidente** en el seno del Gobierno y en las relaciones con las Cortes Generales, **y enmarcado en un bicameralismo imperfecto** (con más peso del Congreso de los Diputados que del Senado). La preeminencia del presidente respecto a los otros miembros del Gobierno se pone de manifiesto, por un lado, en que **la relación de confianza con el parlamento se establece solo con él** (investidura individual), y es el **presidente quien fija el programa de Gobierno antes de que el Gobierno exista formalmente**; por otro lado, la preeminencia (que no supremacía) del presidente o presidenta en el seno del poder ejecutivo es determinada también porque, además de tener importantes funciones propias (puede presentar una cuestión de confianza o disolver las cámaras sin que le haga falta el acuerdo del Gobierno, solo con la deliberación previa del Consejo de Ministros), **dirige y coordina la acción del Gobierno y disfruta de una disponibilidad externa sobre el mismo** (nombra y destituye libremente a los ministros y al resto de los miembros del Gobierno). **En relación con el parlamento, también se puede observar una cierta preeminencia del presidente del Gobierno** en la facultad discrecional de disolver anticipadamente las cámaras y en la protección que la Constitución da a los gobiernos minoritarios (por la combinación de mayoría simple para la investidura y para la cuestión de confianza, y de mayoría absoluta para la moción de censura constructiva), pero sobre todo porque con mucha frecuencia, en la práctica, el presidente del Gobierno es también el líder del partido más importante de los que conforman la mayoría parlamentaria y, por lo tanto, de hecho, es el líder de la mayoría del parlamento quien teóricamente tiene que controlar su acción política, hasta el extremo de que podría forzar su cese. Finalmente, tal y como se ha apuntado, también hay que destacar que **el modelo parlamentario que establece la Constitución se da en un bicameralismo que se caracteriza por ser asimétrico y desigual**, con predominio del Congreso de los Diputados. El bicameralismo español es asimétrico porque hay atribuciones propias de una cámara en las cuales la otra no interviene. Y es desigual porque en aquello que sí hacen las dos cámaras, no tienen la misma posición, los mismos poderes. En conjunto, **hay un claro predominio del Congreso de los Diputados**, no solo porque tiene encomendadas muchas e importantes atribuciones exclusivas en las que el Senado no participa (asimetría), sino también porque en las funciones que ejercen de manera compartida, el Senado tiene un papel secundario. Las dos principales expresiones de este predominio del Congreso se encuentran en la relación de confianza con el Gobierno, que se establece solo con el Congreso (la investidura del presidente del Gobierno, la moción de censura y la cuestión de confianza), y en el procedimiento legislativo, en el que, como hemos visto, la función del Senado es la de cámara de segunda



Sede del Congreso de los Diputados, en Madrid.

lectura, y las modificaciones que quiera introducir –por medio del veto o de enmiendas– al proyecto que le remite el Congreso acaban siendo resueltas por este, sin la posterior intervención del Senado.

Solo en un caso la asimetría favorece al Senado (art. 155.1 CE). Solo en tres casos en los que tienen que actuar las dos cámaras, están en una posición homogénea (tienen los mismos poderes): la autorización para la guerra y la paz (art. 63.3 CE); la revisión total o la reforma parcial de la Constitución que exija seguir el procedimiento del art. 168 CE, y el supuesto excepcional previsto en el art. 150.3 CE (apreciar que hay interés general para dictar una ley de armonización, decisión que requiere la mayoría absoluta de cada cámara).



Salón de Plenos del Senado.

4) Es un parlamentarismo con un jefe del Estado con funciones básicamente simbólicas y representativas, que no puede tomar decisiones políticas (ni legislativas ni ejecutivas), ni tampoco puede ejercer la potestad jurisdiccional. La Constitución establece que el órgano de jefe del Estado (la *jefatura del Estado*) recae en la institución de la Corona, que **no es un órgano soberano, sino** una institución del Estado, **un órgano constitucional cuyo titular es el rey. Las atribuciones del rey derivan de la Constitución, y están tasadas por la Constitución.** En consecuencia, el rey no tiene poderes ni funciones implícitas. **Las funciones que le encomienda la CE las ejerce por medio de actos debidos**, actos que está obligado a efectuar. La Constitución regula la Corona en su título II (art. 56 al 65), como una institución que expresa la unidad del Estado y establece que la titularidad es vitalicia, y que se transmite por herencia de acuerdo con las reglas previstas en la Constitución; por lo tanto, el rey no puede dejar en herencia la Corona a quien quiera, sino **que el orden sucesorio está establecido en la Constitución.**



Antes de que se aprobara la Constitución, el orden sucesorio no se respetó con Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, que no fue nunca rey de España.

Las causas de sucesión a la Corona son la muerte, la renuncia (antes de reinar) o la abdicación. La Constitución también prevé el supuesto excepcional de que el rey sea menor de edad o estuviera inhabilitado (art. 59): para estos supuestos, se prevé la figura de una Regencia (el titular de la Corona seguiría siendo el rey, pero las funciones de jefe del Estado las ejercería en nombre del rey la persona que ocupara la Regencia). Cuando la Regencia tuviera lugar por minoría de edad, la Constitución también prevé la tutela (art. 60.1 CE).

El rey no puede tomar ninguna decisión política, debido a su carácter no electivo ni responsable. Solo pueden tomar decisiones políticas los representantes políticos de los ciudadanos, que son elegidos por los ciudadanos y tienen que revalidar la representación periódicamente en las elecciones. El rey no representa a los ciudadanos, porque no ha sido elegido. **El rey representa al Estado.** En una monarquía parlamentaria, a menudo se afirma que «el rey reina, pero no gobierna»; en el Estado español, el rey no participa en la dirección política del Estado, es decir, **no ejerce ninguno de los tres poderes del Estado:** ni el poder legislativo (que corresponde a las Cortes Generales), ni el ejecutivo (que corresponde al Gobierno, del cual el rey no forma parte), ni el judicial (que la Constitución atribuye en exclusiva a jueces y tribunales). En una monarquía parlamentaria, el rey no ejerce poderes políticos, sino solo funciones simbólicas y representativas como jefe del Estado; y se limita a hacer «actos debidos» que exteriorizan (solemnizan) decisiones políticas que han tomado otros órganos del Estado. **Por lo tanto, estas funciones simbólicas y**

representativas que le encomienda la Constitución las ejerce por medio de actos debidos, actos que está obligado a hacer; son actos que, a pesar de que no decide su contenido, el rey no puede dejar de hacer. Jurídicamente, la voluntad del rey no cuenta, son atribuciones de carácter formal, porque el rey se limita a solemnizar la decisión previamente adoptada por otro órgano estatal.

En la mayoría de las monarquías europeas, las funciones y el estatus del rey no están regulados en detalle en la constitución, sino que están regidos por costumbres y convenciones, resultado de la práctica constitucional de muchos años. En cambio, en el Estado español, el singular proceso de instauración de la monarquía parlamentaria es lo que explica que la Constitución regule con cierto detalle las funciones y el estatus del rey en la forma parlamentaria de gobierno, y exprese en derecho escrito lo que en muchas monarquías europeas solo son costumbres y convenciones (resultado de un lento proceso de práctica política).

La monarquía parlamentaria no es fruto de una construcción teórica, sino el resultado de la incorporación de prácticas y costumbres a la vida política, a menudo al margen de las previsiones constitucionales²⁰. Así ha sucedido en buena parte de las monarquías del centro y norte de Europa, donde las constituciones atribuyen (todavía hoy) poderes políticos al rey (en especial la dirección del Gobierno), pero las prácticas políticas han llevado progresivamente a la «parlamentarización» de la monarquía: el Gobierno deviene un órgano colegiado, al margen del rey, que necesita solo la confianza del parlamento; el monarca no ejerce poderes políticos, sino solo poderes simbólicos.

Al contrario de estos países, la instauración de la monarquía parlamentaria en el Estado español no es el resultado de un lento proceso de práctica política, porque a lo largo de la historia constitucional española la monarquía tuvo un carácter absolutista y antidemocrático que impidió la parlamentarización. La monarquía parlamentaria no se establece hasta la Constitución de 1978.

Los actos que la Constitución encomienda al rey necesitan, para ser válidos, el refrendo, es decir, la firma de otra persona que acompañe la firma del jefe del Estado. Salvo los dos casos que prevé el art. 65 CE, **todos los actos del rey tienen que ir refrendados; si no es así, son inválidos**.

La excepción la establece el art. 65 CE, al prever que el rey distribuye «libremente» la cantidad global que recibe de los presupuestos del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa, y al prever también que nombra y releva «libremente» a los miembros civiles y militares de su Casa. Aun así, sin alterar el carácter libre de la decisión real, el RD 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de S. M. el rey, los nombramientos de los altos cargos de esta institución tienen que ser llevados a cabo mediante real decreto, es decir, necesitan refrendo.

Solo pueden refrendar los actos del rey: el presidente del Gobierno, los ministros y, en dos casos concretos, el presidente del Congreso (propuesta y nombramiento del presidente del Gobierno). Si de los actos que el rey está obligado a hacer se derivase alguna responsabilidad, la asumirían quienes refrenden estos actos (art. 64 CE). Por lo tanto, **la firma es un mecanismo para trasladar la responsabilidad de los actos debidos que hace el rey a aquellos que los refrendan**²¹ (que no siempre son quienes han tomado realmente la decisión de efectuar aquel acto). **Hay varios tipos de refrendo**: explícito (con la firma físicamente junto a la del rey), tácito (la presencia en un deter-

(20) El jefe del Estado en el Reino Unido, Holanda o Bélgica tiene algunas posibilidades de intervención política de acuerdo con sus textos constitucionales, mientras que en Japón o Suecia la figura es únicamente simbólica.



El actual rey de España, Felipe VI, con su padre, Juan Carlos I, de quien heredó la corona.

(21) La Corona es un órgano constitucional sin responsabilidad política, porque no puede tomar decisiones políticas.

minado acto, como por ejemplo una inauguración, del llamado «ministro de jornada»), o presunto (por ejemplo, el de las alocuciones en actos públicos e, incluso, los discursos de Navidad).

Finalmente, **dos elementos característicos de la posición jurídica del rey son la irresponsabilidad** por los actos políticos que lleva a cabo (que está obligado a hacer) como jefe del Estado, **y la inviolabilidad**, es decir, la imposibilidad de ser juzgado de acuerdo con las leyes penales²² (la responsabilidad civil se vehicularía por medio del jefe de la Casa Real, que es una parte de la Administración del Estado, aunque con características muy especiales).

(22) La Constitución opta por un jefe del Estado no elegido, vitalicio, hereditario y no sujeto a responsabilidad (ni política ni jurídica).

2.3. La forma de organización territorial: el Estado de las autonomías

La fórmula de «Estado de las autonomías» o «Estado autonómico» no aparece en el texto constitucional. Para definir el tipo de organización territorial, **la Constitución no contiene una fórmula definitoria** similar a las que encontramos en relación con la forma de Estado o a la forma de gobierno. **Es la doctrina la que ha utilizado estas expresiones** («Estado de las autonomías» o «Estado autonómico») **para definir el tipo de organización territorial de la Constitución española de 1978.**

A continuación, expondremos sintéticamente las principales razones de la descentralización política y los principios constitucionales básicos del Estado autonómico español, que lo sitúan dentro de la categoría de Estado compuesto (que ya hemos explicado); también repasaremos brevemente la evolución del proceso autonómico que ha llevado a la actual concreción del Estado de las autonomías. Nos limitaremos a dar una visión básica y general porque en la asignatura *Derecho constitucional*, del grado de Derecho, que es la continuación natural de *Sistema constitucional español*, se profundiza en lo que aquí se explica y se completa con la exposición de la organización institucional de las comunidades autónomas, el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, o los sistemas de financiación de estas últimas.

1) Las razones de la descentralización política

La Constitución de 1978, elaborada y aprobada durante la transición, **tenía que dar respuesta a algunos de los problemas pendientes de la historia constitucional española**: la posición de la monarquía, el asentamiento de un sistema democrático, la sujeción del ejército a las instituciones civiles, las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado y, **muy especialmente, la llamada «cuestión nacional»**. Esta última, **a diferencia de las otras, no estaba resuelta social ni políticamente al final de la década de los setenta** y, por eso, se tenía que solucionar constitucionalmente. Y no solo no estaba resuelta, sino que era la cuestión constitucional clave.

El «problema» vasco y catalán se vincula a la estructura del Estado para decir que es «un problema de ser o no ser», porque «no se trataba de cómo estructurar mejor el poder territorial del Estado, sino, en el límite, de formar parte o no de ese Estado». Dotar al Estado de una nueva organización territorial que diera respuesta a las aspiraciones políticas de las llamadas nacionalidades históricas era quizá el problema constitucional más difícil, pero, sin duda, el más decisivo de los que la desafortunada historia política ochocentista dejaba en legado a los constituyentes de 1977.

Lectura complementaria

F. Tomás y Valiente (1993). «La primera fase de construcción del Estado de las autonomías (1978-1983)». *Revista Vasca de Administración Pública* (núm. 36, pág. 42).

La descentralización política plasmada en la Constitución podía perseguir otros objetivos adicionales (acercar el poder público a los ciudadanos, aumentar la eficacia de la Administración, colaborar a una mejor distribución de recursos), **pero su origen concreto se encuentra en la voluntad de integrar unas comunidades con un nombre propio en una unidad política más amplia**, el Estado español. Ciertamente, el Estado autonómico también se propone sustituir el viejo Estado unitario español, que tiene un carácter autoritario, burocrático y centralizado heredado del franquismo, por un Estado más moderno, participativo y eficaz. Esto es lo que lleva al profesor Linz a hablar de la «simultaneidad de las dos transiciones políticas» en el Estado español: la de un régimen autoritario a un régimen democrático, y la de un Estado unitario y centralista a un Estado políticamente descentralizado en autonomías.

Lectura complementaria

J. J. Linz (1985). «De la crisis de un Estado unitario al Estado de las autonomías». En: F. Fernández Rodríguez (ed.): *La España de las Autonomías*. Madrid: Instituto de Estudios de la Administración Local.

De hecho, la transición española coincide cronológicamente con un movimiento de regionalización en algunos países de Europa, entre estos, incluso, Francia y Gran Bretaña, aunque de manera tardía y limitada. A pesar de que en 1979 fracasa un primer proyecto de «devolución» de poderes a Escocia y a Gales, durante los años setenta se pusieron en marcha en Italia las autonomías regionales de estatuto ordinario, se crearon las regiones lingüísticas de Bélgica (reformas constitucionales de 1970 y 1980), se había aceptado una autonomía parcial en Portugal e, incluso, en Francia –paradigma del centralismo contemporáneo– se hablaba de regionalización.

Sin embargo, **la raíz del Estado de las autonomías solo se puede comprender desde una perspectiva histórica**: aparece en el proceso constituyente como una fórmula específicamente diseñada **para resolver unos problemas concretos, planteados en los últimos dos siglos (e incluso antes)**, entre el poder central y las comunidades vasca y catalana y, en menor medida, la gallega, que mantienen una identidad colectiva diferenciada y manifiestan políticamente una voluntad de autogobierno.

Tal y como recuerda Enric Fossas, la construcción institucional del Estado español durante los siglos XVIII y XIX no consiguió crear una comunidad nacional estable. En el siglo XIX, la monarquía borbónica intentó imponer un Estado uniforme y centralista inspirado en los esquemas del jacobinismo francés, utilizando el constitucionalismo, la codificación, el ejército y el mercado. Sin embargo, ni el Estado español tuvo éxito, como el francés, en eliminar o diluir las comunidades nacionales preexistentes, ni estas, por su parte, tuvieron nunca proyectos secesionistas hegemónicos. Tampoco tuvieron éxito los intentos de encontrar fórmulas constitucionales para integrar estas comunidades en una organización política descentralizada o compuesta; más bien, acabaron mal: la Primera República, con la Restauración; la Mancomunidad, con la dictadura de Primo de Rivera, y la Segunda República, con el régimen autoritario del general Franco (E. Fossas, 1998. «El model de l'estat de les autonomies a la llum de les diferents experiències comparades». En: J. Colominas, coord. *Catalunya-Espanya. Les relacions històriques, culturals i polítiques*, págs. 98-99. Barcelona: Fundació Ramon Trias Fargas-Columna). Como ha escrito Carles Viver, el objetivo último del Estado autonómico es «la creación de una organización estatal acorde, por primera vez en nuestra historia reciente, con la existencia de diver-

sas naciones o nacionalidades que han mostrado reiteradamente su voluntad de autogobierno» (C. Viver y Pi-Sunyer, 1994. *Las autonomías políticas*, pág. 9. Madrid: IEE).

No se tendría que olvidar, pues, cuando se analiza (y cuando se desarrolla) el sistema autonómico, que su origen último no es la solución de un problema técnico, sino fundamentalmente la de un problema político complejo y secular. El desarrollo práctico de las previsiones constitucionales, después de muchos años de vigencia de la Constitución, nos lleva a considerar que se ha conseguido más el propósito de acercar el poder político a la ciudadanía que el de acomodar dentro del Estado la voluntad mayoritaria de las denominadas nacionalidades históricas.

2) El Estado de las autonomías como Estado compuesto

La expresión «Estado autonómico» o «Estado de las autonomías» hace referencia a la forma de organización territorial del actual Estado español, que **es un tipo de Estado compuesto, diferente del Estado federal**, donde el poder político está descentralizado en las distintas comunidades autónomas que se han constituido en el mismo. Ya hemos visto que el Estado federal ha evolucionado mucho y tiene múltiples manifestaciones, pero podemos considerar que se caracteriza por ser un Estado de estados, donde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son divididos territorialmente, hay una idea de pacto entre los diferentes territorios, que se muestra en la génesis y en la reforma de la constitución, así como en la integración de las partes –estados miembros– en la federación.

El Estado autonómico, en cambio, es consecuencia de la descentralización de un Estado unitario, que distribuye territorialmente el poder político (legislativo y ejecutivo), pero no el poder judicial, que es único para todo el conjunto del Estado, lo cual no quiere decir que no se organice en el territorio, sino que no está afectado por el principio de la división territorial del poder político (no está dividido). **En el Estado autonómico, el poder constituyente y el de reforma es único:** solo hay un poder constituyente que, de acuerdo con lo que establece la Constitución, reside en la nación española, y de la que también deriva el poder de reforma constitucional (las comunidades autónomas solo pueden participar en la fase de iniciativa, según el art. 166 CE). **Los estatutos de autonomía completan una Constitución deseadamente abierta**, y forman parte del «bloque de constitucionalidad» que distribuye las competencias entre los órganos centrales o generales y los autonómicos que, además de las competencias propias, teóricamente tienen mecanismos para participar en la conformación de algunos órganos generales del Estado. Sin embargo, al menos hasta ahora, las comunidades autónomas no acaban de participar realmente en las instituciones generales del Estado: pensemos en la composición del Senado, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, etc. Por esta vía, observamos las dificultades de la integración del pluralismo territorial en los órganos del Estado español.

3) Los principios constitucionales del Estado autonómico

El artículo 2 de la Constitución de 1978 incluye el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, enmarcado en el contexto de la unidad española:

«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.»

Como se puede observar, se trata de una redacción muy reiterativa que refleja la transacción entre puntos de vista diferentes (y hasta cierto punto contradictorios) en relación con la organización territorial del Estado español.

Los sucesivos proyectos a lo largo del proceso de elaboración de la Constitución fueron modificados, que se sepa, al menos cuatro veces como consecuencia de **la presión militar**; la modificación más importante de todas ellas **obligó a reformular el art. 2, en el que se introdujo el concepto de «Nación española, patria común e indivisible»**. Tanto Miquel Roca como Jordi Solé Tura, miembros de la ponencia constitucional, han explicado cómo se negoció el art. 2:

«Cuando negocié personalmente en la Moncloa con Adolfo Suárez la inclusión del término *nacionalidades* en la Constitución, en la habitación de al lado había un conjunto de militares con quienes iba consultando.» (Entrevista a Miquel Roca, *Avui*, 6 de diciembre de 1998, pág. 22.)

Solé Tura también pone de manifiesto la intervención decisiva de las Fuerzas Armadas cuando explica la aceptación de la redacción del art. 2 CE (*Nacionalidades y nacionalismos en España*, 1985, pág. 100, Madrid: Alianza); ved también la versión catalana, parcialmente distinta y, en este aspecto que comentamos, más explícita: *Autonomies, Federalisme i Autodeterminació*, 1987, pág. 82, Barcelona: Laia.

En el primer borrador, elaborado por la ponencia parlamentaria durante la primera lectura, dedicada a convertir en un solo texto los diferentes borradores de los partidos, el art. 2 presentaba la redacción siguiente:

«La Constitución reconoce y la Monarquía garantiza el derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones que integran España, la unidad del Estado y la solidaridad entre sus pueblos».

Observemos que, además de aparecer ya el término nacionalidades, se habla de los diferentes pueblos del Estado y la unidad se refiere al Estado y no, como en el texto actualmente vigente, a la Nación española, que es un concepto que no está presente, como tampoco encontramos la referencia a la «patria común e indivisible de todos los españoles».

La presencia del término «nacionalidades» es consecuencia de la voluntad de los grupos nacionalistas catalanes y vascos. Se piensa en Cataluña, Euskadi y Galicia, a pesar de que no están mencionadas expresamente y, en todo caso, se quiere diferenciar unos territorios que presentan un fuerte sentimiento de identidad preexistente de otros en los que no es así. Aun así, hasta ahora no se ha asociado ninguna consecuencia jurídica específica a los estatutos de autonomía que han optado por la definición de un territorio como nacionalidad o como región.

Por otro lado, en el art. 2 CE se recogen **los principios en torno a los cuales se estructura el Estado: la unidad, la autonomía y la solidaridad**. Sin embargo, además de estos principios explicitados en la Constitución, **hay que añadir otro implícito** sobre el cual se ha construido el Estado de las autonomías: **el principio dispositivo**.

La **unidad** supone que el Estado español es un único Estado soberano, cuyos poderes emanan del pueblo español (art. 1.2 CE). El principio de autonomía no puede articularse en contra del principio de unidad, puesto que en su marco encuentra todo su significado. No son principios opuestos, sino complementarios. La unidad tiene que respetar el pluralismo y la diversidad, porque no significa **uniformidad ni centralización**, sino que es el resultado de una integración de los diferentes entes autonómicos en la unidad estatal. Por eso, **la Constitución establece técnicas de integración para reconducir la diversidad a un régimen unitario**, como por ejemplo la solidaridad (arts. 2 y 138, entre otros); la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español (art. 139.1); la libertad de circulación y de establecimiento de personas y la libre circulación de bienes (art. 139.2); la ordenación del reparto de competencias, con las correspondientes cláusulas de cierre y la cláusula de supletoriedad (art. 149.3); los mecanismos de resolución de conflictos competenciales mediante la intervención del Tribunal Constitucional (art. 161.1 c); y el deber de cooperación leal entre las diferentes instancias de poder.

La autonomía es un principio estructurador de todo el ordenamiento jurídico, porque afecta a la división llamada vertical (o territorial) del poder político, entre todas las instancias en las que se organiza territorialmente el Estado español. **La autonomía es un derecho que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones**, poniendo de manifiesto que tienen una existencia previa a la norma fundamental. **El contenido de este derecho consiste en la posibilidad de devenir una comunidad autónoma** mediante los procedimientos previstos en el **título VIII de la Constitución**.

El art. 137 reconoce dos tipos de autonomía, la local (puramente administrativa) y la de las comunidades autónomas (política), **cualitativamente diferentes**. Estas últimas disfrutan de un grado más intenso de autonomía, según ha expresado la jurisprudencia constitucional (STC 4/1981, de 2 de febrero; STC 35/1982, de 14 de junio), porque son titulares de la potestad legislativa y porque disfrutan de unas competencias propias que han asumido en los respectivos estatutos de autonomía. Hay que recordar que la autonomía política de las comunidades autónomas deriva del bloque de la constitucionalidad formado por la Constitución y los estatutos de autonomía, y no está disponible para el Estado. Ahora bien, **la autonomía se configura como un ámbito de poder o de decisión limitado por definición** (la autonomía no es soberanía). **No obstante, aun así, implica capacidad de autogobierno, de autoorganización institucional, de crear políticas públicas propias y de elaborar normas jurídicas**. En todo caso, el poder político que deriva de la

autonomía comparte las características del poder estatal (en este sentido, podemos decir que las comunidades autónomas son parte del Estado español), dado que se ejercen funciones legislativas y ejecutivas. También hay que recordar la importancia de la autonomía financiera, que implica poder disfrutar de recursos suficientes para hacer frente a las competencias asumidas; pero este es un aspecto discutido y renegociado muchas veces, y aún no cerrado definitivamente.

El tercer gran principio sobre el que se fundamenta el Estado autonómico es el de **solidaridad**, establecido también de manera explícita por la Constitución (arts. 2 y 138) y que, según el TC, **implica que todas las instancias de gobierno (Estado y comunidades) están unidas por el interés general que todas comparten y están obligadas a promover**. Este vínculo de solidaridad no tiene solo un contenido político (promover una actitud de respeto y colaboración entre las distintas instancias de gobierno), sino que se expresa también en términos jurídicos constitucionales como un deber que obliga a todas las partes en sus relaciones recíprocas. En este sentido jurídico, la solidaridad presenta dos dimensiones: por un lado, el principio de solidaridad se traduce en el hecho de que cada parte tiene que actuar de modo que no obstaculice el ejercicio de las competencias de las otras y tiene que ponderar los intereses generales y los de las otras partes, puesto que, si se lesionan estos intereses, la actuación resultará ilegítima; en esta vertiente, el principio de solidaridad **supone un deber de lealtad constitucional o lealtad institucional** que, por el hecho de ser considerado un deber jurídico y constitucional, significa que está sometido al control jurisdiccional, del Tribunal Constitucional o de los tribunales ordinarios, en función del tipo de actuación que se considere ilegítima (SSTC 46/1990 y 64/1990). Por otro lado, el principio de solidaridad **también deriva hacia un deber mutuo de asistencia y auxilio**, e implica para cada instancia de gobierno el deber de contribuir al hecho de que las otras puedan ejercer adecuadamente sus competencias, llevando a cabo las actuaciones que sean necesarias para que las otras instancias puedan cumplir de manera correcta sus funciones (SSTC 80/1985 y 133/1990, entre otras).

Otro elemento importante que hay que destacar de las previsiones constitucionales es el **principio dispositivo, un principio no escrito, pero que está en la base de todo el proceso autonómico y constituye una singularidad de la Constitución española** y, según coincide en destacar la mayoría de la doctrina, la principal aportación de los constituyentes del 78 al conjunto del constitucionalismo. Porque la Constitución no establece ningún mapa autonómico, no dice qué comunidades autónomas habrá, ni las competencias concretas de cada una. Como se ha apuntado, los estatutos de autonomía completan la Constitución en este punto: constituyen la comunidad autónoma y establecen qué competencias asume y cuáles son sus principales instituciones de gobierno. Como hemos visto en el módulo 2, los estatutos de autonomía son aprobados por las Cortes Generales, como leyes orgánicas, de modo que son reconocidos por el Estado y forman parte así también de su ordenamiento jurídico, pero al mismo tiempo son la norma institucional básica de la comu-

nidad autónoma. Por lo tanto, la Constitución se limita básicamente a establecer unos principios (unidad, autonomía, solidaridad) y unos procedimientos para que los diferentes territorios accedan a la autonomía; establece varias vías de acceso por medio de las cuales se condiciona el nivel de competencias que se pueden asumir en un primer momento.

Las dos vías más importantes de acceso a la autonomía que establece la Constitución **son la vía general del art. 143** y siguientes (conocida también como vía lenta), **y la especial del art. 151** y siguientes (denominada vía rápida), a pesar de que el título VIII CE recoge otras particularidades para casos concretos. **En el caso de Cataluña, Euskadi y Galicia se usó la vía especial, pero matizada por lo que establece la disposición transitoria segunda de la CE**, que afirma que los territorios que hubieran plebiscitado un régimen de autonomía en el pasado (referencia implícita a la Segunda República), y que en el momento de promulgarse la Constitución tuvieran un régimen provisional de autonomía, quedan exonerados del requisito del referéndum de iniciativa autonómica, es decir, se considera que ya han demostrado en otro momento histórico su interés para acceder a la autonomía. **También usó la denominada vía rápida o especial Andalucía**, que aun así tuvo que recurrir al referéndum de iniciativa autonómica. **El resto de las comunidades autónomas** (excepto Navarra) **se constituyeron por la vía lenta del art. 143**, con un nivel de competencias menor en un primer momento, pero con la facultad de lograr más competencias cuando hubieran transcurrido cinco años.

4) La evolución del Estado autonómico

El Estado de las autonomías que tenemos actualmente ha sido «una concreción» de las disposiciones constitucionales, pero con el mismo texto constitucional hubiese podido tener otras. De hecho, el Estado de las autonomías se ha forjado por medio de un proceso que todavía está abierto: puede acabar de desarrollarse o puede involucionar.

De este modo, **el Estado de las autonomías es un modelo en parte preconstitucional** porque, como hemos visto, antes de que se aprobara la Constitución se dieron unos regímenes provisionales de autonomía (las llamadas preautonomías), que condicionaron al menos parcialmente la situación posterior, **y en parte subconstitucional**, porque la concreción de algunos de sus rasgos característicos no se encuentra en la misma Constitución, sino que se han concretado en primer lugar por los estatutos de autonomía y por la legislación estatal que, junto con la Constitución, forman el denominado bloque de la constitucionalidad y, en segundo lugar, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, del tenor literal de la Constitución se desprende una diversidad de vías de acceso a la autonomía y una heterogeneidad inicial en la configuración del Estado de las autonomías, que después se ha ido uniformizando. Por lo tanto, la Constitución del 78 no define un modelo cerrado y acabado de Estado autonómico, sino que fija solo unos principios y unos procedimientos que permiten diferentes concreciones (un modelo abierto) en un proceso que difícilmente se puede cerrar en algún momento. Así, por ejemplo, en noviembre del 2017 se constituyó una comisión de estudio en el Congreso de los Diputados que, durante seis meses, tenía que debatir la modernización del Estado de las autonomías como preludio de una comisión constitucional para la reforma de la Constitución.

En el desarrollo del Estado de las autonomías, podemos diferenciar hasta ahora seis etapas:

a) De 1977 a 1983: antes de que se aprobara la Constitución española y en plena transición, ya se restableció la Generalitat de Cataluña de la Segunda República (después de una multitudinaria manifestación en Barcelona el 11 de septiembre de 1977 de reivindicación del Estatuto), y después también se restableció el Consejo General Vasco; posteriormente, las llamadas preautonomías se extendieron a prácticamente todo el territorio del Estado. Sin embargo, es importante destacar que a las preautonomías solo se les reconoció autonomía administrativa. A lo largo de más de un año, desde septiembre de 1977 hasta octubre de 1978, se fueron creando las preautonomías, que condicionaron notablemente el futuro despliegue constitucional, no solo como precedente de la generalización de las comunidades autónomas, sino porque se les atribuyó funciones importantes en el proceso autonómico, de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera (podían sustituir la iniciativa del proceso autonómico que el art. 143.2 CE atribuía a las diputaciones provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes). Así pues, en esta etapa se consolida la generalización, primero, de las preautonomías y, después, de las comunidades autónomas, y se define un primer mapa autonómico. Durante estos años, entran en vigor todos los estatutos de autonomía, diecisiete en total, que alcanzan todo el territorio del Estado español (menos las ciudades de Ceuta y Melilla). Excepto el País Vasco, Cataluña, Andalucía y Navarra, el resto accedieron a la autonomía por la vía general del art. 143 y, en algunos casos, con particularidades, como es el caso de Madrid, que siguió las previsiones del art. 144.a) CE. Encontramos un primer punto de inflexión ya muy pronto, en 1981, con el pacto autonómico entre la UCD y el PSOE, acordado después del golpe de Estado del 23-F, la adopción definitiva del *café para todos* y la frustrada armonización de la LOHAPA (Ley orgánica de armonización del proceso autonómico), puesto que la STC 76/1983, de 5 de agosto, declaró inconstitucional una parte muy importante de la ley. Aun así, las ideas de fondo de la Ley (uniformización e interpretación restrictiva de la autonomía apenas estrenada) se materializaron por otras vías jurídicas que el Tribunal Constitucional mayoritariamente avaló: ampliando el contenido material de las competencias exclusivas estatales, extendiendo el alcance funcional y material de

las competencias básicas y ensanchando el alcance de los títulos denominados *transversales* u *horizontales* del Estado, especialmente de los que recogen los artículos 149.1.1 y 149.1.13 CE. Este último, por ejemplo, ha permitido que el Estado pudiera actuar en casi todos los ámbitos materiales que ha considerado oportunos, sin que haya ningún criterio objetivo en el ordenamiento español capaz de limitar la expansión constante de este título competencial (Viver).

b) De 1983 a 1993: el PSOE ocupa el Gobierno central, sin necesidad de apoyo parlamentario de otros grupos. Es una etapa de desarrollo estatutario, con los correspondientes trasposos, pero con una gran conflictividad competencial, en la que el Tribunal Constitucional ejerce un importante papel de árbitro. Es una etapa en la cual el legislador estatal lleva a cabo una intensa actividad, condicionando la actuación autonómica, por ejemplo, cuando con mucha frecuencia en las competencias compartidas (en las que el Estado tenía que regular lo básico y las comunidades autónomas desarrollar estas bases) establece unas bases muy amplias que dejaban en la práctica muy poco margen de actuación a las autonomías, en una interpretación muy reduccionista de las competencias previstas en los estatutos. Esta etapa acaba con la firma de los segundos pactos autonómicos, en este caso entre el PSOE y el PP, en 1992. Estos pactos supusieron, primero, una ley orgánica de transferencia complementaria que permitía ampliar el techo competencial inicial a las comunidades autónomas que accedieron al autogobierno por la vía lenta (del artículo 143 de la CE) y, segundo, también diferentes reformas estatutarias que recogían esta facultad y se otorgaban más competencias. Se consagra así una tendencia homogeneizadora, que topará con el deseo de mantener un estatus singular en el caso de los gobiernos autonómicos de comunidades como Euskadi o Cataluña, que entienden que la igualación –aunque no tendría que ser necesariamente así– acabará suponiendo finalmente una rebaja de sus expectativas de autogobierno.

c) De 1993 al 2000, es una etapa en la que los gobiernos del Estado no disfrutaban de mayoría absoluta, primero el PSOE y después el PP, lo cual les obligará a buscar pactos, en especial con CiU, el PNB y el grupo canario. Se consagra el modelo 17+2 (Ceuta y Melilla tendrán en 1995 su Estatuto de autonomía como ciudades autónomas, sin potestad legislativa). Se empiezan a plantear nuevas reivindicaciones: mejoras en la financiación autonómica, la Administración única, nuevos trasposos de servicios todavía no resueltos, la reforma del Senado, etc. Por otro lado, aumenta la insatisfacción ante la autonomía política, en especial en el País Vasco y en Cataluña.

d) Del 2000 al 2004, el Gobierno del PP obtiene mayoría absoluta y se cierra ante las reivindicaciones autonómicas, en nombre del llamado *patriotismo constitucional*. En especial destaca la incomunicación con el Gobierno vasco, el cual presenta en el 2003 un proyecto de reforma estatutaria (el denominado Plan Ibarretxe) que es impugnado desde el primer momento de su tramitación por el Gobierno central.

e) Del 2004 al 2011, etapa de Gobierno socialista, con el apoyo de grupos de izquierdas y nacionalistas, marcada por un lado por el freno al Plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados por el voto conjunto principalmente del PSOE y el PP, en el 2005 (después de que el Tribunal Constitucional, por la Interlocutoria 135/2004, de 20 abril, permitiese continuar su tramitación). En esta etapa, se llevan a cabo reformas de los estatutos de autonomía de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, las islas Baleares, Aragón, Castilla-León y Extremadura, y también de la Ley orgánica de reintegración y mejora del régimen foral de Navarra. Y es una etapa que se cierra con las sentencias del 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña y con la reforma de la Constitución (verano del 2011), hecha sin el consenso de algunas fuerzas políticas, como CiU, y que supuso que algunos de sus representantes históricos (como Miquel Roca) afirmaran públicamente que consideraban que se había roto el consenso sobre el cual se elaboró la Constitución de 1978. La reforma del artículo 135 CE pone nuevos límites a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, puesto que vincula la actuación de todas las administraciones a principios de estabilidad presupuestaria y remite a su desarrollo ulterior en una ley orgánica.

f) Del 2011 al 2018, etapa que empieza con la victoria del PP por mayoría absoluta en las elecciones del 20 de noviembre del 2011 y con la formación de un Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Es la etapa de más confrontación política y se focaliza especialmente entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Cataluña. El apoyo a la independencia crece de manera muy importante en Cataluña, y no solo se constata en las encuestas y en las reiteradas manifestaciones multitudinarias de cada 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña) desde el 2012, sino también en las elecciones al Parlamento de Cataluña: en las elecciones del 27 de septiembre del 2015, los ciudadanos de Cataluña eligieron por primera vez en su historia un parlamento con una mayoría de miembros que se presentaron con un programa independentista. El 9 de noviembre de aquel mismo año, la primera resolución aprobada de la legislatura (1/XI) confirma la voluntad de aquella mayoría parlamentaria y «declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república». El 6 septiembre del 2017, el Parlamento de Cataluña aprueba la Ley del referéndum de autodeterminación y dos días después, la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana, que son suspendidas inmediatamente por el Tribunal Constitucional de manera cautelar. Aun así, el referéndum se lleva a cabo y participan más de dos millones doscientas mil personas (con un 90 % de votos a favor de la independencia), a pesar de la represión con la que la policía y la guardia civil intentaron impedirlo. El 10 de octubre del 2017, en una sesión en el Parlamento de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo una declaración de independencia, pero propuso al Parlamento que la dejara en suspenso, a la espera de una mediación internacional. El 27 de octubre del 2017, el Parlamento de Cataluña levantó de hecho aquella suspensión y aprobó la declaración que proclamaba la República Catalana, en aplicación de los resultados del referéndum de autodeterminación, con 70 votos a favor, 2 en

blanco, 10 en contra y la retirada de 53 diputados como protesta. En el mismo día, el Senado aprobó prácticamente todas las medidas que el Gobierno español le había propuesto, en una interpretación del artículo 155 de la Constitución española que, entre otras cosas, incluían el cese del Gobierno de Cataluña, la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Este conjunto de medidas significaba en la práctica la suspensión de la autonomía de Cataluña, en una interpretación del artículo 155 CE que fue considerada inconstitucional por una parte de la doctrina y que fue impugnada al Tribunal Constitucional mediante dos recursos de inconstitucionalidad, presentados, primero, por diputados del grupo parlamentario de Podemos y, posteriormente, por el Parlamento de Cataluña. En las nuevas elecciones (21 de diciembre del 2017), el conjunto de fuerzas independentistas volvieron a obtener mayoría absoluta en el Parlamento y eligieron a Quim Torra como presidente de la Generalitat, con un discurso de investidura en el que aseguró que se mantendría leal al programa del 1 de octubre y a la constitución de la República. Esta etapa se cierra con el cese de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno español, mediante la aprobación de una moción de censura en el Congreso de los Diputados que supuso la investidura automática del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, como nuevo presidente. Y empieza una nueva etapa todavía por definir y llena de incertidumbres.

En conclusión, el desarrollo del Estado autonómico ha ido evolucionando –no siempre de una manera lineal–, como consecuencia de diferentes coyunturas, pactos políticos y criterios jurisprudenciales que han contribuido a concretar un modelo entre las diferentes opciones que permitía un marco constitucional, por naturaleza, permanentemente abierto a cambios. En los primeros 30 años, el carácter abierto del sistema autonómico no significó más inestabilidad estructural de la que es habitual en cualquier Estado compuesto que quiere ir adaptándose a la realidad social. Este modelo, con algunos elementos que tienen ya una notable consolidación, ha satisfecho las expectativas iniciales de descentralización e, incluso, las novísimas aspiraciones de autogobierno que han surgido en algunas comunidades autónomas creadas a partir de 1981, pero ha tendido a administrativizar el carácter político de la autonomía y no ha resuelto –si tenemos que juzgar por los resultados electorales y varias encuestas coincidentes– la que fue en origen su razón fundamental de ser: la acomodación de las llamadas nacionalidades históricas a la unidad del Estado.

2.4. El modelo de justicia constitucional: un sistema jurisdiccional y concentrado en manos del Tribunal Constitucional

El sistema de justicia constitucional que adopta la Constitución española se **inscribe en el modelo europeo** desarrollado en países como Austria, Italia y Alemania a partir de las premisas del modelo kelseniano. Se trata, pues, de un **sistema jurisdiccional y concentrado** que presenta las características siguientes:

1) **El sujeto de control de la constitucionalidad de las normas con valor de ley es el Tribunal Constitucional**, un **órgano constitucional** (previsto y regulado en sus aspectos básicos por la Constitución) y **diseñado** como un **órgano de carácter jurisdiccional**, tanto por el procedimiento mediante el cual llega a tomar decisiones, como por el razonamiento mediante el que adopta las decisiones: sus argumentaciones tienen que estar inspiradas por la racionalidad jurídica, es decir, el parámetro desde el cual se legitima su razonamiento tiene que ser siempre una norma jurídica, y el criterio para fundamentar la decisión debe consistir en aplicar reglas de razonamiento jurídico. **Sin embargo**, pese a tratarse de un órgano de naturaleza jurisdiccional, **no forma parte del poder judicial**. **Ejerce con exclusividad sus competencias en todo el territorio del Estado**, está **previsto** por la Constitución **como un órgano independiente** de los otros órganos constitucionales y **sujeto solo a la Constitución y a la ley que lo regula**.

La Constitución dedica todo el título IX (arts. 159 a 165) a establecer las características principales del Tribunal Constitucional, y remite a una ley orgánica su desarrollo; esta ley se aprobó al poco de entrar en vigor la Constitución (LO 2/1979, de 3 de octubre), porque el legislador era consciente de la necesidad urgente de este órgano para el conjunto del sistema jurídico y político español, y ha sido reformada muchas veces (diez hasta el 2018).

De acuerdo con lo que prevé la Constitución, **el TC está integrado por 12 miembros, que tienen que ser juristas** (magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios o abogados) **de competencia reconocida y con más de quince años de experiencia profesional** (art. 159 CE); son nombrados por el rey (con un acto formal, debido), pero quienes los proponen (y, por lo tanto, deciden elegirlos) son los órganos siguientes: **el Congreso de los Diputados designa a cuatro (por mayoría de tres quintas partes)**, **el Senado (con idéntica mayoría) también a cuatro**, **el Gobierno, dos**, y **el Consejo General del Poder Judicial, también dos (y también por mayoría de tres quintas partes)**, pero no porque lo establezca la Constitución, sino porque lo determina la LOPJ). Los doce magistrados **son designados por un periodo de 9 años y renovados por terceras partes cada tres años**, sin que pueda haber una reelección inmediata. **Tienen las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial, pero**, a diferencia de estos, **la Constitución les permite pertenecer a partidos políticos como militantes** (art. 159.4), **aunque no ejercer funciones directivas** (y según subraya el Auto del TC 226/1988, de 16 de febrero, FJ3, «una posible afinidad ideológica no es



Sede del Tribunal Constitucional español, desde 1981, en la calle Domenico Scarlatti, núm. 6, de Madrid. El edificio, construido originariamente para otras finalidades, es obra de los arquitectos Antonio Bonet y Francisco G. Valdés. En otros países, como Alemania, la sede del TC no está en la capital del Estado.

en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que según su Ley orgánica este Tribunal tiene que decidir», posicionamiento ratificado por el ATC 180/2013, de 17 de septiembre, sobre su presidente, el magistrado Pérez de los Cobos, que había militado en el Partido Popular). **Los magistrados del TC eligen entre ellos a su presidente** (y así se quiere reforzar su autonomía), que tendrá un mandato de tres años (art. 160 CE) y puede ser reelegido solo una vez (art. 9.3 LOTC); asimismo, y en iguales condiciones, se elige al vicepresidente del TC (art. 9.4 LOTC).

En nuestro contexto europeo, las soluciones para elegir al presidente del tribunal van desde la elección por el mismo tribunal, de manera similar a la española, como sucede en Italia (art. 135 de su Constitución) y Portugal (art. 224), a la designación por el Parlamento, alternando el Bundestag y el Bundesrat, en el caso de Alemania (art. 94 de la Ley fundamental de Bonn), pasando por confiar el nombramiento al presidente de la República, como se hace en Francia (art. 56 de la Constitución francesa) y Austria (art. 147 de su texto fundamental).

2) El Tribunal Constitucional tiene el monopolio para poder declarar la inconstitucionalidad de las normas con valor de ley, como es propio de un **modelo concentrado**. Este control lo lleva a cabo **por dos vías: la vía directa, principalmente mediante el recurso de inconstitucionalidad**, que permite a órganos mayoritariamente políticos acudir al TC para que juzgue la constitucionalidad de una norma con valor de ley sin necesidad de que haya sido aplicada; y **la vía indirecta, la cuestión de inconstitucionalidad**, en la que un juez que tiene que aplicar una norma con valor de ley en el transcurso de un proceso judicial ordinario pide al TC que se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta norma. Así, tanto en una vía como en la otra, la capacidad para activar un proceso de constitucionalidad de las normas con valor de ley está reservada a unos pocos órganos (**hay una legitimación restringida para instar estos procedimientos**). En el caso del recurso de inconstitucionalidad, solo lo pueden interponer el presidente del Gobierno del Estado, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores y los gobiernos y parlamentos autonómicos. En cambio, puede interponer la cuestión de inconstitucionalidad cualquier órgano judicial (que considere que una norma con valor de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el veredicto, puede ser contraria a la Constitución); la cuestión la plantea un órgano judicial de oficio (por iniciativa propia) o a instancia de parte (las partes de un juicio pueden pedir al juez o tribunal que presente una cuestión de inconstitucionalidad), pero la decisión de presentarla o no corresponde solo al órgano judicial (art. 35 LOTC). Por lo tanto, en el sistema constitucional español, el ciudadano no tiene ningún mecanismo directo para poner en marcha un procedimiento de control de constitucionalidad (el TC ha insistido en que el ciudadano no tiene el derecho de exigir al juez que plantee la cuestión de inconstitucionalidad).

Antes de adoptar la resolución definitiva y no recurrible (art. 35.2 LOTC) mediante auto, el órgano judicial tiene que escuchar a las partes y al ministerio fiscal para que aleguen lo que quieran sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Esta audiencia previa es obligatoria. La omisión de este trámite es causa de inadmisión de la cuestión (ATC 145/1993).

Recurso y cuestión también se diferencian en el plazo para interponerlos: el recurso de inconstitucionalidad tiene un plazo limitado (un plazo general de 3 meses, aunque hay algunas excepciones), mientras que no hay plazo para la cuestión, es decir, se puede interponer en cualquier momento durante la vigencia de la norma con valor de ley. Si solo hubiera el recurso de inconstitucionalidad, una vez pasado el plazo para impugnar una ley, esta se podría aplicar pese a ser manifiestamente inconstitucional; la cuestión de inconstitucionalidad permite que la posibilidad de control de constitucionalidad esté siempre abierta, y se ha convertido en el procedimiento más utilizado para este tipo de control en el Estado español.

Por lo tanto, los tribunales ordinarios tienen la competencia de comprobar la constitucionalidad de las normas con valor de ley antes de aplicarlas, pero si consideran que hay alguna inconstitucionalidad, no pueden declarar su nulidad ni inaplicarlas al caso concreto porque **la competencia de rechazo corresponde en exclusiva al TC. Con una excepción: las normas con valor de ley preconstitucionales** (las que entraron en vigor antes que la Constitución del 78 y todavía continúan vigentes) **tienen que ser inaplicadas por los órganos judiciales ordinarios si, y solo si, son inconstitucionales**, en virtud de la disposición derogatoria tercera de la Constitución; estas normas si, además de ser anteriores, son contrarias a la Constitución, no pueden ser aplicadas por los jueces (porque ya no son vigentes), **porque se entiende que la Constitución ya las ha derogado**, aunque no hayan sido explícitamente derogadas por ninguna norma posterior. Aun así, el TC ha admitido que, en estos casos, los jueces también pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad, y entonces el pronunciamiento del TC tendrá efectos generales (*erga omnes*). Por lo tanto, para ser precisos, el Tribunal Constitucional tiene el monopolio para poder declarar la inconstitucionalidad de las normas con valor de ley *posconstitucionales*. **En cambio, los órganos judiciales pueden inaplicar las normas con valor de ley preconstitucionales, y ostentan las competencias de comprobación y de rechazo respecto a las normas con rango inferior a la ley** (inaplicación de reglamentos y declaración de nulidad, tal y como se ha explicado en el módulo 2).

Finalmente, también hay que señalar que, como regla general, **la admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspende la vigencia ni la aplicación de la norma impugnada** (art. 163 CE y art. 30 LOTC). Sin embargo, **hay una excepción que ha resultado de gran aplicación e importancia política**: el TC tendrá que suspender la vigencia de la norma impugnada en el caso de que el presidente del Gobierno del Estado se ampare en lo que dispone **el artículo 161.2 de la Constitución**. Este artículo establece para el Estado un privilegio del que no disfrutaban las comunidades autónomas; y esta impugnación, alegando el art. 161.2 CE, puede referirse tanto a leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley de las comunidades autónomas (art. 30 LOTC) como a las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas (art. 76 LOTC). La formulación de la impugnación comunicada por el Tribu-

nal producirá la suspensión de la disposición o resolución objeto de recurso hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia (art. 76 LOTC y art. 161.2 CE).

3) El control de constitucionalidad de las normas con valor de ley **tiene un carácter abstracto y se lleva a cabo generalmente *a posteriori***. Así, **tanto por la vía directa** (recurso de inconstitucionalidad) **como por la vía indirecta** (cuestión de inconstitucionalidad), **el TC hace un juicio en abstracto de la compatibilidad entre una norma legal y la Constitución**. El recurso es un procedimiento directo (los legitimados para interponerlo lo hacen sin ningún condicionante ante el mismo TC, porque quieren hacer valer la supremacía de la Constitución) y abstracto (se impugnan normas en sí mismas, no contextualizadas en ningún caso concreto); en cambio, la cuestión de inconstitucionalidad es un procedimiento que se caracteriza por ser indirecto (la impugnación surge incidentalmente en un procedimiento ordinario en el que se juzga un caso cuyo veredicto depende de si una determinada norma es o no constitucional) y concreto, solo en cuanto al surgimiento (en la fase previa a la interposición está vinculado a un caso concreto), porque una vez interpuesta la cuestión ante el TC, la norma se desvincula del caso que lleva el juez ordinario y a partir de aquel momento, también se analiza en abstracto.

Para hacer el juicio de constitucionalidad, **el parámetro que utiliza el TC no es exclusivamente la Constitución, sino un conjunto de normas más amplio**. Así, a la hora de interpretar los derechos fundamentales, el TC tiene que usar los tratados y convenios internacionales (art. 10.2 CE), y en materia de reparto de competencias, hay que tener en cuenta no solo los preceptos constitucionales, sino también las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para delimitar competencias del Estado y las comunidades autónomas, o para regular o armonizar el ejercicio de sus competencias (que es **el conjunto de normas que se conoce como «bloque de la constitucionalidad»**). Por otro lado, **el TC está facultado para fundamentar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya sido o no invocado** en el curso del proceso (art. 39.2 LOTC); en estos casos, la desviación está basada en el principio *iura novit curia* (el tribunal conoce la ley), y no hay alteración del principio de congruencia (que fija la necesaria correlación entre las pretensiones de los recurrentes y el contenido dispositivo de la sentencia). De acuerdo con el art. 39.1 LOTC, sí puede haber una cierta modulación del principio de congruencia, porque el TC puede extender el pronunciamiento de inconstitucionalidad a normas no impugnadas, siempre que se den tres requisitos (STC 11/1981): que la sentencia sea estimatoria de los preceptos impugnados o de alguno de ellos; que haya una relación de conexión o congruencia entre los preceptos declarados inconstitucionales y los otros a los cuales la inconstitucionalidad se extienda o se propague, y que estos últimos pertenezcan o queden comprendidos dentro de la misma ley, disposición normativa o acto con fuerza de ley.

De acuerdo con lo que establece el art. 164 CE, **las sentencias del Tribunal Constitucional se tienen que publicar en el *Boletín Oficial del Estado* (BOE)** con los votos particulares, si los hubiera. **Tienen el valor de cosa juzgada** a partir del día siguiente de haber sido publicadas, **y no es posible ningún recurso en contra**. Aun así, las sentencias sobre una cuestión de inconstitucionalidad tienen eficacia a partir de la comunicación que hace el TC al juez o tribunal *a quo* (art. 38.3 LOTC). Las sentencias declarativas de inconstitucionalidad tienen **plenos efectos ante todos** (*erga omnes*). Y salvo que en el veredicto se disponga otra cosa, **subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad**; de hecho, las leyes no son impugnadas habitualmente en su totalidad y, por lo tanto, en la sentencia, el TC especificará cuál de los preceptos impugnados son declarados inconstitucionales.

Tanto en el recurso como en la cuestión de inconstitucionalidad, **la sentencia puede ser de dos tipos**: sentencia **desestimatoria** (que es la que declara la constitucionalidad del precepto examinado) o **estimatoria** (se declara la inconstitucionalidad del precepto examinado). Como regla general, las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y también en conflictos en defensa de la autonomía local impiden cualquier planteamiento ulterior por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional (art. 38.2 LOTC); aun así, si sobre un determinado precepto se desestima un recurso de inconstitucionalidad, sí se puede interponer una cuestión de inconstitucionalidad; y, asimismo, si sobre un determinado precepto se desestima una cuestión de inconstitucionalidad, se le puede interponer otra. En cambio, **como regla general, los efectos de las sentencias estimatorias son la anulación del precepto declarado inconstitucional**. Así lo establece el art. 39.1 de la LOTC, que vincula a la declaración de inconstitucionalidad exclusivamente la consecuencia jurídica de la nulidad. Por lo tanto, los efectos de estas sentencias son declarativos y de carácter retroactivo (son efectos *ex tunc*: los efectos se despliegan tomando como referencia el día de la publicación de la norma inconstitucional y no desde el día que se publica la sentencia). Sin embargo, a pesar de que el art. 39.1 LOTC establece que cuando una sentencia del TC declare la inconstitucionalidad, **declarará igualmente la nulidad, a veces el TC ha adoptado las llamadas sentencias constitucionales «atípicas», entre las cuales están las que declaran la inconstitucionalidad, pero no la nulidad** de los preceptos impugnados, con la voluntad de proteger la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y procurar que la restauración de la normalidad constitucional rota por la ley inconstitucional se produzca afectando lo mínimo posible a la seguridad del tráfico jurídico; es el caso de la STC 45/1989, de 20 de febrero, sobre la ley del IRPF del 1978, en la que el TC declara la inconstitucionalidad, pero no la nulidad, de algunos de sus preceptos, once años después de entrar en vigor (1989).

En este caso, es fácil imaginar el volumen de reclamaciones y la cantidad de dinero para devolver que hubieran podido llevar a Hacienda a una situación caótica, durante años, y, por lo tanto, es fácil también ver el interés del TC en hacer esta excepción. Otros ejemplos en los que el TC no ha aplicado el criterio de la nulidad de las normas inconstitucionales con todas sus consecuencias, porque otros principios y valores constitucionales

les hacían desaconsejable o imposible su aplicación: SSTC 13/1992, 195/1998, 273/2005 o 236/2007 (inconstitucionalidad sin nulidad). Alguna otra vez, el TC ha declarado un precepto inconstitucional y nulo pero ha mantenido su vigencia de manera transitoria (STC 151/2017, de 21 de diciembre).

Otro tipo de sentencia atípica son las sentencias interpretativas, que declaran un determinado precepto como constitucional o inconstitucional «en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera adecuado a la Constitución» (STC5/1981). Así, en las sentencias interpretativas, el TC declara qué interpretación de la ley es constitucional o qué interpretación resulta inconstitucional y, por lo tanto, **el TC no se limita tan solo a su función de «legislador negativo»** (declarar qué precepto no es constitucional y expulsarlo del ordenamiento jurídico), tal y como era la concepción de Kelsen, **sino que introduce nuevas normas en el ordenamiento y, por lo tanto, va más allá de la función que le encomienda la Constitución para convertirse en «legislador positivo»**.

También hay que señalar que la declaración de inconstitucionalidad no se extiende a las sentencias anteriores con fuerza de cosa enjuiciada en la que se hayan aplicado los preceptos declarados inconstitucionales, con una excepción: sí se pueden revisar procesos finitos en los casos penales o contenciosos administrativos referentes a un procedimiento sancionador en el que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción, o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad (art. 40.1 LOTC).

Por otro lado, **el control de constitucionalidad que lleva a cabo el Tribunal Constitucional es generalmente un control *a posteriori***, es decir, de normas aprobadas y publicadas que son vigentes²³. **Sin embargo, hay dos excepciones:** pueden ser objeto de un control previo los proyectos de Estatuto de autonomía y sus propuestas de reforma (art. 79 LOTC), así como los tratados internacionales (arts. 95 CE y 78 LOTC); en este último caso, el pronunciamiento del TC no es propiamente una sentencia, sino una «declaración», que tiene carácter vinculante y produce frente a todos los efectos de la cosa juzgada (Declaración del TC, de 1 de julio de 1992).

⁽²³⁾ En diferencia con lo que está establecido en el Estado español, en otros países, como Francia, el control preventivo de constitucionalidad no es la excepción, sino la regla (ved el módulo 1).

En el recurso previo de los tratados internacionales, nos encontramos ante un supuesto de consulta vinculante en el que, a requerimiento del Gobierno o de las cámaras parlamentarias, el TC formula una declaración en la que decide sobre la compatibilidad del tratado en cuestión con la norma constitucional. Hasta ahora, este mecanismo solo se ha usado dos veces: dio lugar a la Declaración del Tribunal del 1 de julio de 1992 sobre el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht), después de la cual se hizo la primera reforma de la Constitución (art. 13.2 CE), y a la Declaración del Tribunal Constitucional del 13 de diciembre del 2004, sobre la constitucionalidad del Tratado por el cual se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre del 2004.

El recurso previo respecto a los proyectos de Estatuto de autonomía y sus proyectos de reforma, establecido por la LO 12/2015, no es una novedad porque ya había sido previsto en la LOTC desde 1979 hasta 1985, momento en el que fue suprimido por la LO4/1985, cuando ya casi todos los estatutos de autonomía estaban en vigor.

4) Las funciones del Tribunal Constitucional no se limitan al control de la constitucionalidad de las leyes, sino que también tiene encomendada la garantía de la división de poderes (horizontal y vertical) y la tutela de los derechos fundamentales. Estas tres funciones, en el fondo, son concreciones de la tarea fundamental de garantizar la supremacía de la Constitución (9.1 CE). El TC las lleva a cabo principalmente mediante los procedimientos siguientes:

a) El control de constitucionalidad de las normas con valor de ley, sobre todo mediante el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad, pero también con el control previo de los tratados internacionales y los conflictos en defensa de la autonomía local.

b) La garantía de la división de poderes:

- La garantía de la **división vertical** de poderes, en relación con las comunidades autónomas, **depende del objeto**: las normas con valor de ley ya hemos visto que las controla principalmente mediante el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad, y **las normas infralegales, mediante los conflictos de competencias** entre el Estado y las comunidades autónomas, o entre estas; también tiene que resolver las impugnaciones del Gobierno del Estado de disposiciones sin rango de ley y resoluciones de las comunidades autónomas (art. 161.2 CE); en relación con los entes locales, los conflictos en defensa de la autonomía local también le permiten llevar a cabo la función de garante de la división vertical de poderes que establece la Constitución respecto a las lesiones que provengan de leyes y normas con rango de ley del Estado o de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es un instrumento que cumple a la vez una doble función, de garantía de la división vertical de poderes y también de control de constitucionalidad de normas con rango de ley. Se trata de un mecanismo no previsto en la Constitución, que fue introducido en la LOTC mediante la LO 7/1999, de 21 de abril.

El conflicto en defensa de la autonomía local es un conflicto atípico. A diferencia de los conflictos de competencias, su objeto son las normas con rango de ley del Estado y de las comunidades autónomas, lo cual hace pensar en un recurso de inconstitucionalidad encubierto; parece que el legislador haya querido encubrir la verdadera naturaleza de este proceso ante el *numerus clausus* que establece la Constitución de sujetos legitimados para la interposición del recurso de inconstitucionalidad. Aun así, la regulación de este proceso parece más encaminada a disuadir de su utilización (especialmente por la dificultad de configurar la legitimación activa del procedimiento) que a proteger un derecho, el de la autonomía local, que la Carta Europea de Autonomía Local obligaba a tutelar jurisdiccionalmente, aunque no hacía falta que fuera en un proceso constitucional. Ved, en este sentido, F. Balaguer (2010). *Manual de Derecho Constitucional* (págs. 300-301). Madrid: Tecnos. En cualquier caso, hasta ahora ha sido un procedimiento muy poco utilizado: hasta el 2017, solo se habían dictado doce sentencias y veintiocho autos.

- En cuanto a la garantía de la **división horizontal**, el procedimiento adecuado es el **conflicto entre órganos constitucionales del Estado**. Es una atribución del TC que la Constitución no prevé, sino que se trata de una ampliación material que lleva a cabo la LOTC (arts. 59 y 73 a 75). El art.

59 de la LOTC enumera los órganos que están legitimados de manera activa (mediante acuerdo de su órgano plenario) y pasiva: el Gobierno del Estado, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial; pero la LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, extendió a este órgano constitucional la legitimación para interponer el conflicto entre órganos constitucionales (art. 8).

c) **La protección de los derechos fundamentales** la lleva a cabo el TC, fundamentalmente, **mediante el recurso de amparo**. El objeto del recurso son los actos, omisiones o disposiciones sin rango de ley de los poderes públicos que vulneren los derechos y libertades recogidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 CE. No es posible impugnar una ley o norma con rango de ley mediante el recurso de amparo, pero sí sus actos de aplicación. Los causantes de la lesión de los derechos fundamentales tienen que ser poderes públicos (no personas particulares), a pesar de que se puede reclamar contra la resolución judicial que no ha restablecido el derecho vulnerado en un litigio entre particulares. La lesión que se quiere reparar tiene que ser real, concreta, efectiva y cierta; el TC ha rechazado entrar a conocer situaciones meramente cautelares, temidas, potenciales o futuras (STC 27/1997). El recurso de amparo puede interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el ministerio fiscal (art. 162.b CE).

Todos los tribunales constitucionales de nuestro entorno europeo tienen atribuida la función de control de la constitucionalidad de las leyes, pero menos frecuente es su faceta de protector último de los derechos fundamentales mediante un recurso específico similar al de amparo en el Estado español, que no existe, por ejemplo, en Italia ni en Francia, pero sí en Alemania. En los estados compuestos, es habitual que a estos tribunales se les atribuyan las competencias para dirimir los conflictos entre las diferentes instancias de gobierno (el Estado central respecto a regiones, autonomías o estados federados, y de estos entes territoriales entre sí), como, por ejemplo, en Italia o Alemania. Además, algunos tribunales tienen atribuido el llamado juicio político contra las altas autoridades del Estado (Italia) o la acusación contra los jueces (Alemania), y se dan casos en los que también se les conceden competencias para controlar la regularidad de procesos electorales (Francia). El Tribunal Constitucional español, junto con el alemán, es uno de los que más funciones tiene encomendadas: casi todas las mencionadas, salvo la acusación contra los jueces y el juicio político (la responsabilidad de los miembros del Gobierno es exigible ante el Tribunal Supremo, de acuerdo con el art. 102 CE).

Teniendo en cuenta todas las funciones que ejerce el TC y la importancia de estas funciones, hay que coincidir con García de Enterría cuando, muy pronto, ya señaló que el tema del Tribunal Constitucional era posiblemente el tema central de la Constitución española:

«Me atrevo a decir [...] que es aquel en el que esta Constitución se juega sus posibilidades y su futuro.»

Lectura complementaria

E. García de Enterría (1981). «La posibilidad jurídica del Tribunal Constitucional». En: *Revista Española de Derecho Constitucional* (vol. 1, núm. 1, págs. 35 y siguientes). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Resumen

En este tercer y último módulo, hemos estudiado las cuatro decisiones más importantes que ha de tomar cualquier constituyente (sobre la forma de Estado, forma de gobierno, forma de organización territorial y el modelo de justicia constitucional), eligiendo sobre un abanico limitado de opciones.

Las diferentes formas de Estado dependen del tipo de relaciones que mantiene el aparato de Gobierno con los ciudadanos. Estas relaciones dependen fundamentalmente de tres variables: la sumisión o no de los poderes del Estado al derecho, la participación, o no, de los ciudadanos en el ejercicio del poder público estatal, y la intervención o no del Estado en la vida socioeconómica. La forma de Estado depende, en primer lugar, de si hay una limitación del poder del Estado ejercida por el derecho, y de si este derecho le impone la obligación de respetar un conjunto de derechos y libertades fundamentales. Si el poder del Estado está limitado por el derecho (y por un derecho con este contenido), nos encontraremos ante un Estado de derecho; si no hay esta limitación jurídica, el Estado será totalitario o autoritario. Hemos visto que el Estado de derecho tiene una dimensión valorativa o material: no todo Estado *con* derecho es un Estado *de* derecho; solo merece este nombre el Estado que responde a tres presupuestos, que hemos analizado con detenimiento: la proclamación y la garantía de unos derechos y libertades que pertenecen a todas las personas por igual; la división de los poderes como principio de organización del Estado, y la sujeción de la actuación de los diferentes órganos del Estado al derecho.

La segunda de las variables que permiten clasificar las diferentes formas de Estado hace referencia a si los ciudadanos pueden participar libremente en el ejercicio y el control del poder público estatal. Desde esta perspectiva, podemos distinguir entre estados autocráticos y estados democráticos. Y hemos definido estos últimos como los estados en los cuales los ciudadanos participan (o como mínimo, pueden participar) en condiciones de igualdad y en un contexto de pluralismo político en la gestión y control de los poderes públicos, porque la soberanía corresponde a todos los ciudadanos. Hemos visto que el Estado democrático incorpora los presupuestos del Estado de derecho y hemos analizado los tres elementos nuevos que añade y que lo caracterizan: la soberanía popular (que implica el sufragio universal), el reconocimiento y la garantía del pluralismo de la sociedad, y muy especialmente del pluralismo político; y la participación política, ejercida directamente mediante mecanismos como el referéndum o la iniciativa legislativa popular, o bien por medio de la elección libre y periódica de representantes.

La intervención o no del Estado en la vida socioeconómica es el tercer factor del que depende la forma de Estado; partiendo de este criterio, podemos diferenciar los modelos de Estado abstencionista propios del siglo XIX y los esta-

dos intervencionistas, que en la actualidad son casi todos, aunque no en el mismo grado o intensidad, ni tampoco con los mismos objetivos. El Estado social es el tipo de Estado que interviene en el orden económico con el fin de asegurar determinados bienes y prestaciones que garanticen a los ciudadanos las condiciones económicas y sociales suficientes para hacer reales y efectivas la libertad y la igualdad. En el Estado social, la igualdad no puede ser solo una igualdad formal (a todo el mundo el mismo trato), sino que tiene que ser también una igualdad material: real, efectiva, y por lo tanto que implica tratar desigualmente a los que son desiguales, ayudando a quienes menos tienen, con el objetivo de la igualdad de oportunidades.

Cuando se dan las tres calificaciones (Estado de derecho, democrático y social) en una misma forma de Estado, como, por ejemplo, en el art. 1.1 de la Constitución española, la fórmula resultante no constituye solo una simple agregación o yuxtaposición de los tres elementos, sino que origina una nueva forma de Estado en la que estos tres componentes (social, democrático, de derecho) están vinculados entre ellos por relaciones directas e indirectas, de modo que el conjunto de la fórmula tiene un alcance normativo diferente de la simple suma de sus elementos integrantes.

El segundo tema que hemos tratado es la forma de gobierno, que es determinada por las atribuciones fijadas por los diferentes órganos superiores del aparato estatal y por sus relaciones (básicamente entre el parlamento y el Gobierno), así como por el sistema de partidos y la configuración de mayorías y minorías. Hemos apuntado las características principales de las tres formas de gobierno principales que se dan dentro del Estado democrático: el sistema parlamentario, el presidencial y el mixto o semipresidencial.

Hemos visto que la forma presidencial de gobierno se basa teóricamente en una separación rígida de poderes, y que son tres sus características más relevantes:

- hay elecciones separadas para la presidencia de la República y para el parlamento (legitimidad dual);
- no existen los elementos de colaboración entre poderes propios del sistema parlamentario: el presidente no necesita la confianza del parlamento ni para ser elegido ni para mantenerse; el parlamento no puede obligar a dimitir al presidente, y este tampoco puede disolverlo de manera anticipada, y
- el presidente de la República reúne las funciones de jefe de Estado y de jefe de Gobierno (ejecutivo monista), de tal manera que el poder ejecutivo corresponde personalmente al presidente, que lo ejerce asesorado por secretarios y colaboradores, pero no hay un consejo de ministros como órgano

colegiado y con responsabilidad solidaria (que es una de las características de la forma parlamentaria).

En cambio, hemos visto que la forma de gobierno parlamentaria parte de una concreción del principio de división de poderes que se basa en la colaboración entre el Gobierno y el parlamento, y se caracteriza por la necesidad de una permanente relación de confianza entre estos dos órganos, de tal modo que el ejecutivo deriva del poder legislativo y es responsable ante él. Así, hemos sintetizado las cuatro grandes características que lo definen:

- El Gobierno deriva del parlamento y ha de tener en todo momento su confianza, que se expresa generalmente mediante el voto de investidura inicial del Gobierno o de quien lo preside, y continúa mediante el apoyo parlamentario a la acción política del Gobierno a lo largo de la legislatura; esto supone que la mayoría parlamentaria y el Gobierno actúan de mutuo acuerdo para tomar decisiones políticas (una parte importante de las cuales se concretarán en leyes que serán mayoritariamente de iniciativa del Gobierno).
- El Gobierno es políticamente responsable de sus actuaciones ante el parlamento, que tiene encomendada una función de control político sobre el Gobierno. Si la mayoría parlamentaria rompe la confianza en el Gobierno, este está obligado a dimitir; los instrumentos para exigir esta responsabilidad política son la aprobación de una moción de censura (voto parlamentario de desconfianza) y la denegación de una cuestión de confianza (el parlamento vota en contra de la solicitud de confianza presentada por el Gobierno).
- Además de estas dos características fundamentales (el Gobierno deriva del parlamento y es responsable ante el mismo), también suele estar presente en los sistemas parlamentarios la facultad del Gobierno o de su presidente o presidenta de disolver el parlamento antes de que se acabe la legislatura.
- También se acostumbra a diferenciar la figura del jefe del Estado y la del presidente o presidenta del Gobierno, que no coinciden en la misma persona. Así, hay una separación orgánica entre el jefe del Estado (que es una figura básicamente simbólica y representativa) y el presidente del Gobierno (o primer ministro), con poder ejecutivo y de dirección política. El Gobierno se estructura como un órgano colegiado que responde políticamente de manera solidaria ante el parlamento. Teniendo en cuenta la figura del jefe del Estado, se pueden distinguir dos variantes de la forma parlamentaria de gobierno: la monarquía parlamentaria (en la cual el jefe del Estado es un rey o reina, con un mandato vitalicio y hereditario, e irresponsable políticamente de sus pocas atribuciones) y la República parlamentaria (con un jefe del Estado elegido –por un parlamento generalmente ampliado–, con un mandato limitado y responsable de sus también pocas atribuciones). Tanto en una variante como en la otra, el jefe del Es-

tado se ha convertido en un elemento secundario del sistema parlamentario, que ya no forma parte del ejecutivo, y con unas funciones básicamente representativas. En una monarquía parlamentaria, el presidente o presidenta del Gobierno (u otro de sus miembros) asume la responsabilidad de los actos del rey, mediante la contrafirma.

El sistema mixto o semipresidencial combina algunos elementos típicos del sistema parlamentario con otros que lo acercan al presidencial. Las condiciones necesarias para poder considerar un sistema político como semipresidencial son fundamentalmente cinco:

- existencia de un poder ejecutivo dual (presidente o presidenta de la República y Gobierno);
- elección del presidente de la República por medio de sufragio universal directo; hay elecciones separadas para el presidente de la República (elegido directamente por los ciudadanos) y para el parlamento y, por lo tanto, es posible que la mayoría presidencial y la parlamentaria no coincidan;
- el presidente de la República tiene atribuidos amplios poderes constitucionales;
- el presidente de la República nombra al primer ministro y puede presidir el consejo de ministros, y
- el Gobierno es responsable ante el parlamento y necesita, por lo tanto, la doble confianza del presidente de la República y del parlamento.

El tercer tema que hemos estudiado es la forma de organización territorial, y hemos visto que históricamente hubo dos modelos: el Estado unitario y el Estado federal, que surgieron a finales del siglo XVIII en Francia y en Estados Unidos, respectivamente. El Estado unitario se basa en tres principios: la unidad (un solo Estado), la uniformidad (la misma ley para todo el territorio) y la centralización (la dirección política y la decisión administrativa se ejercen desde la capital del Estado). En cambio, el Estado federal continúa siendo una unidad pero, en contraposición al Estado unitario, se basa en la pluralidad (de centros de poder), la diversidad (de normas y orientaciones políticas) y la descentralización o no centralización (distribución territorial de la capacidad de decisión). El esquema tradicional, tanto del Estado federal como del Estado unitario, ha sufrido una importante evolución durante estos dos últimos siglos, y para poder encajar todos los tipos de organización territorial que encontramos hoy día en los diferentes estados y explicar mejor la evolución de los dos modelos históricos (unitario y federal), actualmente una parte de la doctrina ha propuesto una nueva categoría, el Estado compuesto, que incluiría a todos los estados que reconocen varios centros de poder político (el Estado federal, el autonómico y el regional). Por lo tanto, actualmente podemos considerar que hay dos grandes modelos de organización territorial: el Estado

unitario, en el que se parte de un criterio de organización unitaria en la cual solo se reconoce un único centro de poder político, y el Estado compuesto, que puede ser federal, autonómico o regional, pero que parte de un criterio de organización pluralista en el que se establecen varios centros de poder político.

El cuarto tema que hemos estudiado es el de la justicia constitucional, porque, junto con las decisiones fundamentales sobre la forma de Estado, forma de gobierno y organización territorial, cualquier constituyente que quiera hacer una constitución como norma suprema y que, por lo tanto, adopte un concepto de constitución racional-normativo, prácticamente está obligado a establecer uno u otro sistema de justicia constitucional. Porque la justicia constitucional quiere asegurar el respeto a la constitución y, por lo tanto, garantizar la aplicación real de todas las decisiones del constituyente. Y en consecuencia, hemos destacado la importancia de la función de control de constitucionalidad de la ley y también de todos los procesos de defensa de la constitución (como por ejemplo, los conflictos entre entes territoriales o entre órganos constitucionales, o la protección de los derechos fundamentales), porque son la última garantía del cumplimiento efectivo de la constitución y, por lo tanto, garantía del Estado de derecho y de la democracia; pero por otro lado, también hemos señalado los peligros de un ejercicio ilegítimo de estas funciones. Así, tanto si el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes es un órgano político, un tribunal constitucional o, en última instancia, un tribunal supremo (en el sistema de control difuso), este órgano no tan solo es el supremo intérprete de la constitución, sino que también es el órgano supremo de interpretación de la ley, en conformidad con la constitución. El peligro, pues, es doble: puede incurrir en la ilegitimidad de ocupar el papel del poder constituyente, porque encuentre un significado en los preceptos constitucionales no justificado en los métodos de interpretación jurídica, y también puede incurrir en la ilegitimidad de ejercer la función de legislador y, por lo tanto, invadir la función reservada constitucionalmente al Poder Legislativo, al interpretar la ley no en conformidad con la constitución, sino de acuerdo con parámetros que no sean los constitucionales. También hemos apuntado varios mecanismos para intentar evitar o minimizar estos peligros, pero remarcando que el grado de eficacia en la búsqueda de independencia, imparcialidad y calificación técnicas no depende solo de cómo se configuren jurídicamente, sino sobre todo de la cultura institucional y política de cada país, que determina que un mismo requisito cumpla o no la función para la cual ha sido pensado. Y hemos subrayado también que del correcto funcionamiento de la justicia constitucional depende no solo el prestigio, sino, en último término, la calidad democrática del sistema jurídico.

Finalmente, también hemos analizado las cuatro opciones elegidas por el constituyente español de 1978 en relación con estas grandes decisiones. En primer lugar, la forma de Estado como Estado social y democrático de derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución española de 1978, y que proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En segundo lugar, la forma de gobierno, con-

cretamente la monarquía parlamentaria (la variante monárquica del sistema parlamentario), que nos ayuda a comprender las diferentes dinámicas de relación que se pueden suscitar entre los órganos constitucionales del Estado. En tercer lugar, como organización territorial del Estado, el Estado de las autonomías, vertebrado en un largo proceso a partir de los principios de unidad, solidaridad, autonomía y el principio dispositivo. La cuarta opción, en relación con el modelo de justicia constitucional, es un modelo jurisdiccional concentrado que configura el Tribunal Constitucional español como garantía de la supremacía normativa de la Constitución y que, además del control de constitucionalidad de las normas con valor de ley, tiene encomendadas otras dos funciones muy importantes: la garantía de la división de poderes (horizontal y vertical) y la tutela de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional deviene, así, un órgano clave desde el punto de vista de las garantías del Estado de derecho.

Actividades

1. En un Estado democrático, ¿qué es lo que hace que las minorías acepten la legitimidad de la decisión de la mayoría? ¿La mayoría siempre tiene razón? ¿Siempre aciertan más diez que uno solo?
2. ¿Puede haber un Estado democrático que no sea un Estado de derecho? ¿Por qué? ¿Y un Estado de derecho que no sea democrático?
3. Valorad si se podría considerar democrático un sistema político actual que reconociese un voto doble a los ciudadanos que hubieran acreditado (mediante algún tipo de prueba objetiva) un interés por la política y un conocimiento de los asuntos públicos.
4. Buscad argumentos a favor y en contra del voto obligatorio.
5. En virtud de la Disposición derogatoria tercera de la Constitución española, ¿todas las normas anteriores a la Constitución de 1978 quedaron derogadas? ¿Por qué?
6. ¿Es posible diferenciar jurídicamente al tráfuga que actúa por convicciones políticas del que lo hace por intereses personales? Si se pudiera diferenciar, ¿de qué manera se podría actuar contra el tráfuga que actúa por intereses personales, respetando la prohibición del mandato imperativo que establece la Constitución española?
7. Explicad las principales diferencias entre el sistema presidencial y el parlamentario, y señalad algún elemento en común.
8. ¿Qué características comparte la forma de gobierno semipresidencial con el sistema parlamentario, y cuáles con el sistema presidencial?
9. Indicad qué límites fija la Constitución española para una fuerza política que tuviera mayoría en las Cortes Generales y quisiera aplicar un programa de gobierno comunista. Y haced el mismo ejercicio, pero respecto a un programa radicalmente neoliberal.
10. ¿Ha previsto el ordenamiento jurídico español algún mecanismo para juzgar penalmente al jefe del Estado? ¿Y para juzgar a un rey que ha abdicado?
11. ¿Qué argumentos permiten considerar el Estado autonómico como un Estado compuesto?
12. ¿Qué mecanismos jurídicos hay previstos en el Estado español si se considera que la actuación del TC ha vulnerado la Constitución o la LOTC?

Ejercicios de autoevaluación

1. El Estado que no acepta limitaciones a su poder, invade todos los ámbitos de la vida personal y social y le impone sus directrices, actuando con violencia contra los ciudadanos que se oponen a las mismas, es un Estado...
 - a) liberal predemocrático.
 - b) autoritario.
 - c) totalitario.
 - d) fallido.
2. En los estados democráticos actuales, el derecho de voto...
 - a) puede ser restringido a aquellos que no tengan un nivel elevado de estudios.
 - b) es siempre reconocido a todo el mundo, ciudadanos y extranjeros.
 - c) puede ser también un deber.
 - d) no puede ser secreto, porque solo pueden criticar a los representantes elegidos aquellos que los han votado.
3. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español...
 - a) la ley tiene que tratar a cada ciudadano de una manera individualizada.
 - b) no es posible que la ley prevea diferentes tratos entre los ciudadanos españoles, pero sí entre españoles y extranjeros.
 - c) siempre que el legislador lo considere oportuno, puede establecer diferentes tratos entre ciudadanos españoles.

d) la diferencia justificada no es discriminación.

4. De acuerdo con la Constitución española, tienen eficacia inmediata y vinculante...

- a) todos los derechos del título I Constitución.
- b) todos los derechos del capítulo II del título I de la Constitución.
- c) solo los derechos de la sección primera del capítulo II del título I de la Constitución.
- d) todos los derechos de los capítulos II y III del título I de la Constitución.

5. En el Estado español, la libertad para afiliarse a un partido político...

- a) es un derecho fundamental.
- b) es una obligación jurídica para los que quieren votar.
- c) no está protegida por la tutela judicial.
- d) es un derecho de configuración legal, porque la Constitución ni siquiera menciona los partidos políticos.

6. El pluralismo que reconoce y garantiza la Constitución española...

- a) es solo el político.
- b) es solo el social.
- c) no se limita al ámbito político, sino que también es social.
- d) es solo el religioso y el ideológico.

7. Actualmente, en el Estado español los cargos de presidente y de vocal de una mesa electoral...

- a) son obligatorios.
- b) son voluntarios, excepto para los militantes de los partidos políticos.
- c) no reciben ningún tipo de remuneración ni dieta.
- d) son ejercidos por jueces o catedráticos, y profesores de derecho o ciencia política o sociología.

8. El art. 53.3 CE, en relación con los principios rectores de la política social y económica, establece...

- a) que pueden ser alegados directamente ante la jurisdicción ordinaria.
- b) que tienen que ser desarrollados mediante una ley orgánica.
- c) que si se vulneran, cabe un recurso de amparo siempre que se agote la vía ordinaria previa.
- d) que solo se podrán alegar ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con aquello que dispongan las leyes que los desarrollen.

9. La forma de Gobierno en la que el Gobierno deriva del parlamento y es responsable ante el mismo es...

- a) el sistema presidencial.
- b) el sistema parlamentario.
- c) solo el sistema mixto o semipresidencial.
- d) solo el sistema de asamblea o convencional.

Solucionario

Ejercicios de autoevaluación

1. c
2. c
3. d
4. b
5. a
6. c
7. a
8. d
9. b

Glosario

ATC *m* Auto del Tribunal Constitucional.

bloque de la constitucionalidad *m* Conjunto de normas integrado por la misma Constitución, los estatutos de autonomía y otras normas que el Tribunal Constitucional puede tener en cuenta para determinar la constitucionalidad de una ley.

CE *f* Constitución española de 1978.

CGPJ *m* Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno administrativo del poder judicial español, con funciones en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

constitución económica *f* Conjunto de normas que proporcionan el marco jurídico fundamental para la estructura y el funcionamiento de la actividad económica. Se encuentran básicamente en el título VII, «Economía y hacienda», de la Constitución, pero también en algunos otros preceptos situados en el título preliminar y en el título I, que en conjunto establecen reglas básicas del proceso económico y de sus actores.

LOPJ *f* Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial.

LOREG *f* Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.

LOTCU *f* Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

OCE *f* Oficina del Censo Electoral, bajo la dirección de la Junta Electoral Central. Tiene como función principal confeccionar el censo electoral, que es el registro público y único de todos los que reúnan los requisitos para ser electores (quienes forman parte del cuerpo electoral) y se actualiza mensualmente.

sentencia interpretativa *f* Sentencia del TC en la que ejerce una cierta función de «legislador positivo», porque establece qué significado hay que atribuir a un precepto legal para que sea conforme a la Constitución.

STC *f* Sentencia del Tribunal Constitucional.

TEDH *m* Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

TS *m* Tribunal Supremo.

Bibliografía

1) Sobre la forma de Estado

- Aragón, M.** (1989). *Constitución y democracia*. Madrid: Tecnos.
- Arendt, H.** (2006). *Los orígenes del totalitarismo*. Madrid: Alianza.
- Bustos, R.** (2017). *Calidad democrática. Reflexiones constitucionales desde la teoría, la realidad y el deseo*. Madrid: Marcial Pons.
- Cabello, M. D.** (2017). *Democracia directa e iniciativa legislativa popular*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Carmona, E.** (2000). *El Estado Social de Derecho en la Constitución*. Madrid: CES.
- Cascajo, J. L.** (coord.) (2016). *Participación, representación y democracia. XII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Cossio, J. R.** (1989). *Estado social y derechos de prestación*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Díaz, E.** (1981). «El Estado democrático de Derecho en la Constitución española de 1978». *Sistema* (núm. 41).
- García-Pelayo, M.** (1986). *El Estado de partidos*. Madrid: Alianza.
- Garrorena, A.** (1984). *El Estado español como Estado social y democrático de Derecho*. Madrid: Tecnos.
- Gutiérrez, I.** (ed.) (2016). *Decidir por mayoría*. Madrid: Marcial Pons.
- Jiménez, R.** (2016). *Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las Instituciones*. Madrid: Marcial Pons.
- López, H.** (2005). *La democràcia cuirassada*. Barcelona: L'esfera dels llibres.
- Pérez, A. E.** (1984). *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*. Madrid: Tecnos.
- Pérez-Moneo, M.; Vintró, J.** (2017). *Participación política: deliberación y representación en las Comunidades Autónomas*. Madrid: Congreso de los Diputados.
- Pisarello, G.** (2011). *Un largo termidor*. Madrid: Trotta.
- Ridao, J.** (2014). «La crisis de legitimidad de la democracia representativa en España: aventurando algunas soluciones». *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho* (núm. 48, págs. 18-23).
- Stolleis, M.** (2014). «La idea de Estado de Derecho». *Fundamentos (Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional)* (núm. 8, págs. 27-55).
- ### 2) Sobre la forma de gobierno
- Ackerman, B.** (2007). *La nueva división de poderes*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Aragón, M.** (1990). *Dos estudios sobre la monarquía parlamentaria en la Constitución Española*. Madrid: Civitas.
- Bobbio, N.** (2001). *La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica de España.
- García, M.** (1991). *La monarquía parlamentaria española*. Madrid: Tecnos.
- García, J.** (1985). *El control parlamentario del Gobierno en el ordenamiento español*. Madrid: Tecnos.
- García, M.** (1993). «La división de poderes y su control jurisdiccional». *Revista de Derecho Político* (núms. 18-19).

García, F. J. (2016). «Control parlamentario y convergencia entre presidencialismo y parlamentarismo». *Teoría y realidad constitucional* (núm. 38, págs. 61-99).

Gómez, Y. (coord.) (2006). *XXV años de monarquía parlamentaria*. Madrid: Sanz y Torres.

González, P. J. (1996). *La cuestión de confianza en la Constitución de 1978*. Madrid: Cortes Generales.

Fernández, J. J. (2018). *La forma de gobierno multinivel. La configuración multinivel del gobierno en el Derecho constitucional español*. Pamplona: Aranzadi.

Molas, I.; Pitarch, I. (1987). *Las Cortes Generales en el sistema parlamentario de gobierno*. Madrid: Tecnos.

Pau, F. (coord.) (1998). *Parlamento y control del Gobierno*. Pamplona: Aranzadi.

Pendás, B. (2009). «División de poderes y formas de gobierno. Una perspectiva contemporánea». *Fundamentos (Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional)* (núm. 5, págs. 207-239).

Pérez, J. (1984). «Jefatura del Estado y democracia parlamentaria». *REP* (núm. 39). Madrid: CEPC.

Presno, M. A. (2009). «Pluralismo de partidos, no separación de poderes». *Fundamentos (Cuadernos monográficos de teoría del Estado, derecho público e historia constitucional)* (núm. 5, págs. 243-300).

Revenga, M. (1988). *La formación del Gobierno en la Constitución Española de 1978*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Sánchez, M. (1992). *La moción de censura: un estudio comparado*. Madrid: Congreso de los Diputados.

Santaolalla, F. (2006). *Derecho parlamentario español*. Madrid: Espasa Calpe.

Vintró, J. (2006). *La investidura parlamentaria del Gobierno: perspectiva comparada y Constitución española*. Madrid: Congreso de los Diputados.

Vírgala, E. (1988). *La moción de censura en la Constitución de 1978*. Madrid: CEC.

3) Sobre la organización territorial del Estado

Aja, E. (2003). *El Estado autonómico, Federalismo y hechos diferenciales*. Madrid: Alianza.

Barceló, M.; Vintró, J. (coords.) (2008). *Dret Públic de Catalunya*. Barcelona: Atelier.

Barceló, M.; Corretja, M.; González Bondia, A.; López, J.; Vilajosana, J. M. (2015). *El derecho a decidir. Teoría y práctica de un nuevo derecho*. Barcelona: Atelier.

Cagiao, J.; Ferraiuolo, G. (coords.) (2016). *El encaje constitucional del derecho a decidir: un enfoque polémico*. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Cruz, P. (1992). «La Constitución territorial del Estado». *Autonomies* (núm. 13). Barcelona: EAPC.

Fossas, E. (2007). *El principio dispositivo en el Estado autonómico*. Madrid: Marcial Pons.

García, E. (2016). *La revisión del sistema de autonomías territoriales: reforma de Estatutos, leyes de transferencia y delegación, federalismo*. Madrid: Civitas.

Häberle, P. (2008). «El Valor de la autonomía como elemento de la cultura constitucional común europea». *Revista de Derecho Constitucional Europeo (RdDCE)* (núm. 10). Granada: IAAP.

Mateu, M.; Pérez, J. Ll. (2017). *Dret Públic de Catalunya*. Barcelona: FUOC.

Ridao, J. (2018). *Curs de dret públic de Catalunya*. Madrid: Marcial Pons.

Ortega, L.; Martín, I. (2005). *La reforma del Estado autonómico*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Pizzorusso, A. (1993). *Minoranze e maggioranze*. Turín: Einaudi.

Porras, J. M. (2005). «El autogobierno local en el Estado autonómico. Premisas para una reforma necesaria». *REDC* (núm. 75, págs. 211-238). Madrid: CEPC.

Pérez, P. (2018). *Las reformas de la Constitución hechas y no hechas*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Tudela, J.; Kölling, M.; Reviriego, F. (2018). *Calidad democrática y organización territorial*. Madrid: Marcial Pons.

Viver, C. (1994). *Las autonomías políticas*. Madrid: Instituto de Estudios Económicos.

4) Sobre la justicia constitucional y el Tribunal Constitucional español

Abat, A. (2010). *El Estatuto Jurídico de los Magistrados del Tribunal Constitucional Español. Estudio y análisis comparado*. Madrid: Aranzadi.

Bercholz, J. O. (2017). *La producción del Tribunal Constitucional de España a través del control de constitucionalidad. Un estudio empírico-cuantitativo, con análisis cualitativo agregado, sobre el rol desempeñado por el Tribunal Constitucional en el sistema político-institucional español*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Espín, E., Díaz, F. J. (coords.) (2000). *La justicia constitucional en el Estado democrático*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Estrada, J. A. (2017). *La designación de los magistrados del Tribunal Constitucional en España. Una perspectiva orgánica y empírica*. Pamplona: Aranzadi.

Favoreu, L. (1995). *Los tribunales constitucionales*. Barcelona: Ariel.

Garrorena, A. (1999). «Condiciones y efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional: artículo 164». En: Alzaga Villaamil, O. (dir.). *Comentarios a la Constitución española de 1978*. Madrid: Cortes Generales.

Pérez, P. (2010). *Sistema de justicia constitucional*. Madrid: Civitas.

Prieto, L. (2015). *Justicia constitucional y derechos fundamentales*. Madrid: Trotta.

Ridao, J. (2016). «Las nuevas facultades ejecutivas del Tribunal Constitucional como sustitutivo funcional de los mecanismos de coerción estatal del artículo 155 de la Constitución». *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria* (núm. 106, págs. 151-188).

Ruiz, R. (2016). *Discrecionalidad judicial, justicia constitucional y objeción contramayoritaria*. Pamplona: Aranzadi.

Sabela, B. (2012). *El Tribunal Constitucional. Pasado, presente y futuro*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Sospedra, F. J. (2011). *Justicia constitucional y procesos constitucionales*. Madrid: Civitas.

Tomás y Valiente, F. (1993). *Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional*. Madrid: CEC.

Villanueva, A. (2018). *El Tribunal Constitucional Español. Una visión actualizada del supremo intérprete de la Constitución*. Madrid: Editorial Tébar Flores.

Villaverde, I. (1997). *La inconstitucionalidad por omisión*. Madrid: McGraw-Hill.

